分类号 D923.04　　密 级

UDC　　编 号 10486

武 汉 大 学

博 士 学 位 论 文

纯粹经济损失赔偿研究

研 究 生 姓 名：王　　璟

指导教师姓名、职称：温世扬　教授

学 科、专 业 名 称：法学·民商法学

研 究 方 向：比 较 民 商 法

二〇一〇年四月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Study on the Compensation for Pure Economic Loss

By

Wang Jing

April, 2010

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

郑重声明

本人的学位论文是在导师指导下独立撰写并完成的，学位论文没有剽窃、抄袭、造假等违反学术道德、学术规范和侵权行为，否则，本人愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果，特此郑重声明。

学位论文作者（签名）：王涛

2010 年 5 月 30 日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

学位论文使用授权书

本论文作者完全了解学校关于保存、使用学位论文的管理办法及规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权武汉大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国博士学位论文全文数据库》进行信息服务，也可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存或汇编本学位论文。

本论文提交□当年/□一年/□两年/☑三年以后，同意发布。

注：保密学位论文，在解密后适用于本授权书。

作者签名：王蝶　　导师签名：温世扬

2010 年 5 月 29 日　　2010 年 5 月 29 日

学院：法学院

学号：2006110800057

专业：民商法学

（一式三份，交研究生院学位工作处）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

论文创新点

本文创新点主要包括四点：

第一，提出了成立纯粹经济损失赔偿责任时，应考虑的九个因素：当事人的主观心理状态，潜在原告数量无限制的可能性，损失的可预见性，当事人之间的近因性，被告是否负担额外的注意义务，当事人之间的合理信赖，潜在原告的保护手段，原告经济损失的重要性，当事人之间的金钱上的利害关系。

第二，以既有的侵权责任构成要件来合理限制纯粹经济损失的赔偿责任，即要求损害具有正当性及严重性；以可预见性来认定是否有过错，具体认定过错时应当考虑以下因素：双方当事人间的特殊关系或近因性，额外的注意义务，合理的信赖，潜在原告的保护手段，金钱上的利害关系；以因果关系要件来确定责任的归属与范围，要求具有直接的因果关系，且利用因果关系的举证责任来达到限制的目的。

第三，针对中国新颁布的《侵权责任法》关于保护范围的规定，认为民事权益虽然属于侵权责任法的保护范围，但综合《合同法》的一些规定，认为权利和利益还是应该区别保护，不能一体保护。对利益的保护程度要低于绝对权，应该合理限制纯粹经济利益的保护。

第四，根据文章的研究分析，认为具体的规定可以是这样的：“故意导致的纯粹经济损失应当承担赔偿责任。过失导致的纯粹经济损失，应当特别考虑以下因素：潜在原告数量无限制的可能性，原被告双方之间的近因性，额外的注意义务对行为自由的限制，原告的合理信赖，潜在原告通过其他方式保护自己的能力，原告损失的可预见性，原告遭受经济损失的重要性，当事人双方是否有金钱上的利害关系。因此过失导致的纯粹经济损失，原告应当证明自己遭受的损害的正当性和严重性，被告对原告的损失具有可预见性，原告的损失是被告的过错所直接导致的结果。”

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中文摘要

纯粹经济损失问题已经成为现代侵权行为法扩张中的主要问题之一。在一些国家，他和不可控制的、不可预见的且无休止的诉讼洪水联系在一起；而在另一些国家，这个问题好象被忽视，纯粹经济损失看起来和其他损失一样对待。这种反差本身就证明了在纯粹经济利益的保护问题上进行比较是正当的。对于纯粹经济利益的保护，触及侵权行为法中最为困难的课题，如纯粹经济利益与其他权益的利益衡量和价值比较问题，损失范围的不确定性问题，侵权法和合同法的规范机能的重合与区分问题。必须承认，对于纯粹经济利益完全不予保护是个过时的路径，然而对纯粹经济利益予以全面保护也会导致不公平的结果，因此如何选择将成为我们研究的重点。

本文共分为五章，首先从纯粹经济损失的定义入手，厘清了纯粹经济损失与间接经济损失的区别，将纯粹经济利益定性为法益。然后考察比较了英国、德国、法国对待纯粹经济损失赔偿问题的方式及态度，得出责任排除规则背后的政策考量是什么，再结合分析为什么一些经济利益受到公认的保护，得出成立纯粹经济损失赔偿责任的九个考虑因素，并试图用既有侵权责任构成要件来限制纯粹经济损失的赔偿责任。然后以此考虑因素及严格的构成要件来分析一些具体的纯粹经济损失是否应该得到保护。最后，再结合我国的具体实际，尝试对纯粹经济损失赔偿问题进行具体的立法规定。

本文前言主要介绍了选题理出和意义，阐述了国内外对纯粹经济损失赔偿问题的研究现状及趋势，以及本文的研究方法。

第一章为“纯粹经济损失的概念界定”。该章首先对纯粹经济损失进行定义，然后分析了纯粹经济损失的特点，将纯粹经济损失与间接经济损失进行比较。最后将纯粹经济利益的性质界定为一种法益。

本文将纯粹经济损失定义为：被害人所直接遭受的经济上的不利益或金钱上的损失，其并非是作为被害人的人身或有形财产遭受损害的结果而发生的经济损失。认为纯粹经济损失的特点是：（1）纯粹性，即独立性，指纯粹经济损失是一种在任何方面与人身伤害和财产损害都没有关联的经济损失。（2）经济性，即金钱性，即

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

当事人损失的是金钱或金钱财富。(3) 损失性，即不利益性，指受害人因经济利益受到侵害而引起财产总量的减少。本文认为间接经济损失是指与原告人身或财产受到的任何侵害发生联系的经济损失，即“立即”或“直接”跟随实质损害而产生的，是可以获赔的损失。损失是否与原告的有形财产损害或者人身损害相联系，是纯粹经济损失与间接经济损失的主要区别。但二者的区别具有高度的技术性，或者甚至是人为的，其来自于责任排除规则的两个技术特征：首先是间接经济损失只描述同一财产集合内部的因果关系；其次，间接经济损失是一个最终结果受政策考量影响的因果概念。

权利与利益的区别在于是否具体特定，将纯粹经济利益的性质认定为是一种法益，是法律尚未明文规定的利益，是未被权利化的利益，因为其符合法益的特性：难以具体特定。

第二章为“纯粹经济损失的外国法考察——以英、德、法三国为例”。该章对英国、德国和法国对于纯粹经济损失赔偿的处理模式进行了考察比较，分析了实用式体系的代表——英国法中的纯粹经济损失问题，保守体系的代表——德国法中的纯粹经济损失问题，放任式体系的代表——法国法中的纯粹经济损失问题，并对三国的处理模式进行了比较分析。

英国普通法的传统是对纯粹经济损失不予赔偿，后来在司法实践中，Hedley Byrne 案突破了责任排除规则，确立了许多解释注意义务存在的理论：特别关系的理论、责任的自愿承担理论、合理的信赖理论及金钱上的利害关系理论。但是，Hedley Byrne 案仅是在“过失不实陈述”领域突破责任排除规则，并没有彻底颠覆传统。而后出现了很多类型的纯粹经济损失案件，法官对其处理充满了变数和不确定性，后来在此基础上又提出了注意义务的三阶段检验标准：损失的可预见性、当事人间关系的近因性及政策因素。

德国的侵权行为法规定采用了三个层次的规范模式，使得只有违反“以保护他人为目的的法律”或“故意违背善良风俗”所导致的纯粹经济损失才有可能获得赔偿，因此基本排除了纯粹经济损失在侵权法下获得赔偿的可能性。而后，德国法院进行了一系列的尝试，如创设“营业权”，创设“物之使用不能”案型，然而效果并不理想。于是德国法院开始扩大契约法的救济，运用缔约过失责任、“附保护第三人作用之合同”理论及第三人损害清算理论来扩大对纯粹经济损失的保护。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

《法国民法典》第1382条和1383条并未事先对受保护的权利及利益的范围和性质作出限制，也未事先对受保护群体的范围作出限制，因此立法中未区分纯粹经济损失和非纯粹经济损失，而是予以一体保护。法国民事责任普通法中的损害，原则上一种“主观的损害”，且赔偿原则采用“全部赔偿原则”或“损害与赔偿相当性”原则。在司法实践中，对经济利益的保护有两种：经济利益的故意侵权保护，如干预他人契约关系而产生的侵权责任，及经济利益的过失侵权保护。立法的宽松导致了赔偿责任的苛重，于是法国法官运用侵权责任要件，如损害的确定性及损害的直接性以及因果关系，来作为对纯粹经济损失的赔偿责任进行控制的工具。

英国合同法由于对价的坚持，对于纯粹经济损失的保护主要是适用过失侵权行为法，主要是基于注意义务的认定，但背后有深层次的政策考虑，因此，英国法的特点可以概括为：普通法的不赔传统，司法的波折反复和侵权法的救济偏好，体现了实用主义的特点。德国由于其民法典采取“绝对权利”的清单方式，因此侵权法对纯粹经济损失的救济极为有限，从而扩大合同法的救济方式，因此，德国法的特点可以概括为：立法的拒绝赔偿、司法的松动和契约法的救济偏好，体现了保守主义的特点。法国民法典采取了最宽泛的一般条款，未排除纯粹经济损失的赔偿责任，在实务中对纯粹经济损失案件的处理，虽有政策的选用，却未明说，而只是借助于因果关系或损失的直接确定性来否定纯粹经济损失的赔偿。因此，法国法的特点可以概括为：宽松的立法、苛重的赔偿责任和侵权法的救济偏好，体现了放任主义的特点。三种模式的主要区别是：英国法国采用侵权法进行救济，而德国多采用合同法进行救济；英国最重要的特征是谨慎的个案分析方法，德国运用合同法和其他制定法机制来获得赔偿，法国则通过一般条款的构成要件，尤其是损害及因果关系要件来巧妙处理纯粹经济损失案件中的政策考量；法国法中合同和侵权概念互不重叠，而英国和德国则允许侵权责任和合同责任的竞合。

第三章为“纯粹经济损失赔偿责任的排除、成立与限制”。该章通过分析法律区别保护纯粹经济损失及对物的有形损害和人身损害的原因，及公认的受保护的经济利益的范围，得出成立纯粹经济损失赔偿责任时应当考虑的九个因素，然后试图以侵权责任的构成要件来限制纯粹经济损失的赔偿责任。

本文认为对于人身和财产的有形损害与纯粹经济损失予以区别保护的原因在于：诉讼闸门的风险，维护人们的基本行为自由，优越法益论据，保险因素以及经

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

济分析的视角。

公认的受保护的经济利益范围有：（1）合同责任：对合同责任中的纯粹经济损失予以广泛保护的原因，主要是没有诉讼闸门的风险；对人们的基本行为自由没有限制；未违反合同一方当事人的损失是可以预见的；合同当事人的经济利益依赖于另一方当事人的谨慎行事，尤其是纯粹经济利益；合同当事人双方都在追求自己的商业利益。（2）近似于合同关系：主要为缔约过失责任等近似于契约关系。（3）故意侵权造成的纯粹经济损失：主要包括第三人故意侵害债权、故意不实陈述（欺诈）、通谋损害第三人利益、假冒、引诱违反合同、恶意诽谤、滥用垄断优势和非法干涉交易等情形，是所有法律制度都予以保护的领域。（4）间接损失：以受害人存在实际损害为前提，在任何国家均受保护。（5）关联损失中的例外：即人身伤害和死亡的案件中，配偶和孩子会特别给予一定形式的赔偿。（6）转移损失：也是大多数国家所承认的一个例外。

通过以上两节的分析，本文认为在确认是否成立纯粹经济损失的赔偿责任时，需要考虑以下九个因素：当事人的主观心理状态，潜在原告数量无限制的可能性，损失的可预见性，近因性，额外的注意义务，合理的信赖，潜在原告的保护手段，原告经济损失的重要性，金钱上的利害关系。然后试图以既有的侵权责任构成要件来合理限制纯粹经济损失的赔偿责任，即采用严格的构成要件：要求损害具有正当性和严重性；认定过错时要求被告对于原告的损失具有一定程度的可预见性，具体考虑以下因素：双方当事人间的特殊关系或近因性，额外的注意义务，合理的信赖，潜在原告的保护手段，金钱上的利害关系；用“可预见性”来界定因果关系，及因果关系的证明活动来合理限制纯粹经济损失的赔偿责任。

第四章为“纯粹经济损失的类型”。该章首先将纯粹经济损失予以类型化，然后再针对具体的类型进行分析。

对纯粹经济损失的分类影响最大的，也是欧洲通行的分类，为《欧洲法中的纯粹经济损失》一书中的分类，其将纯粹经济损失分为反射性损失，转移损失，公共市场、运输通道和公用设施的关闭，对错误信息、建议和专业服务的信赖四类。而实践中常见的类型有：电缆案件，遗嘱无效案件，不实陈述案件，公共设施损害案件，雇员和家庭成员人身伤亡案件及第三人侵害债权案件。

典型的“反射损失”产生于一方当事人财产或人身受到实际损害，而该损害进

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

而引致原告权利受损的情况，通常包括两种类型：侵害某人的人身（死亡或伤害），致其他与该被害人有亲属或契约关系之人受有财产损失；侵害某人之物，致其他之人（尤其是债权人）遭受财产上损失，此类损失的典型代表为“电缆案件”。在雇员和家庭成员人身伤亡案件中，英国德国通常不予赔偿，除非为“扶养费损失”，法国对因人身伤害或死亡而导致的反射损失赋予请求权。根据我们的考虑因素，通常对此类损失不予赔偿，理由是：诉讼闸门，近因性及不可预见性。根据侵权责任构成要件，第二受害人可能众多，被告没有预见的可能性，因此没有过错。但是大多数法律制度都对配偶和孩子失去的扶养费给予某种形式的赔偿，因为诉讼闸门理由不存在，没有对侵权人附加额外的注意义务，生活费损失是可以预见的且具有特殊的重要性。而根据侵权责任构成要件，配偶和孩子的扶养费损失具有严重性，被告对配偶和孩子失去扶养费具有预见的可能性，认定其存在过错，并且二者之间具有因果关系。所以加害人应该赔偿配偶和孩子的扶养费损失。对于电缆案件，英国法出于政策的考量，通常采取排除规则，不予赔偿。在德国，如果原告伴随有其他实质损害，则停工损失可以获得赔偿，如果只有停工损失，则不能够获赔。法国理论上认为此类损失可以获得赔偿，但法官会重点调查生产损失是否足够直接以及是否应当认定因果关系具有充分性。根据我们的考虑因素，则认为此类损失基本不可赔，理由在于：非故意，诉讼闸门论据，当事人双方无近因性，原告有保护自己利益的其他手段，被告无法预见原告的经济损失，此类经济损失对原告来说具有较少的重要性，虽然没有给被告施加额外的注意义务，但显然否定因素多于赞成因素。而根据侵权责任构成要件，原告的损失多不具有严重性，并且被告多没有过错，因为对原告的损失没有预见的可能性，此外原告可以通过自备发电器来减少损害，因此其自身也有过错，可以适用与有过失的理论。所以权衡利弊，对此类损失不予赔偿。最后分析了重庆电缆案，认为法院的判决结果是正确的，判决理由也基本正确。

转移损失的情形是指，C 造成了 B 财产或人身的实际损害，但 A 和 B 的合同（或法律本身）将通常属 B 的损失转移给了 A。转移损失发生的典型案例有两类：因合同而发生的转移，因法律规定而发生的转移。从侵权行为人责任的角度而言，转移损失的安全对其是中性的，而且它可能带来的困难更多的是技术上问题而不是政策或者衡平问题，必要时可以引入代位请求的方法，因此也可避免对不确定责任的担心。支持做出赔付判决的另一些理由是：虽然一些规则的意外适用纯属偶然地

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

排除了他的责任，但对原始受害人明显负有责任的侵权行为人不应从中受益。根据冯•巴尔的说法，转移损失的概念目的在于“避免一些人求助于那些原意不是保护他，而是保护其他人的规则”。

在公共市场、运输通道和公用设施的关闭类案件中，经济损失不是产生于此前对任何人财产或人身的伤害。也许存在实际损害，但它是对公共领域里“不属于个人所有的资源”的损害。同电缆案件类似，英国德国都不予赔偿，而法国仍具有一定的随意性。根据我们的考虑因素，通常认为在交通堵塞这样的案件中，第三方的纯粹经济损失是没有必要赔偿的，理由在于：非故意，诉讼闸门论据，当事人双方无近因性，被告无法预见原告的经济损失，此类经济损失对原告来说具有较少的重要性。而根据侵权责任构成要件可以得到同样的结论：原告的损害通常不具有严重性，被告对原告的损失没有预见的可能性，不构成过错，二者的因果关系很难成立。

对错误信息、建议和专业服务的信赖，通常包括两个典型案件：过失服务和不实陈述。文中以遗嘱无效和专家第三人责任为案型进行分析。在遗嘱无效案件中，英国法认为律师违反了注意义务，应承担赔偿责任；在德国，原告可以依据“附保护第三人作用之合同”理论获得赔偿；在法国，原告可以根据《法国民法典》第1382条之规定获得赔偿。根据我们的考虑因素，认为此类损失是可以获得赔偿的，理由在于：诉讼闸门理由不成立，双方之间具有某种程度的近因性，没有给公证人或律师附加额外的注意义务，原告的损失是公证人或律师可以预见到的，遗产对于预期受益人具有某种重要性，公证人或律师获得报酬。根据侵权责任的构成要件分析也可以得到同样的结果，因为原告的损害具有正当性及严重性，被告对原告的损害具有完全的预见可能性，因此具有过错，而且被告的过错导致了原告的损失，二者间具有因果关系。最后分析了中国的王保富诉三信律师事务所财产损害赔偿纠纷案，认为判决结果虽是正确的，但判决理由不充分。不实陈述类型的案件，是各国讨论的热点。英国法从注意义务理论入手，通过承认专业人士对特定范围内第三人承担注意义务，肯定了专业人士对第三人的侵权责任，使第三人的损害可以通过过失侵权法得到救济。在德国，专家责任到目前为止源自德国法院创造的默示合同或基于“附保护第三人作用之合同”，现在则成为基于缔约过失责任的专家对第三人的直接责任。而法国法因为未区分纯粹经济损失和物的实质损失，因此可以获得赔偿，但是运用因果关系这个弹性工具，使得判决结果具有一定的不可预见性。根据我们

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的考虑因素，认为由于诉讼闸门理由、无近因性、不可预见性等反对理由，通常会计师不对第三人承担责任，除非存在故意。但是如果特殊情况下，会计师对第三方的损失具有明显的可预见性，则能够成立责任。而且如果第三方为中小投资者，则通常能够成立责任，如果为银行或其他有能力保护自己经济利益的第三方时，则责任通常不能够成立。最后分析了中国的蓝田股份造假案。

债权作为一种法益，第三人侵害债权产生的损失为纯粹经济损失，英国、德国和法国均将责任限定于故意情形，而德国对于故意的要求更高些，要求“违反善良风俗”。根据考虑因素及构成要件来分析，故意显然可以成立责任，而过失情形下，由于第三人对债权的存在无从知晓，没有预见的可能性，不能成立过错，并且债权人债权的实现要依赖很多因素，不能因此认为第三人侵害债权与债权人债权的未实现之间具有直接的因果关系。最后分析了太原市外企服务公司诉《山西晚报》巨额赔偿案，认为法院的判决是不正确的，因为不能认定被告具有故意，最多只能认定其有过失。

第五章为“我国相关立法之检讨”。该章首先分析了我国现行法中关于纯粹经济损失的规定，进而分析了德国和法国侵权法的一般条款模式，比对我国侵权责任法的一般条款，尝试对我国的纯粹经济损失赔偿问题进行具体的立法建议。

《民法通则》第 111-116 条规定了合同责任，《合同法》对于合同效力的扩张做了一些规定，如较为全面地规定了附随义务，确立了缔约过失责任，并且规定了涉他契约，然而对第三人利益的保护并不全面。《侵权责任法》确立了同《民法通则》相类似的一般条款模式，将侵权责任法的保护对象确定为“民事权益”。另外还有大量的立法和司法解释涉及纯粹经济损失的赔偿问题。

在侵权行为法的一般条款的模式上，法国采用减法模式，即在逻辑起点上，任何损害均可以获得赔偿，除非有某种抗辩事由，德国采用加法模式，即在逻辑起点上，只承认对权利的侵害构成侵权行为，而应受保护的利益则根据其他规定加入可赔偿的行列。我国《侵权责任法》最终形式上采用了法国模式，但根据与现行法的协调及主流学说、司法实践等具体情况，认为虽然侵权责任法的保护范围包括权利与利益，但对利益的保护程度要低于绝对权。最后根据《欧洲侵权法基本原则》及《奥地利损害赔偿法草案》，结合前面章节的分析，认为我们可以将纯粹经济损失赔偿问题具体规定为：“故意导致的纯粹经济损失应当承担赔偿责任。过失导致的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

纯粹经济损失，应当特别考虑以下因素：潜在原告数量无限制的可能性，原被告双方之间的近因性，额外的注意义务对行为自由的限制，原告的合理信赖，潜在原告通过其他方式保护自己的能力，原告损失的可预见性，原告遭受经济损失的重要性，当事人双方是否有金钱上的利害关系。因此过失导致的纯粹经济损失，原告应该证明自己遭受损害的正当性和严重性，被告对原告的损失具有可预见性，原告的损失是被告的过错所直接导致的后果。”

关键词： 纯粹经济损失；经济利益；责任排除规则；赔偿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

Pure economic loss compensation has become one of the main problems in the expansion of modern tort law. In some countries, it is linked together with the uncontrollable, unforeseeable and endless litigation flood. And in some other countries, the problem seems to have be ignored, for pure economic loss is treated the same with other treats loss. The disparity itself justifies the composition of the protection of the pure economic interest comparison. Protection of pure economic interests touches upon the most difficult topics in tort laws, such as evaluation and comparison of pure economic interests and other interest, the uncertainty of loss of range, and the overlapping and difference of regulating functions of the tort law and the contract law. Admittedly, it is outdated not to fully protect pure economic interests, but its full protection leads to the unfair result, so we will focus on what choice to make in this research.

This dissertation is divided into five chapters. Starting from the definition of pure economic loss, it clarifies the difference between the pure economic loss and indirect economic loss, characterized pure economic intereses as legal interests. Then it examines the attitudes of British, German, French to pure economic loss as well as their compensation methods. And figures out what policy underlies the exclusionary rules. On the basis of analyzing why some of economic interests are universally protected, it puts forward nine factors in establishing pure economic loss compensation liabilities, and tried to limit the pure economic loss compensation liabilities existing tort liability constitutions. Given these nine factors and strict constitutions, it analyzes whether some specific pure economic loss if types should be protected. Finally, with China's concrete practice, its attempts to set up specific legislation for pure economic loss compensation.

The preface mainly introduces the reasons and the significance of the research, and expounds on the research status and trend of pure economic loss compensation as well as the research methods.

The first chapter is "concept of pure economic loss concepts". Firstly this chapter

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

defines the pure economic loss, and then it analyses the characteristics and qualities of pure economic loss, then it compares pure economic loss with indirect economic loss. Finally it characterized pure economic intereses as legal interests.

This pure economic loss will be defined as: the victim suffers direct economic interest or loss of money, rather than economic loss resulting from the damage to a victim's personal or visible property. The pure economic loss has three characteristics: (1) Purity, namely, independence. It refers to the loss that has nothing to do with property damages in any respect. (2) Economy, namely, that money the party suffers from loss of money or wealth. (3) Loss, namely, the victim is infringed due to the economic benefit and suffers the loss of the total assets. In this dissertation, the consequential economic losses mean economic losses which are connected to any infringement of the person or property, namely "immediately" or "directly" follows substantial injury, and can obtain compensate. The main difference between the pure economic loss and the consequential economic loss is whether the losses are associated with the plaintiff's physical property or damage to the persons. However, the difference between the two is highly technical, or even man-made, its the responsibility of the exlusionary rule from the two technical features: first, the consequential economic losses only describe the collection of the same property within the causal relationship; Second, the consequential economic losses are a final results were affected by policy considerations affect the concept of cause and effect.

The difference between the rights and interests of any specific particular, the purely economic nature of that interest recognized as a legal interest, the law has not expressly provided for the interest, is not the rights of interests, as they meet the legal interests of the features: difficult to specify a specific.

Chapter two is "comparison of pure economic loss compensation and analysis in foreign countries—the British, Germany, France ". This chapter investigated pure economic loss compensation mode of Britain, Germany and France, analyzed the typical practical system - British law on pure economic loss compensation; representative of conservative system - pure economic loss compensation system in Germany, representatives of the indulgent system - the pure economic loss compensation in France.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

At last it compares and analysies the three countries' processing modes.

The British common law tradition is no compensation for pure economic loss. Later in the judicial practice, Hedley Byrne case broke the exclusionary rule, setting up many theories explaining the existence of duty of care: the theory of voluntary assumption of responsibility, theory, the reasonable reliance theory and theory on money interests. However, in the case of Hedley Byrne, the rule was broken in misstatements without completely subverting the traditional rules. Then there are many types of pure economic loss cases, judges dealt with them with variables and uncertainty. On the basis the inspection standards for three stages of the duty of care were put forward: predictability of loss, the proximity of parties and policy factors.

German tort law regulations adopted three levels of regulating mode, pure economic loss can be compensated which results from violation of "the laws for the purpose of protecting others" or "intentional violation of the good custom". Therefore it excluded the possibility that pure economic loss was compensated in tort law. Then, the German court conducted a series of trying, such as creating "business", "the use case model and create", but the effect is not ideal. German court began to expand contract law relief, using culpa in contrahendo, "the effect of the third attached to protect the contract" theory and the theory of liquidation damage to third parties on pure economic loss to expand the protection.

Terms No.1382 and No.1383 in the French civil code do not restrict in advance the cope and quality of protected rights and interests, the scope of protection groups is not limited beforehand. So in legislation there is no difference between pure economic loss and the non-pure economic loss, but the same protection is given. In judicial practice, there two kinds of ways to protect economic benefits: protection of intentional tort e.g. tort liability resulting from intervention of contractual relationship, and protection of negligence of economic benefit. The loose legislation leads to heavy liability to pay compensation. Thus the French judges use as a tool to control compensation for pure economic loss, such as determinacy and directness of damage.

Due to the institence of consideration in English contract law, so the protection of

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

pure economic loss is mainly applicable to negligence tort law, and mainly based on identification of the duty of care, but deep behind is the policy considerations, embodies the charatersitics of pragmatism. Therefore, the British law can be summarized as follows: the tradition of no compensation in the common law, judicial twists relief preferences of the tort law. Germany because of its Civil Code to take "absolute rights" list, so tort of pure economic loss relief is extremely limited, thereby expanding the law of contract remedies way. Therefore, the German law can be summarized as follows: the legislation for refusal of compensation, loose judicial system and contract law relief preference, and embodies the characteristics of conservatism. French Civil Code adopted the most broad general terms, does not exclude liability for pure economic loss, in practice the cases of pure economic loss treatment, although the policy choice, but did not explicitly stated, but rather by means of cause and effect relationship or the loss of direct uncertainty to deny compensation for pure economic loss. Therefore, the French law can be summarized as: loose legislation, heavy liability for compensation and tort relief preference, and embodies the characteristics of laissesfaire. The main difference between three models are: the British and French used tort relief, while the German mainly use contract law to relief; Britain's most important feature is the careful analysis of the case, the German use of contract law and other statutory law mechanisms to receive compensation, France through the general provisions of the general elements, especially the causal relationship element to skillfully deal with cases of pure economic loss in the policy considerations; In the France, the concept of contract and tort is non-overlapping, while the English and Germany to allow tort liability and contractual liability of the competing .

The third chapter is "the exclusion、establishment and restriction of pure economic loss compensation ". This chapter analyzes why pure economic loss, the physical damage and personal injury are protected differently, and describe the scope of protected economic interests. At last it put forwards nine factors which should be taken into account when pure economic loss compensation is established, and then attempt to limit liability for pure economic loss by stict constituents of tort liability.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

The dissertation thinks that pure economic loss, the physical damage and personal injury should be protected differently for the following reasons: floodgate risk, maintaining the people's basic freedom of behavior, superior arguments, insurance and the economic analysis angle.

The universally-acknowledged scope of protection of economic benefits includes: (1)contract liability: the reason why pure economic loss contract shall be extensively protected is mainly that there is no floodgate; there is no restriction to people's basic freedom of behavior; the loss suffered from by the party who has not violated the contract; the party's interest depends on the other party's caution, especially the pure economic interests; the parties are in pursuit of their commercial interests. (2) Near-contractual relationship: mainly including culpa in contrahendo. (3) Pure economic loss caused by Intentional tort: mainly including the third party infringement claims, deliberate untrue statement (fraud), conspires third party's interests, breach of contract, malicious slander, abusing the monopoly advantage and unlawful interference with trading. All theses are protected by legal system. (4) The indirect losses: the indirect losses are protected in any country on the premise that the victim really suffers from actual damage. (5) The exception to the relational loss: namely spouses and children will receive some special form of compensation for losses in death and personal injury cases. (6) Transferred loss: most countries have admitted this exception.

Through the above analysis, this paper argues that the following nine factors should be taken into consideration in deciding whether to set up the responsibility for compensating the pure economic loss. whether it is intentional tort, the number of potential plaintiff is unlimited, both parties have proximity, whether to impose on the defendant responsibility will lead to additional duty of care, whether the reasonable trust relationship exists between both parties, whether the potential has other means to protect their interests in, the defendant can reasonably foresee the plaintiff's losses, whether economic losses holds a special significance for the plaintiff, if both parties have some money relationship. And then attempt to constitute the elements of the existing tort liability to reasonable limitation of liability for pure economic loss, namely, strict

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

composition requirements: for damages with the legitimacy and seriousness; finds fault of the plaintiff when the defendant for the loss of a certain degree of predictability, specifically consider the following factors: the special relationship between the parties or the proximate cause of the extra duty of care, reasonable reliance, the potential protection of the plaintiff's money is at stake; with "predictability" to define the causal relationship between and the proof of causal relationship between activities to reasonable limitation of liability for pure economic loss.

The fourth chapter is "type of pure economic loss". This chapter first categorizes pure economic loss, and then analyzes it according to the concrete types.

The classification of pure economic loss in 《The pure economic loss in European law》 is the most influential classification, which is also the common classification in Europe. In this book, the pure economic loss is divided into ricochet losses, the transfer losses, public market, the closure of transport channels and public facility, trust in error messages, advice and professional services. But in practice the common types are as follows: cable cases, invalidation of wills cases, untrue statement, damages to public facilities case, employee and family member casualties' case and the third party's infringement cases.

A typical "ricochet loss" arising from a party by the actual damage to property or person, which in turn caused damage to the right plaintiff, the case of damage, usually include two types: the personal against the person (death or injury), for the other and the Victims have relatives or contractual relations were affected by the loss of Property; against a person things, for the other person (especially creditors) suffered property losses, such losses typical of a "cable case." In the case of employee and family member casualties, compensation is not obtained in both Britain and Germany except for the claim for "maintenance loss". French law grants claim for personal reflection loss resulting from personal injuries or death. According to our consideration such loss are usually not compensated. The reasons are: litigation gate, proximity and unpredictability. According to the tort liability constitutions, the second victims may be a number, the defendand can not foresee the possibility, so there is no fault. But most of the legal system support some kind of compensation for spouses and

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

children who have lost upbringing fees for there does not exist litigation gate. There is no additional duty of care, and living expenses are predictable and has special significance. According to the tort liability constitutions, spouse and child maintenance with the severity of the loss, the defendants can foress the possibility of lost maintenance by spouse and children, so determined that the existence of fault, and the causal link between the two. Therefore, perpetrators should be compensation for the spouse and children for loss of maintenance.Cable case is typical of pure economic loss case and is of the most common type, digging the cable with negligence leads to the economic losses of the relevant person. This case is so typical a representative that it is conventionally called cable case in modern law. In such cases, the British law usually adopts elimination rules due to the consideration of policy, not granting compensation. In Germany, if the plaintiff suffers from other substantial injuries, he can obtain compensation for not being able to work. If there are only shutdown losses, he can not obtain compensation. Theoretically speaking, France grants compensation for such losses, but the judge will lay emphasis on investigating whether the loss is direct enough and whether the cause and effect relationship is sufficient. According to our consideration, the author thinks such losses shall not be compensated. The reasons are as follows: indeliberateness, litigation gate, both parties have no proximity, the plaintiff has other means to protect his interests, the defendant cannot foresee the plaintiff's economic losses, such economic losses has less importance to the plaintiff. Though no extra attention obligation is added on the defendant, but obviously negative factors are more than approval factors. According to the tort liability constitutions, the plaintiff's loss will not have the seriousness and the defendant for more than a fault, because he could not foresee the possibility of the plaintiff's loss, in addition to the plaintiff can bring their own generators to reduce the damage and therefore, also have their own fault, so can be applied with the contributory negligence theory.With the advantages and disadvantages taken into consideration, such loss are not granted compensation. In The Chongqing cable case is analyzed at last and the author thinks that court verdict result is correct and its reasons are general right.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Transterred loss is of the case, C caused B actual damage to property or person, but the contract of A and B (or the law itself) would normally be transferred the loss B to A. There are two types: contract occurred due to the transfer, and occurred due to the transfer law. From the perspective of tort liability, the transfer of security to its neutral loss, and the difficulties it may bring more of a technical problem rather than a policy or equity issues, when necessary, to introduce the method Subrogation , and therefore can avoid uncertain liability concerns. Support the decision to make compersaion to some other reasons: Although some of the rules applicable to the accident by acceident eccludes his responsibility, but obvilusly responsible for the original victioms of the violations shoule not benefit form it. According to Von Bars argument, the purpose is to transfer the concept of loss "to avoid some people turn to those who intended not to protect him, but the protection of other people's rules."

In the public markets, transportation routes and public facilities closed categories, the economic losses are not generated in the previous property of any person or personal injury. Perhaps there is actual damage, but it is in the public domain "does not belong to individuals of all resources" damage.Public facilities damage cases, like cable cases are compensated neither in British nor in Germany. But the French law still deals it arbitrarily. According to our consideration, in the case of traffic jams the compensation for the third party's pure economic loss is not necessary. The reasons are that: indeliberateness, Floodgate, no proximity between the parties, the defendant's inability to foresee the plaintiff's economic losses and such economic losses has less importance to the plaintiff. According to the tort liability constitutions can we also get the same result, because the plaintiff's loss will not have the seriousness and the defendant for more than a fault, because he could not foresee the possibility of the plaintiff's loss, and the causal relationship between the two is difficult to establish.

On the error information, advice and trust in professional services, usually including two typical cases: service and non-negligent misrepresentation.In the case of invalid will, Britain law thinks that the lawyer violates attention obligation, and assumes the compensation responsibility. In Germany, the plaintiff may receive compensation in accordance with the "attached contract of protecting the third party". In France, the plaintiff may win

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

compensation according to term No.1382 prescribed in the French civil code. According to our consideration, the author thinks this loss can obtain compensation. The reasons are: litigation gate can not stand, the two parties have some kind of proximity, no additional duty of care for the surveyor or the lawyer, the plaintiff's loss can be predicted by the surveyor or the lawyer, heritage has some significance for expected beneficiary, the surveyor or the lawyer received remuneration. According to the tort liability constitutions can we also get the same result, because the plaintiff has the legitimacy and seriousness of the damage, the defendant can completety foresee the possibility of the plaintiff's loss, so have a fault, and the fault of the defendant led to the plaintiff's loss, has a causal relationship between the two. At last Chinese WangBaoFu's suing SanXin law firm for property damages dispute is analyzed, and a collusion is made that the verdict is correct, but sufficient reasons are not given for judgment.Untrue statement type of cases is discussed heatedly in every country. British law states with the theory of a duty of care. Through acknowledging professionals' duty of care for the third party in a given scope, it admits a professional tort liability for the third party, make the third party obtain compensation for the damage through the tort law relief. In Germany, the professional's responsibility has come so far from implied contract created by German court or is based on the "attached contract of protecting the third party", and now it is based on liability to the third party of the experts who have made the contract wrongly. While the French law doesn't distinguish between pure economic loss and materialist loss, and therefore the compensation can be obtained. With the elastic tools in use, decision is not predictable. According to our consideration, the author thinks that due to the opposing reasons such as, litigation gate, no immediate proximity and unpredictability, the account should no responsibility for the third party with the exception of intention. But if in special circumstances, the loss is obviously predictable for the accountant, compensation can be established. And if the third party is a small investor, the liability can be established. If the third party is a bank or other party who has the ability to protect its own economic interests, the third party liability usually can not established. Chinese Lantian shares fraud case is analyzed in the end.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Obligatory rights as a legal interest, third party infringement claims arising from loss of pure economic loss, the English, Germany and France will limit the responsibility to deliberate of case, while Germany's more demanding for the more deliberate, calling for "breach gute Sitten." According to considerations and elements to analyze the composition, willful clearly established responsibilities and negligence cases, because of the existence of a third party unknown to the claims, did not foresee the possibility of mistakes can not be established, and the realization of creditor's claim is dependent on many factors could not be considered a direct causal link between the relationship. The final analysis of the foreignservice companies in Taiyuan v. "Shanxi Evening News" huge compensation case that the court's decision is not correct, because they can not identify the defendant with the intentional, can only identify the fault.

The fifth chapter is "review of relevant legislation in china". This chapter firstly analyzes the contract liability in China civil law, the relevant provisions of the tort liability law and the special legislation protecting the pure economic interests. It then analyzes the general terms mode of tort law in France and Germany. In comparison with the general provisions in China's tort law, it tries to propose specific legislations for the pure economic loss compensation.

Article 111 to 116 of Civil law specifies the contract responsibility. The contract law stipulated for the expansion of the power of contract law. It stipulated all-roundly the collateral obligation, established misfeasance liability, but its protection for the interests of third parties is not enough. The tort liability law established the general clause patterns similar to the civil law. It defines the protection objective as protection as "the civil rights and interests". In addition large number of legislations and judicial interpretations involves pure economic loss compensation.

In the mode of general terms of tort law, France adopts the subtraction mode, namely, at the logic starting point, any damage can obtain compensation, unless there is a defense. German adopted the addition mode, namely, at the logic starting point, for only it admits that the right infringement should be protected, and the interests deserving protection can be included in the compensation plan according to other regulations.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

China's liability law adopts the French mode, however, under the coordination of the existing law and the prevailing doctrine, legal practice and other specific circumstances, that although the scope of tort law, including the protection of the rights and interests, but the degree of protection of the interests of the right to be less than absolute. Finally, according to the basic principles of European tort law and the Austrian damage compensation dráft, combining the preceding section, the author thinks pure economic loss compensation problem can be specified as: "Deliberate result of pure economic loss should bear the liability. Pure economic loss caused by negligence, should give special consideration to the following factors: the possibility of an unlimited number of potential plaintiffs, the proximateness between the plaintiff and the defendant, the extra duty of care restrictions on the freedom of conduct, the plaintiff's reasonable reliance, potential plaintiffs' ability to protect themselves in other ways, the plaintiff loss of predictability, the importance of the plaintiff suffered economic losses, whether there is money at stake between both parties. Therefore, pure economic loss caused by negligence, the plaintiff must prove the legitimacy and seriousness of damage, the predictability by defendant to the plaintiff's loss, the plaintiff's loss is a direct result of the defendant's fault."

Key words: Pure economic loss; Economic interests; the exclusionary rule; compensation

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目　录

中文摘要 ..... **I**

ABSTRACT ..... **IX**

前　言 **1**

一、选题理由和意义 1

二、国内外研究现状及趋势 2

三、研究方法 4

第一章　纯粹经济损失的概念界定 **6**

第一节　纯粹经济损失的概念 6

一、纯粹经济损失的定义 6

二、纯粹经济损失的特点 8

三、纯粹经济损失与间接经济损失 9

第二节　纯粹经济损失的性质 12

一、权利与利益 12

二、法益的特征：难以具体特定 13

三、纯粹经济利益的性质——法益 14

第二章　纯粹经济损失的外国法考察 ——以英、德、法三国为例 **15**

第一节　英国法中的纯粹经济损失 ——实用式体系的代表 15

一、普通法的传统 15

二、司法实践 16

三、注意义务的检验标准 21

第二节　德国法中的纯粹经济损失 ——保守式体系的代表 23

一、立法态度 23

二、司法尝试 25

三、契约法的救济 28

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第三节　法国法中的纯粹经济损失 ——放任式体系的代表.....39
一、立法态度.....39
二、司法实践.....41
三、责任控制工具.....45
第四节　纯粹经济损失处理模式的分析比较.....48
一、英国模式分析.....48
二、德国模式分析.....50
三、法国模式分析.....51
四、三种模式的比较.....53
第三章　纯粹经济损失赔偿责任的排除、成立与限制.....54
第一节　区分保护的原因.....54
一、诉讼闸门.....55
二、维护人们的基本行为自由.....57
三、优越法益论据.....58
四、保险因素.....59
五、经济分析的视角.....60
第二节　公认的受保护的经济利益范围.....63
一、合同责任.....63
二、近似于合同关系.....65
三、故意侵权造成的纯粹经济损失.....66
四、间接损失.....66
五、关联损失中的例外.....66
六、转移损失.....67
第三节　纯粹经济损失赔偿责任的限制.....67
一、成立纯粹经济损失赔偿责任时应考虑的因素.....67
二、以既有的侵权责任构成要件合理限制纯粹经济损失的赔偿责任.....72
第四章　纯粹经济损失的类型.....76
第一节　纯粹经济损失的分类.....76

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

一、学理上的分类 76
二、实践中的常见类型 78
第二节 反射损失 80
一、概述 80
二、各国的具体观点 80
三、成立责任的要件分析 85
四、实例分析——重庆电缆案 87
第三节 转移损失 89
一、概述 89
二、各国的具体观点 89
三、成立责任的要件分析 93
第四节 公共市场、运输通道和公用设施的关闭 94
一、概述 94
二、各国的具体观点 95
三、成立责任的要件分析 97
第五节 对错误信息、建议和专业服务的信赖 97
一、概述 97
二、各国的具体观点 98
三、成立责任的要件分析 103
三、实例分析 107
第六节 第三人侵害债权 111
一、概述 111
二、各国的具体观点 112
三、成立责任的要件分析 113
四、实例分析——太原市外企服务公司诉《山西晚报》巨额赔偿案 113
第五章 我国相关立法之检讨 115
第一节 我国现行法中关于纯粹经济损失的规定 115
一、关于纯粹经济损失的合同责任规定 115

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

二、关于纯粹经济损失的侵权责任规定 117
三、保护纯粹经济利益的特别立法 118
第二节 纯粹经济损失的立法建议 122
一、法国和德国侵权行为法一般条款模式分析 122
二、我国侵权责任法的一般条款分析 123
三、对纯粹经济损失的立法建议 127
结 语 131
参考文献 133
攻读博士期间发表的科研成果目录 147

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

前 言

一、选题理由和意义

在过去十年间，法律学者、律师和法官已经逐渐重视纯粹经济损失现象所带来的挑战。今天，纯粹经济损失可能已经成为侵权行为法扩张中的主要问题之一。在一些国家，他和不可控制的、不可预见的且无休止的诉讼洪水联系在一起。这强烈影响了对纯粹经济损失救济的看法，以致明确设计了一些规则，如“排除规则”(the exclusionary rule)、“明线原则”(bright line rule)，来用以关闭诉讼闸门(floodgates)。而在另一些国家，这个问题好象被忽视，纯粹经济损失看起来和其他损失一样对待。这种反差本身就证明了在纯粹经济利益的保护问题上进行比较是正当的。但是同样重要的是，用比较法来研究允许或驳回纯粹经济损失请求的法律理由是否是令人信服的问题。对于纯粹经济损失责任可能存在的内容不确定性的害怕，是否有理由？如果这是问题所在，那么排除纯粹经济损失的赔偿请求是否就是一个适当的方法？第一眼看上去，对于纯粹经济利益完全不予保护同全部保护一样，是不效率的也是不公平的。在这两条路径之间，难道没有可以接受的中间解决方案吗？

纯粹经济损失的可赔性是众多问题中的前沿问题：侵权责任可扩张到什么范围而又不至于给个人行为增加过重的负担（或者正如某些人所希望的那样，侵权规则在多大程度上与法律制度的市场化取向一致？）21 世纪的侵权法应该如何解决这个问题？作为政策问题，纯粹经济损失赔偿是否主要隶属于合同法领域？然而必须承认，在许多法律体制中，对于纯粹经济利益完全不予保护是个过时的路径，而对于那些不平常的案件提供保护也被证实是非常困难的。在这些法制体系中，纯粹经济利益是不被侵权行为法所保护的。所以政策决定需要保护特殊的纯粹经济利益，这就促进了现存学说和概念在侵权法范围内外的延伸。然而，这样的延伸给法律提出了挑战，并且不可避免的带来一个问题：在严格法律理由的背后，什么才是真正的思考。

纯粹经济损失问题虽然具有一定的前沿性，但决不是侵权责任法上的一个孤立

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

或者标新立异而无实际意义的课题，事实上，它是社会发展到一定程度因应人类法律实践而提出的重要课题。纯粹经济损失问题应该是民法上的一个普遍性和基本性的问题，对其进行研究具有重要的实践意义和理论意义。宏观而言，纯粹经济损失问题，跨越私法边界，尤其横跨侵权责任法和合同法的边界，其解决方式，在一定程度上有可能决定未来侵权责任法和合同法的区别与走向。在我国现在正在进行民事立法的进程中，深入探讨纯粹经济损失问题，具有重要的理论意义。微观而言，探讨解决纯粹经济损失问题，对涉及纯粹经济损失的具体个案进行深入研究，为法院处理现实生活中出现的如电缆案件、遗嘱案件、专家不实陈述、第三人侵害债权等纯粹经济损失案例，提供学理上的意见，对于司法实践也具有很好的参考价值。

二、国内外研究现状及趋势

在20世纪80年代以后，普通法和大陆法中才开始流行纯粹经济损失这一概念，在此之前，很多侵权法学者并不熟悉这个概念，因此纯粹经济损失理论在20世纪80年代仍处于起步阶段。即使到目前为止，纯粹经济损失理论仍然处于发展阶段，还没有达到成熟阶段。虽然纯粹经济损失问题，在侵权责任法的研究中，属于一个比较新还没有成熟的领域，却已成为研究中的一个重要的热点问题。最近几年，更是成为比较法研究中的热门课题。尤其在欧洲，纯粹经济损失这个最初看起来枯燥且技术化的命题，成为法学界探讨研究最多的命题之一，因此形成了对于此问题的丰富文献。

英国的Banakas教授在1989年出版了《对纯粹经济损失的侵权责任》一书，并且主持编写了英国比较法论丛第16卷《对纯粹经济损失的民事责任》；1993年，欧洲学者在意大利特兰托大学发起了“欧洲私法共同核心”的研究项目，主持人为Rudolf B. Schlesinger教授，目的在于通过案例的研究，来比较分析欧盟各国在实践中如何处理特定的法律问题。“纯粹经济损失”是其中的一个子课题，由意大利里雅斯特大学毛罗·布萨尼（Mauro Bussani）教授和美国杜兰大学弗农·瓦伦丁·帕尔默（Vernon Valentine Palmer）教授主持，共有22名学者参与，研究时间从1996年至2001年历时6年。该项研究以司法实践中经常出现的典型案例为基础设想了20个案件，分别是：电缆案件Ⅰ——停电，电缆案件Ⅱ——工厂停工，电缆案件Ⅲ——日常工作者，康复中的雇员，意大利全明星队的安魂曲，受感染的奶牛，疏忽的建筑师，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

被取消的航行，放映室里的火灾，尽职的妻子，艺术家的错误，双重销售，分包人的责任，糟糕的法律服务，被关闭的高速公路——时间的价值，堵塞商业大厦入口的卡车，审计人的责任，不当的工作推荐函，违反承诺和匿名电话。其最终的研究成果为剑桥大学出版社（Cambridge University Press）于2003年4月出版的《欧洲法中的纯粹经济损失（Pure Economic Loss in Europe）》一书；在1998年国际比较法学会布里斯托尔会议上，12个国家的代表也对纯粹经济损失问题进行了讨论；欧洲侵权和保险法中心也对纯粹经济损失问题进行立项研究，于2002年10月22日在德国慕尼黑专门召开了关于纯粹经济损失问题的研讨会，其一部分成果为2004年Willem H. van Boom、Helmut Koziol、Christian A. Witting主持编写的《纯粹经济损失（Pure Economic Loss）》一书。欧洲学者们对于纯粹经济损失这个问题倾注了如此多的热情，很大原因是着眼于编撰未来欧洲统一民法典的目标。

欧洲法学界对于纯粹经济损失问题进行深入的研究和探讨，与此相反，我国民法学界似乎缺乏响应。我国学者最早对纯粹经济损失问题进行专门探讨的是张民安教授，其在 2002 年 12 月出版的《民商法论丛》第 25 卷上发表的《因侵犯他人纯经济损失而承担的过失侵权责任》一文，共 4 万多字。2004 年 7 月，李昊博士出版的《纯经济上损失赔偿制度研究》一书，共 18 万字，为我国第一部关于纯粹经济损失的专著。2005 年法律出版社出版由张小义、钟洪明翻译的《欧洲法中的纯粹经济损失》一书，另外张新宝教授于 2001 翻译出版的《欧洲比较侵权行为法》中也有大量的关于纯粹经济损失的论述。还有很多学者发表了关于纯粹经济损失的论文，如张湘兰、朱强在《时代法学》2004 年第 5 期发表论文《论纯经济损失的侵权责任——从欧洲比较法展开》，朱广新在《当代法学》2006 年第 5 期发表《论纯粹经济上损失的规范模式——我国侵权行为法对纯粹经济上损失的规范样式》，张新宝、张小义在《法学杂志》2007 年第 4 期上发表《论纯粹经济损失的几个基本问题》，黄莉萍、朱娟在《广西社会科学》2007 年第 10 期发表《侵权中纯经济损失保护模式的比较探讨》，徐海燕、朱辰昊在《甘肃社会科学》2008 年第 3 期发表《纯粹经济损失赔偿制度研究——兼论证券市场中介机构不实陈述的民事责任》，梅夏英在《中州学刊》2009 年第 4 期发表《侵权法一般条款与纯粹经济损失的责任限制》等等。此外还有一些学位论文，但大多是从比较法的观点，且比较关注其概念和规范模式，对于其背后深层次的理论问题以及赔偿标准的界定，则关注不够。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

杨立新教授的《侵权责任法草案建议稿》第58条规定："以故意加害他人为目的，致使他人遭受与身体伤害或者财产损害不相关联的经济损失，应当承担相应的侵权责任。"第171条规定："纯粹经济利益的损失赔偿范围，应该以实际损失计算，但不得超过加害人在实施侵权行为时应当预见的损失范围。" 在杨立新教授的建议稿说明中写道："这样规定到底准确不准确，还有待于我们进一步的研究，但是我们还是提出这样一种想法。"而在最近颁布的《侵权责任法》中则对纯粹经济损失问题未做具体规定，这也说明，纯粹经济损失的研究在我国还远未达到成熟的地步，还有进一步研究的必要。

三、研究方法

纯粹经济损失涉及的问题庞杂，现实生活面上的表现形态多样，不但是民法学研究中的新鲜领域，而且呈前沿性、交叉性、复杂性等理论特性，也是民法学中的一个极具挑战性的研究课题。因此本文的分析必然要采取多元化的研究方法，而其中最重要的方法有：

（一）比较研究方法

各国法律体系在其漫长的发展过程中，必然与其国家的政治、经济、文化、风俗、伦理习惯等发生密切的联系，乃至如历史法学派所言，法律为民族精神的体现。然而法律所调整的具体社会生活关系却不尽是民族性的表现，而于各国有着一定的共同性，这便使得各国相应的法律解决方法有着共通之处。外国的立法例及判例学说不仅可于各国修订法律之际为参考，而且亦是法官解释法律和填补法律漏洞的重要工具。于纯粹经济损失这一对我国而言尚属新兴的法律概念，如何借鉴外国立法、司法已有之成例，亦是一个非常值得讨论的问题。惟于比较法研究中应注重"功能性原则"的问题，即比较法之研究不应具体纠缠于不同国家的法律概念体系，而应于各法律概念体系之后去发现其是如何进行利益衡量和政策判断以达到解决具体法律问题之功效的，因为法律尤其是私法所注重的应是纠纷解决之道而不仅仅是法律概念和规范之比较。

（二）类型化的研究方法

纯粹经济损失是一涉猎范围很广的损害类型，其发生背景、场合不同，所引起的利益衡量和政策判断因素便会有所不同，解决方法也会有所不同，难以完全以一

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

抽象的原则来概括，故研究中不得不将之类型化，分别探讨各种类型背后的政策因素和相应的解决办法，以达到解决实际问题的目的。而且纯粹经济损失乃英美法上常见的概念，英美法在解决该问题时多采判例的形式，而不同法官在作出判例的过程中必然会采取不同的实质推理过程，从而使得一致的抽象原则难以得出。由于类型化的研究方法下，将相类似的判例归总在一起，发现其判例之中的异同，或可归结出该类型下的一般解决方法，以解决难以概括出抽象的一般原则的不利，亦可发现法律发展进化的脉络。而这种类型化的研究方法亦有助于法官理清法律的适用，并限缩其过度的自由裁量权。但类型是开放的而不是封闭的，是具有弹性的而不是一成不变的，随着法律实践的丰富，类型也存在创设发展的可能，这也是法律能不断进化永葆生机的源泉。

（三）经济分析方法

现代侵权法的研究受到经济分析方法的深刻影响。经济分析方法作为法律分析中的重要思考工具和价值判断工具，对于法律规范的制定、适用、解释和具体案件的裁判具有重要的意义。运用经济学上的分析工具，探讨在何种情形下，应对纯粹经济损失予以赔偿，何种情形不应该对纯粹经济损失予以赔偿，是国外侵权法及经济学学者较为热衷的方法。法律的经济分析方法，在人身损害、物的有形损害与纯粹经济损失的情形，具有不同的意义。因为对于前者而言，保护被害人的权利即为目的，因此对过失侵权责任进行损益分析，不具有重要意义。而对后者而言，对于纯粹经济利益保护的必要性及可行性，是非常适用于以经济分析的方法进行研究。虽然法院因为欠缺足够的资讯，无法对案件进行经济分析，以至于比较关心判决的结果是否公平与合理，而不注意较广泛的利他性计算，但是不可避免地，经济现实会影响“公平、正义与合理”的认定。从而本文亦运用经济分析方法，对纯粹经济损失问题的研究，加以深入探讨。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章　纯粹经济损失的概念界定

第一节　纯粹经济损失的概念

一、纯粹经济损失的定义

关于纯粹经济损失（或者是关于纯粹经济利益）的确切内容没有达成共识，这并不令人吃惊，因为对待这个独特的损失种类，没有共同的方法。而且，纯粹经济损失现象覆盖了各种不同的情况。但是也有一些通常承认的分界线。纯粹经济损失通常同由死亡或伤害引起的损失或者有形实物的损害形成对比。

英格兰、爱尔兰、英格兰、瑞典以及荷兰学者通常将纯粹经济损失定义为与人身或有形物的形体完整性（physical integrity of a person or a tangible thing）所受之侵害并无直接联系的任何损失。德国、奥地利、葡萄牙和荷兰的学者则倾向于将纯粹经济损失定义为与权利所受之侵害并无直接联系的任何损失，这样就将其他国家的许多典型的纯粹经济损失排除在外。而法国、比利时、卢森堡以及西班牙的一般律师甚至就连纯粹经济损失的概念也不了解：纯粹经济损失对他们而言是一个完全陌生的概念。[①]

从立法层面上对纯粹经济损失概念进行界定的只有1972年6月2日颁布的《瑞典赔偿法》，该法第二条规定："根据本法，纯粹经济损失是一种在任何方面与人身伤害和财产损害都没有关联的经济损失。"除此以外，立法上很少对这一概念有过完整而清晰的厘定，[②]只是在各种学术著作和司法判例中可以发现一些介绍。下面就各国权威学者对纯粹经济损失的界定进行介绍：

Markesinis和Deakin将纯粹经济损失定义为，纯粹经济损失在性质上是一种纯粹的经济损失或者金钱损失，也就是说，它与原告遭受的人身或者财产（有形）损害没有关系。[③]Koziol认为纯粹经济损失是一个不产生于对人（生命、身体、健康、

---

① [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，吴越等译，法律出版社2007年版，第25-26页。

② 《奥地利损害赔偿法草案》第1293条第3款、第1325条第1款和第1489条提及了"纯粹财产利益"或"纯粹财产损害"，《欧洲侵权法原则》第2：102条提及了纯粹经济利益，但它们都未对这些概念作出界定。

③ B.S.Markesinis and S.F.Deakin, Tort Law, 4th ed., Clarendon Press, Oxford, 1999, p.88.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

自由或其他人格权）的伤害或对财产（包括有形财产和无形财产）损害的损失。[①]

我国台湾学者潘维大教授则提出“纯粹经济上损失，非人身之损害，亦非财产遭受直接之损害，而系指财产上所遭受之不利益。”[②]王泽鉴教授则认为，“所谓纯粹经济上损失，系指被害人直接遭受财产上不利益，而非因人身或物被侵害而发生，例如证券公司、KTV 或餐厅不能营业，工厂停工。”[③]“所谓纯粹经济上损失，指其营业上损失非因权利被侵权而发生。”[④]而王利明教授则认为，“纯粹经济损失是指行为人的行为给他人造成的人身伤害和有形财产损害之外的经济损失。”[⑤]李昊博士则认为，“纯经济上损失是被害人所直接遭受的经济上的不利益或金钱上的损失，它并非是因被害人的人身或有形财产遭受损害而间接引起的，或者说，它并非是被害人所享有的人身权或物权遭受侵犯而间接引起的。”[⑥]

冯·巴尔教授在考察“纯粹经济损失”的定义时，指出：“对于什么是‘纯粹经济损失’各国规定一直都有很大区别，但从中仍可以总结出两个主要流派：其一是，所谓‘纯粹经济损失’是指那些不依赖于物的损坏或者身体及健康损害而发生的损失；其二是，非作为权利或受到保护的利益侵害结果存在的损失。”[⑦]两种方法的共同点是，即便存在人身伤害或财产损失，也不是发生在权利人方面而是其他人。区别是，第一种方法重在对纯粹经济损失的事实描述，突出了该损失的物理性质，即与人身损害或物的有形损害无关，所以也可称为损害定位方法，多为英美法系国家所采用。第二种方法揭示了纯粹经济损失的法律内涵，是一种制度性描述，正如巴尔教授所说，“从结果上看，也仅后者才在权利侵害和纯粹经济损失之间建立了直接的联系”，[⑧]所以也可称为利益定位方法，是德国法所采用的方式。

上述几种观点对纯粹经济损失的概念界定可以说是大同小异，基本上认为纯粹经济损失是受害人所直接遭受的金钱上的损害，与被害人的权利损害或人身损害及

---

① Helmut Koziol, “Compensation for Pure Economic Loss from a Continental Lawyer’s Perspective”, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.141.

② 潘维大：《中美侵权行为法中不实表示民事侵权责任之比较》，瑞兴图书公司 1995 年版，第 174 页。

③ 王泽鉴：《民法学说与判例研究》（修订版）第七册，中国政法大学出版社 2005 年版，第 68-69 页。

④ 王泽鉴：《民法学说与判例研究》（修订版）第八册，中国政法大学出版社 2005 年版，第 184 页。

⑤ 王利明：《侵权行为法研究》（上卷），中国人民大学出版社 2004 年版，第 368 页。

⑥ 李昊：《纯经济上损失赔偿制度研究》，北京大学出版社 2004 年版，第 7 页。

⑦ [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔著，焦美华译：《欧洲比较侵权行为法》（下卷），法律出版社 2001 年版，第 33-34 页。

⑧ [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔著，焦美华译：《欧洲比较侵权行为法》（下卷），法律出版社 2001 年版，第 33-34 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

财产的有形损害无关，因此，我们可以将纯粹经济损失定义为：纯粹经济损失是被害人所直接遭受的经济上的不利益或金钱上的损失，其并非是作为被害人的人身或有形财产遭受损害的结果而发生的经济损失。

二、纯粹经济损失的特点

综观以上定义，我们可以得出纯粹经济损失的几个特点：

（一）纯粹性，即独立性

“纯粹”是纯粹经济损失这个概念中最为核心的词汇，是一个关键的限定词，它表明了问题的特质，指在损失中，没有掺杂任何人身损害、物的有形损害，是纯粹的经济利益或金钱上的损失。因此，纯粹经济损失是“一种在任何方面与人身伤害和财产损害都没有关系的经济损失。”[①]，具有独立性。然而在现实世界中，每一种利益几乎都以一种无限多的方式相互连接。一种损失不与任何身体或财产的有形损害相联系，不可能是现实世界中的实际状况，而只能是概念上的截取。父亲去世，其子女将因此而失去抚养费；丈夫受伤，妻子为看护丈夫而失去工作。在这些情形中，子女和妻子的损失，在事实层面上仍然是来源于初始受害人即第一受害人的人身伤害。因此，这里所切断的是不同的民事主体之间的人身或者财产联系，即纯粹经济损失是不因“受害人（原告，主张损害赔偿之人）”的身体或者财产受到损害而发生的损失。因此，虽然父亲的人身受到伤害，子女因此发生抚养费的损失，但该损失并不是因为子女自己的人身受到伤害而导致的，所以在此意义上子女遭受的抚养费损失仍是是“纯粹的”或“独立的”经济损失。[②]

（二）经济性，即金钱性

“经济”一词，是纯粹经济损失概念的另一个关键限定词，这个词表达了纯粹经济损失问题的目的和基本内容，也即当事人遭受的是经济利益上的损失，即金钱上的损失。所谓经济利益，是指遭受损害时能以一定量的金钱完全填补的利益，即能够完全恢复原状，而使其利益恢复到没有发生任何损害时的状态。当一方当事人的经济利益受到损害，而他因此得到的赔偿的数额，如果能够准确地反映其因遭受损害而导致的价值丧失时，则他可能不会有受到损失的感觉。如果当事人感觉，即

---

① 1972 年《瑞典赔偿法》第 2 条。

② 张新宝、张小义：《论纯粹经济损失的几个基本问题》，载《法学杂志》2007 年第 4 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

便用相当数额的金钱进行赔偿仍不能使其满足时，则其所受的损害就不纯粹是经济上的。经济利益通常可以用客观的价值来计算，如果某项利益对于其所有者而言，还具有主观价值，那么此利益就不仅仅是经济上的利益。[①] 经济利益和经济损失在市场经济的意义下，通常可以准确计算，经济利益的本质即金钱财富。因此，所有的纯粹经济损失案件都有一个共同的特点，即损失的是金钱或金钱财富，使受害人整体财产减少，而非其他非金钱损失。

（三）损失性，即不利益性

“损失”为纯粹经济损失概念中的被限定词汇，是一个本质词汇。所谓损失，是指（财产的）不利益，有时表现为现有财富的减少，有时表现为应当增加而未增加，通常包括所受损害和所失利益。纯粹经济损失是受害人因经济利益受到侵害而导致的现有财产的减少，或应该增加的财产而未得到增加，是加诸于被害人整体财产上的一种不利益，而非针对某项具体的有形财产或人身利益。这种损失通常表现为受害人整体财产的改变，可以根据被害人在侵权行为发生前后的财产差额来计算，即被害人会感到财富及金钱的减少。

三、纯粹经济损失与间接经济损失

在完全承认纯粹经济损失术语的国家基本上是从反面来界定其含义的，即纯粹经济损失是原告的人身或财产事先未受到损害的情况下发生的损害。在此，“纯粹”一词起到核心的作用，因为若经济损失即便是与原告最为轻微的人身或财产损害存在联系（假设所有其他责任要件均符合），则这种损失就叫做间接经济损失。此时，所有损失均可获得赔偿。间接经济损失之所以可获得赔偿，是因为它以事先存在实际损害为前提，而纯粹经济损失只是侵害了受害人的可得利益，除此之外，原告并无其他任何损失。瑞典 1972 年的侵权法第 2 条以如下表述准确界定了这一概念：“本法中，‘纯粹经济损失’是指与任何人的人身伤害或财产损害均无联系的经济损失。”类似的定义在英格兰和德国似乎也很流行。[②]

由此可见，纯粹经济损失与间接经济损失虽然同为经济损失，但其主要区别在于损失是否与受害人的财产损害或者人身损害相联系，如果受害人存在初始的财产

[①] 张国宏：《纯粹经济损失研究》，中国人民大学 2006 年博士学位论文。

[②] [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，吴越等译，法律出版社 2007 年版，第 104-105 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

损害或者人身损害，那么此后发生的损失就属于间接经济损失，如果经济损失的发生与受害人初始的财产损害或人身损害无关或者受害人根本就没有任何财产损害或人身损害，则属于纯粹经济损失。

然而，纯粹经济损失和间接经济损失的区分具有高度的技术性，或许甚至是人为的。这来自于责任排除规则的两个技术特征。第一个技术特征是“间接经济损失”只描述同一财产集合（原告）内部的因果关系，不同财产集合之间的所有因果关系均被运用技术手段排除。换言之，当金钱损失被描述为“纯粹”而不是“间接”时，则任何一个财产集合均被视为因果关系的切断因素。例如，对作为家庭经济支柱的父亲的伤害会对受其抚养的子女产生直接且可预见的影响，但我们的界定排除了这种因果关系。子女失去抚养不能叫做“间接”经济损失，尽管该损失显然是因其父亲人身受到伤害而产生的“后果”。因此，使用该术语的法律制度将经济损失视为独立的现象，就如同原告的财产是一个与其他所有人的财产切断联系的独立世界。但同样显而易见的是，这种逻辑与经济现实和社会现实均不符。在现实世界里，“实际上种类无限的利益均以几乎无限的方式相互联系着”。[①]经济主体的事务高度依存，它们之间被通过合同、财产和其他各种法定利益联结在一起的权利义务之网相互联结着。在这些情形下，人们可合理预见到，对一项利益的损害会影响其他利益。事实上，已有人正确指出，“只要最初损害通过连锁反应产生的后果来自这种利益的相互依存，就不能将这种后果明确视为特殊的或者不可预见的后果”。[②]但由于责任排除规则对因果关系进行“个别化”的处理，由此导致“间接”经济损失的范围被人为地缩小了，而“纯粹”经济损失的范围则被相应地扩大了。第二个技术特征是，尽管所有采用责任排除规则的国家“一致”认为“间接”经济损失可以得到赔偿，但实际上他们对该原则在具体案件中的适用却是不同的。既然间接经济损失是一个最终结果受政策考量影响的因果概念，因此不国家对此作出不同解释就不足为奇了。某些国家的法院创设的规则要求事先存在的实际损失与因此而产生的经济损失之间存在较为严格的联系。根据该规则，法院会认定原告的损失是“纯粹”经济损失（因而不能得到赔偿），因为该损失与原告事先受到的实际损害的联系不够充分。而其他国家的法院则可能采用较为宽松的概念，它们可能将同一损失视为“间

[①] Benson, “The Basis for Excluding Liability for Economic Loss in Tort Law”, D. G. Owen, The Philosophical Foundations of Tort Law (1995), at p.431.

[②] Benson, “The Basis for Excluding Liability for Economic Loss in Tort Law”, D. G. Owen, The Philosophical Foundations of Tort Law (1995), at p.431.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

接”经济损失，因此认定该损失可获得赔偿。[①]

英国上议院 McFarlane v Tayside Health Board 案的判决是关于间接损失赔偿范围的一个案例。[②]被告诊所未能正确告知原告，在结扎手术后输精管再造的可能性，由此导致孩子的出生。上议院承认（不想要的）孩子的出生是过失法中的损害。这是实质损害的一个类型。除了赔偿物质损失及伴随的疼痛和痛苦，原告还被允许赔偿额外的医疗费用、母亲和孩子的衣服以及收入损失。如果不是作为实质损害的立即或直接后果的经济损失，在英国只有以 Hedley Byrne 案的原则为依据提出的请求才是可以获赔的。因此该案中，缺乏被告自愿承担责任，而不能认定要承担赔偿抚养孩子至成年的费用的责任。[③]这些费用被认为离实质损害太遥远，而只有在更宽松的基础上才能得到赔偿。[④]

有关间接损失的规则适用的严格性，在下面一个涉及连续工业过程的案件中是很明显的。在著名的 Spartan Steel v. Martin 案件中，由于被告的过失导致电力被切断，原告被迫停止冶炼钢铁。原告正处于生产中的已经溶化的钢材无法持续保持溶化状态，因此完全报废。原告请求被告赔偿：（1）锅炉中的铁块受损，减少价值 368 镑。（2）此等铁块若顺利炼成，可以获利 400 镑。（3）工厂因停电不能营业，损失收入 1767 镑。[⑤]电缆的切断致使原告已溶化钢材报废，这和电力被切断有直接的因果关系，为实质损害，因此，法院支持了原告的第一个诉讼请求。此外，由于这部分钢材的报废，致使原告不能从这部分钢材上获利，这个损失是直接来自于对报废钢材的实质侵害，因此为间接经济损失，属于可赔偿范围，因而对于原告的第二个诉讼请求也予以支持。但是，被告的行为对于原告其他因停电而不能生产的钢材却没有物理损害，因此此类损失属于纯粹经济损失，即与原告所受的实质损害无关，因此法院否决了原告的第三个诉讼请求。[⑥]这个案件也充分说明了纯粹经济损失与

---

① [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，吴越等译，法律出版社 2007 年版，第 105-106 页。

② [2000]2 AC 59. 然而，注意其中一个法官 Milltee 拒绝将损害性质认定为是间接或纯粹经济性的。但这不是上议院任何其他法官的观点。

③ ‘医生承担了避免怀孕的注意义务：不必然包括避免孩子出生后被家庭接受后产生的抚养费用的义务’：[2000]2 AC 59，76.

④ Christian Witting, Compensation for Pure Economic Loss from a Common Lawyer's Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.115-116.

⑤ 王泽鉴：《民法学说与判例研究》（修订版）第七册，中国政法大学出版社 2005 年版，第 76 页。

⑥ Christian Witting, Compensation for Pure Economic Loss from a Common Lawyer's Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.116.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

间接经济损失的区别。然而如果这个案件发生在德国，则所有的损失都可以获得赔偿，因为德国也将第三个诉讼请求视为“间接”经济损失而非“纯粹”经济损失，认为是一种寄生性的经济损失，认为生产损失和财产损害之间有因果关系，而不象英国法庭那样对这种因果关系的性质做出极高的要求。这也说明了间接经济损失是一个最终结果受政策考量影响的因果概念。

第二节　纯粹经济损失的性质

一、权利与利益

关于“权利”的本质或概念，学说上众说纷纭，有“意志说”、“利益说”、“从属控制说”、“特权说”等，这些学说见解之间，并非完全对立，而只是观察的角度或重点不同而已，有的强调权利的“内容”，有的强调权利的“主体”对权利“客体”的某种关系，也有的强调权利人可以“拘束”义务人的“正当性”等。通说采用“法力说”，认为“权利为得享受特定利益之法律上之力”。根据此定义，“特定利益”与“法律之力”为权利概念的两个要素，其中，“特定利益”的享受，为权利的内容或要素，权利的本质即是一种“特定利益”。[①]

所谓利益，是一种事实状态，其范围广泛，种类繁多，内容也复杂多样。最广义的利益，包括任何群体社会生活中可以满足需要的各种生活资源。其中，有些利益不具有正当性或保护价值，不属于私法体系所保护的利益，如不法利益或不正当利益（如制造贩卖毒品的收入所得）、反射利益（如邻地广种草木因而享受的视野景观或清新空气的利益）；有些利益则是正当的、值得保护的利益，属于私法体系所应该保护的利益，为“广义的利益”。

广义的利益中，有些利益已经发展成熟，其存在也基本无争议，而且其主体、内容或范围都可以具体特定，因此根据时代变迁或社会发展的需要，而逐步独立发展成为一种“类型”，并且经过现存法律体系承认，赋予其特定名称，则成为一种“权利”，如生命权、所有权等。至于其他利益，则因为还没有发展到成熟的阶段，其是否存在还有疑问，其主体、内容及客体也难以具体特定，没有在时代变迁和社

---

① 陈忠五：《论契约责任与侵权责任的保护客体：“权利”与“利益”区别正当性的再反省》，载《国立台湾大学法学论丛》第36卷第3期，国立台湾大学法律学院出版社2007年版，第126-127页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

会发展过程中，发展成为独立的一种类型，而现存法律体系也并未对其予以承认，没有赋予其特定的名称，仍只是维持“单纯利益”的地位，是“未权利化的利益”或“狭义的利益”，也称为法益。

因此，最广义的利益，只是一种未经既存法律体系予以过滤筛选或认识评价的“事实状态”。此种事实状态一旦经过既存法律体系的筛选承认后，其中有些利益应当给予负面否定评价，则法律不予以保护，而有些利益则应该给予正面肯定评价，则法律应该予以保护。后一种应该由法律予以保护的利益，则为广义的利益，包括已经权利化的利益（即权利）和未经权利化的利益（狭义的利益，也即法益）。[①]

二、法益的特征：难以具体特定

在价值位阶上，法益不能与生命、身体、健康、自由或所有权等权利等同视之，侵权责任法一般优先保护人身权，其次保护所有权等物权，仅在更严格的要件或某些例外的情形下，才保护各种法益。权利与法益在价值位阶上的不同，不在于权利本质上是不是一种利益，而在于权利与法益内容上的区别，此种区别也反映了权利与法益在性质上的不同。

如前所述，某种“利益”之所以“权利化”，是因为该种利益已经发展成熟稳定，其存在没有争议，其主体、内容、范围也可以具体特定，并且因为时代变迁或社会发展需要而成为一种独立类型，经过现存的法律体系承认，赋予特定名称后，而变为“权利”。相比较而言，某种利益之所以“尚未权利化”，是因为该利益还没有发展到稳定成熟地步，其是否存在仍有疑义，并且其主体、内容或范围难以具体特定，因此欠缺具体特定的类型化特征，在时代变迁或社会发展过程中没有发展成为一种独立类型，因此既存法律体系对其既未予以承认，也没有赋予其特定的名称，而只是维持“单纯利益”的地位。

因此，权利的特性在于：其存在、主体、内容、范围等，可以具体特定。法益的特性在于：其存在、主体、内容、范围等，难以具体特定。权利与法益的区别，在于此特性上的不同。生命权、健康权、自由权、所有权等权利之所以毫无疑问地为一种“权利”，即在于该等权利的存在、权利主体为何人、权利内容为什么，权

[①] 陈忠五：《论契约责任与侵权责任的保护客体：“权利”与“利益”区别正当性的再反省》，载《国立台湾大学法学论丛》第36卷第3期，国立台湾大学法律学院出版社2007年版，第127页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

利范围如何等，可以具体特定，具有社会公开性，一般人很容易从外界予以知悉或预见。至于各种法益，其之所以仅被认定为是一种“单纯利益”，即在于该等利益是否存在、利益主体为何人、利益内容为什么、利益范围如何等，难以具体特定，欠缺社会公开性，一般人从外界很难予以知悉或预见。[①]如债权作为一种存在于特定当事人之间的请求权，具有相对性，不具有社会公开性，第三人从外界很难知悉双方当事人之间的债权是否存在、主体、内容及范围如何。因此，债权在性质上比较接近法益，第三人侵害债权所导致的侵权责任，一般只在更严格的责任要件上成立。

三、纯粹经济利益的性质——法益

纯粹经济损失作为一种非作为权利或受到保护的利益侵害结果而存在的损失，因此纯粹经济利益本质上也是一种法益，而非权利。“法益者，法律上主体得享有经法律消极承认之特定生活资源。”[②]因此，法益是尚未由法律明文规定的利益，而纯粹经济利益就属于这样一种法益，是法律尚未明文规定的利益，是未被权利化的利益。纯粹经济利益具有法益的特征：难以具体特定，因为纯粹经济利益是否存在、主体、内容和范围都不具有特定性，外人很难知悉。

纯粹经济利益之所以仍未被权利化，主要是因为纯粹经济利益还没有发展到成熟稳定的阶段，对于其是否存在仍有疑义，而且其主体、具体内容及客体范围也仍然难以具体确定，因而欠缺具体特定的类型化特征，既存的法律体系并未对其予以承认，也没有赋予其特定的名称，所以仍为一种“单纯利益”，性质上属于一种法益。这也说明为什么纯粹经济利益的保护是一个需要研究的课题，因为其为法益而非权利之性质，也导致了纯粹经济损失在很多国家不能得到赔偿，特别是在侵权责任一般条款采“权利清单”的国家。

---

① 陈忠五：《论契约责任与侵权责任的保护客体：“权利”与“利益”区别正当性的再反省》，载《国立台湾大学法学论丛》第36卷第3期，国立台湾大学法律学院出版社2007年版，第152页。

② 曾世雄：《民法总则之现在与未来》，中国政法大学出版社2001年版，第62页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章　纯粹经济损失的外国法考察
——以英、德、法三国为例

第一节　英国法中的纯粹经济损失
——实用式体系的代表

一、普通法的传统

在传统的普通法中，过失责任还不是一个一般性的概念，对过失责任的限制主要是通过相对性原则。相对性原则最初是由英国 1842 年的 Winterbottom v. Wright 案[①]所确立，在该案中，原告承租了被告的马车，然而因被告对马车疏于维修保养，导致原告的受雇人在驾驶马车时，因为马车的瑕疵而受到了人身伤害。由于原告和被告之间没有合同关系，因此原告不能对被告主张合同责任；又因为以前的判例在认定被告对原告是否有注意义务时，从来没有以被告对第三人所承担的合同义务作为依据，因此法院亦认定原告不得对被告主张侵权责任。该案法官认为："当事人之间并无合同关系，如果原告可以起诉，那么每一个行人，甚至任何一个经过该马路的人，都可以因为马车翻覆受到伤害而提起诉讼请求赔偿。除非我们将合同权利的行使限于合同当事人之间，否则将会不断地发生最荒谬的结果。"此判例成为过失侵权法上的重要原则：过失侵权责任只成立于被告对原告承担注意义务时，而是否存在注意义务，则必须从当事人间是否具有合同关系来加以推断。[②]

在 1889 年的 Derry v. Peek 案[③]中，被告即 A 公司的董事，在公开发行公司营业计划书中声明，该公司有权以蒸汽或机械推进器代替马匹行驶电车。原告根据此项声明而购买了 A 公司的股票，不料该权利的申请被帝国商业部驳回，A 公司因而停业，导致原告受到经济损失。上诉法院认为被告的行为构成诈欺，但贵族院认为，因为被告确实相信自己的公司将会享有该项权利，所以被告是出于过失而非故意，

① [1842]10 M. & W. 109，152 Eng. Rep. 402。
② 邱琦：《纯粹经济上损失之研究》，国立台湾大学法律学研究所 2002 年博士论文，第 96 页。
③ [1889] 14 App. Cas. 337。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

因此驳回原告的诉讼请求。后来法院多次援引此判例，认为是确立了因过失不当陈述所造成的经济损失不得请求赔偿的原则。[①]

到了20世纪30年代，终于突破相对性原则的束缚。在Donoghue v. Stevenson案中，原告Donoghue女士在同她的朋友在酒吧里约会时，要了一瓶姜汁啤酒，当她快要喝完的时候，在啤酒瓶中发现有一只腐烂的蜗牛，Donoghue女士因此感到极不舒服并引起了呕吐等身体不适，于是她以过失侵权起诉了啤酒的生产商。法官Lord Atkin认为被告对原告负有注意义务，因此应当承担过失侵权责任，并提出英国侵权法上最著名的判决理由，提出以可预见性（邻居原则）作为认定注意义务成立的标准："当你'必须爱你的邻居'的道德规范，成为法律规定时，你就不可以伤害你的邻居；当法律询问：'谁是我的邻居'时，邻居的范围必须有所限制。当你可以合理地预见到你的作为或不作为，将伤害到邻居时，就必须采取合理的注意措施，以避免损害结果的发生。那么，到底在法律上，谁是我的邻居呢？答案是——当我在为系争作为或不作为时，可合理地预见将因我的行为，而直接受影响之所有与我关系密切的人，均是我的邻居。"然而后来的法院判例对邻居原则采取了限制性解释，认为此规则只能适用于人身损害或财产损害，而不能适用于纯粹经济损失的情形。[②]

二、司法实践

（一）责任排除规则的突破——Hedley Byrne & Co Ltd. v. Heller & Partners Ltd.案

赫德利•伯恩（Hedley Byrne）案是英国法上关于过失不实陈述的最重要的判例，同时也是第一个肯定因过失导致的纯粹经济损失能够请求赔偿的判例。在该案中，原告Hedley Byrne是一家广告代理公司，与Easipower Ltd.公司签订合同，在合同中约定由原告为Easipower Ltd.公司策划一次广告宣传活动，然而Hedley Byrne将为此承担比较大的风险，为了确定对方的资信情况，于是原告Hedley Byrne委请自己的开户行来询问Easipower Ltd.公司的信用情况，其开户行写信给Easipower Ltd.公司的开户行Heller & Partners Ltd.询问Easipower Ltd.公司的资产及信用状况，

① 邱琦：《纯粹经济上损失之研究》，国立台湾大学法律学研究所2002年博士论文，第97页。
② 周学峰：《审计师对第三人过失性虚假陈述责任比较研究》，载《比较法研究》2007年第6期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Heller & Partners Ltd.回信说，Easipower Ltd.的信用良好，然而却附带有声明说银行对此回答不承担责任。Hedley Byrne 的开户行将这封信转达给了原告，后来证实这封信的内容存在虚假成分。Easipower Ltd.公司后来破产，Hedley Byrne 公司因此遭受到经济损失，于是向法院起诉 Easipower Ltd.公司的开户行 Heller & Partners Ltd.，请求其赔偿自己的经济损失。上议院认为，因为被告银行在陈述时已声明对此陈述不承担责任，即附带了免责条款，因此不对原告承担损害赔偿责任，但它同时也认为，如果没有该免责条款，被告银行就对原告负有注意义务，应当承担过失侵权责任，虽然原告所受损害的性质仅为纯粹经济损失，但仍可以成立过失侵权责任。[①]

该案确立了许多解释注意义务存在的理论。主要包括：

1．特别关系的理论

Hedley Byrne 一案认为，只有当双方当事人之间的关系“等同于契约关系”时，作出陈述的人才对他人承担注意义务，如果陈述人违反了这种注意义务，并因此而使他人蒙受损失，则陈述人应当因为自己的过失陈述，而对委托人以外的第三人承担侵权责任。所谓“近似于契约关系”是指，如果不是因为原告与第三人之间欠缺对价，则他们之间就会存在合同，并因此而承担赔偿责任的情况。Hedley Byrne 一案的这种“等同于契约关系”的理论确立以后，成为整个英联邦国家法律的共同规则，一方当事人在作出陈述时对与自己有特殊关系的另一方总是要承担注意义务，如果违反了这种注意义务则要承担相应的责任。[②]

2．责任的自愿承担理论

在 Hedley Byrne 一案中，Lord Moris 认为，如果陈述人自愿对委托人以外的第三人提供某种意见，而陈述人在提供意见时具有过失，则陈述人可能要对第三人承担侵权责任。“应当认为目前已经确立了这样的原则，即如果拥有某种特殊技能的人在与其合同无关的情况下，承诺用其技能来帮助其他人，而他人信赖此种技能，那么，他们之间就存在着注意义务。”[③]因此，如果陈述人在一开始就明确表示，他将不因为自己的陈述内容而对第三人承担法律责任时，则陈述人就不应该因为自己的过失陈述而对第三人承担法律责任，“如果一个人已经明确表示他将不因为自己

---

① 李昊：《纯经济损失上损失赔偿制度研究》，北京大学出版社 2004 年版，第 26 页。
② 参见张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 645-646 页。
③ （1964）AC 465。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的陈述而承担责任的话，则不能够认为是自愿承担责任。”[①]然而在现实生活中，拥有某种特殊技能的专业人士很少明示的表示自愿承担责任，而更多的情形则是专业人士既不明示否认其承担责任，也不肯定其自愿承担责任，在这种情况下，法院往往会根据案件的具体情况，来权衡各种要素，通过推理方法来加以确定，是否存在责任的自愿承担。[②]

3．合理的信赖理论

在Hedley Byrne一案中，Lord Moris和Lord Reid都将第三人信赖专业人士的陈述作为陈述人对原告承担侵权责任的一个检验标准。“原告对另一方建议的‘合理信赖’显然是最为重要的。”[③]这种理论认为，如果第三人合理信赖专业人士的陈述，则专业人士就应当对该第三人承担注意义务，如果未尽到注意义务而导致第三人遭受经济损失，则应当对第三人承担过失侵权责任。在Hedley Byrne一案以后，有大量的案例适用此标准来进行判决，并且法学家们也赞成以原被告双方之间是否存在合理信赖，来作为被告就其不实陈述而对第三人承担注意义务的判断标准。[④]

4．金钱上的利害关系

在 Hedley Byrne 一案中，还确立一个被告因为其过失不实陈述而对第三人承担注意义务的一个检验标准，即金钱上的利害关系。Lord Devlin 在该案中认为，因为过失不实陈述诉讼是建立在“等同于契约关系”的基础上的，因此，如果被告对相关的交易享有金钱上的利害关系时，则他对第三人作出陈述时，就必须承担注意义务，这就相当于合同的相对性规则和对价性规则一样，要求当事人之间互相承担注意义务，如果未尽到注意义务，则要承担相应的侵权责任。此案后，英联邦均承认，被告享有金钱上的利害关系是产生注意义务的一种根据。[⑤]

Hedley Byrne 案的判决作出之后，便被认为是确立了纯粹经济损失的例外赔偿原则，而其基础在于当事人之间存在信赖关系。[⑥]对于英国法中纯粹经济损失赔偿的例外，有外国学者做了总结，认为在特殊关系这个核心概念的基础之上，存在着一系列的原则，而不仅是单一原则。第一类关系是 Hedley Byrne 所确认的类型，即

---

① （1964）AC 465, 553, Per Lord Devlin。
② 张民安、龚赛红：《专业人士所承担的过错侵权责任》，载《法学评论》2002 年第 6 期。
③ B. S. Markesinis ans S. F. Deakin, ibid, p87.
④ Bruce Feldthusen, Issues in Tort Law, ibid , p190.
⑤ 张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 649 页。
⑥ 张新宝：《侵权责任构成要件研究》，法律出版社 2007 年版，第 177 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

被告对原告自愿地承担责任，双方之间由此而形成了直接的信赖关系；第二类关系是，被告对第三人承担义务，因此在双方之间形成了间接信赖关系；在第三类关系中，被告没有履行对第三人承担的义务，由此而导致原告遭受损失，但原告的行为本来就未基于该等信赖做出。[①]

（二）纯粹经济损失处理规则的不确定性

Hedley Byrne 案只是在“过失不实陈述”类型的案例中，适用责任排除规则的一个例外，并没有使责任排除规则的传统得到彻底的颠覆。此后，英国的案例不断地否定先例，又不断地被此后的其他案例再否定。在这期间，法官对于纯粹经济损失问题的处理充满了变数和不确定性，在每种类型中，都会出现不同的意见，也会出现不同的政策考量因素。

1．电缆案型

1973 年 Spartan Steel v Martin 案件[②]就是一个著名的电缆案件，在该案中，丹宁勋爵对此案中拒绝赔偿纯粹经济损失背后的公共政策的考虑作了详细的说明，他认为，在电缆案件中，被告是否承担纯粹经济损失的赔偿责任，最好是考虑特定的关系，并且是一个政策方面的问题。在判决理由中，丹宁勋爵明白地表示，被害人是否能够请求纯粹经济损失的赔偿责任，从根本上而言，是个政策问题；以是否存在注意义务，损害是否具有因果关系来决定被告的赔偿责任，其实是基于政策考量，以便合理限制被告的赔偿责任。丹宁勋爵强调对于纯粹经济损失是否应该得到赔偿，在政策上应该考虑五点：[③]

（1）制定法上的公用事业供应者的地位。如果公用事业的供应者，因为没有供应电、气或水或者关闭此种供应以便维修，而导致消费者的经济损失时，公用事业的供应者并不承担损害赔偿责任，即使此种损害是由于他们的过失引起的。在制定法上，公用事业的供应者从来就不用对单纯的经济损失承担赔偿责任。如果这是法律所采取的立法政策的话，那么，普通法也应当对挖断电缆的承包人采取类似的政策；如果电力委员会因为过错而导致电力供应中断，然而却不需要对因此而引起的经济损失承担法律责任，那么，一个承包人也同样不应该对此承担法律责任。

---

① [英]阿拉斯泰尔·马里斯、[英]肯·奥里芬特：《侵权法》（英文影印本），法律出版社 2003 年版，第 56 页。转引自张新宝：《侵权责任构成要件研究》，法律出版社 2007 年版，第 177 页。

② 具体案情见本文第 11 页。

③ 张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 674-676 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）电力供应中断的危险性质。电力中断经常发生，或者是因为线路的意外故障，或者是因为雷电，或者是因为电线被树木压断，或者是因为人们的过失所导致。这些事故的发生，会影响很多人；但通常不会对人们的人身或财产造成有形损害，而只是使人们生活上感到不便，有时也会使他们遭受纯粹经济损失。然而，电力供应一般几小时即可恢复，因此，通常人们所遭受的经济损失不是很大。人们通常认为这个风险是他们在日常生活中必须忍受的风险，不能够请求任何人予以赔偿。有些人为防止电力中断带来的损失而自备发电器等供电设备，还有些人去买保险以防止损害，但是绝大多数人是自愿承受此种风险。当电力中断时，他们不会去法院，也不去问是谁导致了电力中断，他们仅仅是忍受，并试图在第二天更努力地工作以补偿所受的损失。这种态度是健康的，并且是法律应该鼓励的态度。

（3）诉讼泛滥的担忧。如果人们被允许，因为这些特别的风险而使经济损失得到赔偿的话，那么，这样的请求权将会无休无止。其中有些人的请求可能是真的，有些人的请求可能是虚假的，而实际上基本不可能调查这种请求权的真与假。如果是这样的话，对于单独发生的纯粹经济损失，不如完全不允许提起请求。

（4）社会对相关经济损失的承受。对于此类经济损失的风险，应当由遭受损失的整个社会来承担，这些人的损失总量多但每个人的损失数量相对较少，而不应由加害人一个人来承担，这样将使其承担的赔偿数额太大。

（5）某些例外案例的存在。被告过失中断电力供应，并因此而导致人身伤害或财产损害时，则应当予以赔偿，并且还要赔偿因为这种有形损害而导致的任何经济损失。这种案件相对而言比较少，而且容易证明及查证。对于这些间接经济损失，法律应当并且也的确是允许给予赔偿。

在随后出现的电缆案件中，法院大都拒绝了原告的诉讼请求，但所采用的理由却不相同，有的是强调损害过于遥远，有的则强调不应突破责任排除规则，但是其背后的真正原因却是对诉讼泛滥的担忧。

2．不实陈述案型

不实陈述的法律责任在 Hedley Byrne[①]一案后，出现了扩张的趋势，而这种扩张的趋势在 20 世纪 90 年代被 Caparo Industries plc v. Dickman[②]案遏制住了。Caparo

① 具体案情见本文第 16-17 页。
② [1990]1 All E. R. 568, [1989] 1 All E. R. 798.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

案终结了自 Hedley Byrne 案以来出现的责任不确定的局面，代表了英国司法界对于不实陈述案件的转向。在该案中，A 公司聘请被告会计师制作财务报表，并以该报表为基础，制定股票的承销价格。原告信赖被告，因而向 A 公司的其他股东大量收购股票，最后持有 A 公司百分之九十的股份。收购结束后，原告发现公司财务报表上虽然显示公司有 120 万英镑的税前利润，但实际上已亏损超过 40 万英镑，原告因而遭受严重损失，于是起诉被告请求赔偿损失。该案一审法院认为，原被告双方之间，并不具有“密切而直接的关系”，因此驳回原告的诉讼请求。二审法院则认为，原被告双方之间具有密切的关联性，因此撤回原审判决。然而三审法院却赞成一审法院的判决，认为注意义务的认定，必须是公平且合理的，如果让会计师对不特定的多数人承担注意义务，将会导致不公平且不合理的结果。而且如果国会认为应当对会计师施加这种注意义务，就应该在公司法中对此加以明确规定，既然国会没有这样规定，便不应该由法院以侵权行为法上的注意义务理论来弥补。[①]显然，影响法院认为不存在注意义务的重要因素，仍是对诉讼闸门的担忧。该案的重要之处还在于它提出了“三阶段检验法”，要求确认是否存在注意义务时，要考查可预见性要素、近因性及公平、正义和合理三个要素。

三、注意义务的检验标准

在英国法中，合同的主要特征是以协商一致为基础及提供履行合同的对价，这两个原理密切相关，允许提起诉讼的基础仅仅是不履行合同，其集中于某些特定的事实，即原告已经承担并忠实地允诺做某些事情。但是在纯粹经济损失的情形中，通常没有“对价”，原告和被告之间不能成立合同关系，因此不能提起合同诉讼。由于英国合同法的僵化，坚持对价原则，使其不能保护法律上的陌生人。而英国侵权法则与合同法相比，具有一定的灵活性，尤其是 20 世纪以来，“过失”（negligence）侵权行为，这样一种概括性、包容性很强的类型的设制，使得英国侵权法更为灵活机动。因而法官多用侵权法，尤其是“过失”侵权来处理纯粹经济损失问题，而其中最重要的是对注意义务的判断，认为如果被告对原告负有注意义务，而因为没有尽到此种注意义务致使原告遭受纯粹经济损失时，被告应当承担侵权法上的赔偿责任，反之则不承担赔偿责任。

[①] 邱琦：《纯粹经济上损失之研究》，国立台湾大学法律学研究所 2002 年博士论文，第 110 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在过失法中，首要的是原告必须能够证明在侵权行为发生时，被告对原告负有注意义务。注意义务表明法律承认在当事人之间存在着法律关系，一方有义务谨慎小心不损害另一方。三阶段检验标准提供了一个基本的，能够决定责任问题的柜架。它提供了某种统一的外观，来利用对原告损害的可预见性、关系的近邻性及政策因素这些要素来裁决案件，使三阶段检验标准在英国被明确采用。为了证明注意义务的存在，原告必须提出权威案例作证明，或者以其他方式使法院确信，关于争议的特定种类的损害，满足三阶段检验标准中的每一个要素。[①]

1．损失的可预见性

可预见性是邻居原则提出的，认为如果被告能够“合理预见”到他的作为或不作为，会对原告造成一定的损害，则被告就被原告承担注意义务。这种可预见的损害是指“如果行为人尽到必要的注意，则有可能避免损失或能够将损失降到最低的损害”，判断的依据是行为人在行为之前所获得的有效信息。“可预见性”是一个弹性很大的概念，还具有另一个的价值——限制承担注意义务的人，以及因此限制对其行为承担责任的人的范围。这样，就使得可预见性的概念可以作为一个控制工具，使法官在实践中可以根据实际情况来灵活掌握，用以判断在具体的案件中受害人是否有权请求纯粹经济损失的赔偿。[②]

2．当事人间关系的近因性

近因性是指一种法律上的关系或法律所认可的关系。如果存在这种近因关系，被告就应该对原告承担注意义务，如果不存在这种近因关系，则被告不对原告承担注意义务。近因性检验标准的主要功能在于确定，被告行为时是否适当，被告是否能够采取一定的措施来避免损害原告利益。近因这个词的内涵，同可预见性一样也是灵活的、富有弹性的，应该根据周围的社会环境、道德准则和判断标准来确定。[③]因此，毫不令人惊奇，不同类别的过失侵权，其近因性的构成也不同。

3．政策因素

政策是指考虑社会的普遍的公共利益或福利的一般原则。可预见性和近因性要

---

① Christian Witting, Compensation for Pure Economic Loss from a Common Lawyer's Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.112-113.

② 参见毛大春、王枫：《英国侵权法的注意义务述评》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第21卷），金桥文化出版（香港）有限公司2001年版，第453-454页。

③ 毛大春、王枫：《英国侵权法的注意义务述评》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第21卷），金桥文化出版（香港）有限公司2001年版，，第454-455页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

素需要评估事实情况，他们主要以是否有注意义务为基础。然而，法院也要求施加注意义务是“公平、正义和合理的”，然而怎样算是公平、正义和合理，显然只有参考司法价值才能判断。法院认为，考虑对于新类型案件施加注意义务是否会产生广泛的影响，是他们的合法职责。这些后果可能包括，与法律制度的不一致，公共机构过重的负担，诉讼闸门的打开等等。当权衡在个别案件中赞成责任及在大背景下反对责任的论据，则可能会拒绝强加注意义务。特别是在经济损失领域，法院经常以对不良后果的恐惧作为拒绝施加注意义务的理由。[①]

第二节　德国法中的纯粹经济损失
——保守式体系的代表

一、立法态度

《德国民法典》侵权责任法部分的规定同时受德国普通法与法国法的影响，采取了一般概括条款与分别列举之间的折衷立法方式，通过三个层次的规范模式，规定了三种类型的侵权行为，体现于以下条款：[②]

第 823 条第 1 款：故意地或者有过失地以违法的方式侵害他人的生命、身体、健康、自由、所有权或者其他权利的人，负有向他人赔偿由此发生的损害的义务。

第 823 条第 2 款：违反以保护他人为目的的法律的人，负有同样的义务。根据法律的内容，没有过错也可能违反法律的，只有在有过错的情况下，赔偿义务才发生。

第 826 条：故意地以违反善良风俗的方式加损害于他人的人，负有向他人赔偿损害义务。

其中侵权行为的一般条款是《德国民法典》第 823 条第 1 款，规定了一般侵权行为所保护的对象仅限于权利，而且是绝对权，并不及于一般的财产利益。并且第 823 条第 1 款所规定的那种“其他权利”，也不包括作为整体的钱财。经济损失只有伴随合法权利受到侵害时，即为间接经济损失时，受害人才可基于第 823 条第 1 款

---

① Christian Witting, Compensation for Pure Economic Loss from a Common Lawyer's Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.114-115.

② 条文翻译参见陈卫佐译注：《德国民法典》，法律出版社 2004 年版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的规定请求赔偿。因此，如果加害人的行为并不涉及其他任何人身伤害、有形财产损害或对“其他权利”的侵害，而只是单独造成了受害人的纯粹经济损失时，受害人就不能依据该条款请求赔偿损失。[①]

《德国民法典》第823条第2款规定的侵权责任类型，为违反保护他人目的之法律，在该条款中，损害的形式，无论是人身损害，有形财产损害还是纯粹经济损失，都具有同样重要的意义，也就是说，该款所规定的侵权行为类型，其保护的客体不仅包括权利，也包括权利以外的法益，但有一个限制，即只有损害是由保护性法律所旨在防止的危险引发时，才符合该条的规定，才能够获得赔偿。如果保护性法律的目的只是为了防止人身伤害和财产损害的话，那么纯粹经济损失就不能依据该条款获得赔偿。而且即使是法律规范对纯粹经济损失提供保护，其也并不是保护所有的纯粹经济损失，如外国公司未经许可，不准在德国进行营业的禁止性规定，就不保护针对该公司提起诉讼而支付的费用。再如，刑法中的欺诈罪，也不保护欺诈人的商业伙伴因欺诈而间接受到的经济损失。因此《德国民法典》第823条第2款的规定自身就已经实现了对纯粹经济损失的限制。[②]

《德国民法典》第826条是由社会道德上升的法律规范，这个一般概念的条款主要是为了维护社会的伦理秩序。该条款所保护的客体，除了权利以外，还包括权利以外的法益，也包括纯粹经济利益。但是这种侵权行为的成立要受到两个条件的限制：一是主观上要求加害人必须有“故意”[③]，二是要求加害人以“违反善良风俗”的方式施加损害。因此第826条也对纯粹经济损失的赔偿有所限制，主要就是通过这两个要件的规定。[④]

因此，由于《德国民法典》的侵权行为法部分，采取的立法体例为概括加列举、两个条文三个层次，使得纯粹经济损失只有在符合违反“以保护他人为目的的法律”或“故意违反善良风俗”的要件情况下，才有可能获得赔偿，这就基本排除了依据侵权行为法而救济纯粹经济损失的可能性。

---

① 王千维：《由“民法”第一八四条到第一九一条之三》，载《“民法”七十年之回顾与展望论文集》（一）（总则·债编），中国政法大学出版社2002年版，第119页。

② 李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社2008年版，第192-193页。

③ 虽然有学者认为不一定是直接故意，间接故意也可，但主观要件的要求仍是限制了该种侵权行为的适用范围。

④ 李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社2008年版，第193-194页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

二、司法尝试

由于纯粹经济损失在德国侵权法的规定下，很难获得赔偿，而这又极不符合社会发展的需要，于是德国法院在实践中进行了很多尝试，来扩大对纯粹经济损失的救济。

（一）创设“营业权”

德国法院在实践中创设了一种所谓“对已设立及实施企业经营的权利”（Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb），简称营业权，以弥补对经济利益保护的不足。营业权肇始于1904年德国帝国法院一则判决（RGZ58，24），在德国法上已经经历了百年的发展。在该案中，被告根据其在登记薄上的商标，要求原告停止仿冒其商标。原告停止生产后，发现被告的商标在申请时已经属于众所周知的事实，因此不具备商标能力，于是向法院起诉，要求被告赔偿因停止生产而受到的损害。在这个案件中，原告被侵害的并不是权利，而只是财产利益受损，因此不适用《德国民法典》第823条第1款，同时也不能适用《德国民法典》第826条的规定，因为被告并没有故意以违反善良风俗的方法损害原告。为克服这种侵权责任体系上的限制，德国帝国法院于是特创设所谓的营业权，认为针对已经设立且正在实施的营业，应该承认有一种能够被侵害的权利。在这里企业经营者的意思活动，已经获得客体的实体化，因此能够作为承认营业权存在的坚实基础。[①]

从这个判决中，可以看出承认营业权是为了突破由《德国民法典》第823条第1款、第2款和第826条组成的侵权行为体系所产生的，对于总括财产保护的不足。[②]第二次大战之后，德国联邦法院继续遵守此判决，认为营业权属于《德国民法典》第823条第1款所称的其他权利。营业权具备概括条款的性质，属于一种“框架权”，其保护的客体包括企业活动的整个范围，但是不包括构成企业经营的财产及其成员。[③]

德国法院在审判实践中引入了一个“对企业经营的侵害必须是与经营有关的侵害”的标准，以具体准确地表述营业权。原来帝国法院判决中的观点，赔偿损失请求权成立的一个条件是，经营的存续受到侵害。[④]但联邦最高普通法院并没有遵循

---

① 王泽鉴：《侵权行为法》（第一册），中国政法大学出版社2001年版，第178-179页。

② [德]马克西米利安·福克斯著，齐晓琨译：《侵权行为法》，法律出版社2006年版，第70页。

③ 王泽鉴：《侵权行为法》（第一册），中国政法大学出版社2001年版，第179页。

④ 经营的存续受到侵害的情况是指，经营确实受到妨害、经营被他人禁止或被要求进行限制或予以停止。另外，仅仅是间接地危害经营的行为不能满足这一标准。例如，剥夺赢利所得、侵害营业者的供货商。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

帝国法院的观点，而是认为，对营业这一概念的理解，应当包括在经济上能够使经营行为得以实施并发挥作用的一切情况的总和，也就是说，不仅仅是营业场所及其所占有的土地，不仅仅是机器设备，也不仅仅是附属设施和储存的货物，而是还包括商业渠道、客户和应收款项。应予保护的不仅仅是营业本身的存续，还包括营业的外在形式，只要这种形式关系到业主的与经济行为有关的形象和对外关系。在这一范围内，联邦最高普通法院没有仅限于对单纯的经营存续予以保护。对于标准中的直接侵害经营这一要求，联邦最高普通法院坚持了原帝国法院的观点，认为："直接对业已存在的营业的侵害……必须是以某种方式直接针对该项营业本身的，也就是说是与经营有关的，而不是仅仅针对可以与经营相分离的其他权利和法益。"[①]

营业权的创设是这了弥补德国侵权行为法对纯粹经济利益保护的不足，而为了防止不适当地扩大其适用范围，德国通说认为侵害营业权的损害赔偿请求权仅具有补助性的性质，如果与其他请求权发生竞合时，则不能适用此请求权，而应仅适用其他请求权，例如因为不正当竞争行为而导致侵害营业权时，应当适用不正当竞争的相关法律，而不能适用侵害营业权的规定。侵害企业的所有权时，应当适用《德国民法典》第823条第1款的规定。只有《德国民法典》第826条关于故意违反善良风俗的规定，不属于特别法，能够竞合适用。关于侵害营业权行为的违法性，德国联邦法院强调应该依据具体个案来进行利益衡量，而不能采用"权利侵害引征不法"的原则来认定行为的违法性。[②]

在德国的司法实践中，一般认为以下几种行为为侵害营业权的行为：（1）保护权利的警告，如对自己不存在的商标或专利权主张权利，并以此要求他人必须停止某种商品的生产，也即创设营业权的那个案例。（2）传播对企业有害的事实，如无正当理由，向不相关的第三人散布迟延付款客户的黑名单。（3）联合抵制，如是为了竞争则适用不正当竞争法；如不是出于经济目的时，则构成侵害营业权。（4）不法罢工等。[③]

（二）"物之使用不能"案型的创设

德国法院为了使纯粹经济损失可以通过《德国民法典》第823条第1款的规定获得赔偿，创设了"物之使用不能"案型，即通过扩大解释所有权的保护范围，使

[①] [德]马克西米利安·福克斯著，齐晓琨译：《侵权行为法》，法律出版社2006年版，第72页。
[②] 王泽鉴：《侵权行为法》（第一册），中国政法大学出版社2001年版，第180页。
[③] 王泽鉴：《侵权行为法》（第一册），中国政法大学出版社2001年版，第180页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

之扩大至物的使用范围，从而将纯粹经济损失权利化，使其可以获得侵权法的保护。如将汽车擅自停放于他人车库前面，致使车库的所有人不能使用其车库，在这种情形下，德国通说认为是侵害了所有权，被害人能够请求行为人赔偿其因不能使用车库而遭受的损害，或者请求行为人赔偿拖走该违规车辆所支付的费用；再如将按照一定次序排列的资料、文件或文库打乱，致使所有人必须重新检查、整理、分类并因此而支付一定费用时，也可构成对所有权的侵害（GBHZ 76，216）。[①]

但在电缆案及交通堵塞的情形下，如果所有权人不能正常使用其所有之物，能否构成侵害所有权？就电缆案，德国联邦最高法院曾经作出一则判决（BGHZ 41，123）。该案件事实为：被告在挖地道时因过失挖断了属于第三人的电缆，中断了原告的养鸡场的电力供应，使原告遭受了损失，其中一部分损失为，孵卵器上的蛋孵出了畸形的小鸡，该部分损失被认为是所有权受到侵害，因此可以得到赔偿。另一部分损失为原告因停电而不能使用孵卵器导致的损失，这部分损失被认为是纯粹经济损失，不能够得到赔偿。又如所谓的水道阻塞致使船舶使用不能的案件（Fleetfall，BGHZ 55，153）。该案的案情为：被告有一个设在港口旁边的工厂，其部分倒塌，并有进一步倒塌的危险，于是原告根据政府机关的命令，用支架在港口两边支撑该工厂的建筑物，但该支架却导致进出港口的水道被封闭，而原告所有的一支船被困于水道不能出来，因此不能履行原告与水道旁边的磨粉厂所订立的运输合同，而原告所有的另外三条船因为在水道之外，也不能运货至磨粉厂，因此原告遭受了利润损失。对于被困水道内的船所受的损害，德国联邦最高法院认为是所有权受到侵害，而对位于水道之外的那三条船，法院则认为不能构成对所有权的侵害，因为那三条船仍可以作为运输工具使用，其只是不能进入水道而已，但其作为运输工具的功能及其利用并未被剥夺。另外还有一则储油库爆炸案件（GBH NJW 1997，2264），被告经营一家储油库，因为过失而导致储油库发生爆炸，警察命令原告搬离其营业场所 2 小时以避免进一步的损害，后又因为救火，警察将交通封锁 5 小时，致使原告又中断营业 5 小时。就前两个小时的不能营业，德国联邦最高法院认为，原告被排除使用自己的物，构成了侵害所有权，因此可以获得赔偿，而对于交通封锁导致的不能营业的后 5 个小时的损失，则认为是原告因为不能利用公共道路而遭受的损失，为纯粹经济损失，不能获得赔偿。[②]

[①] 王泽鉴：《侵权行为法》（第一册），中国政法大学出版社 2001 年版，第 161 页。

[②] 王泽鉴：《侵权行为法》（第一册），中国政法大学出版社 2001 年版，第 162-163 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

王泽鉴教授认为对电缆案的判决是合适的，因为需要控制责任的范围。在电缆案中，因停电而导致的不能使用物的经济损失，涉及的受害人很多，其范围无法控制，因此为了避免使加害人承担过重的负担，应当对此种纯粹经济损失的赔偿责任予以限制。而对于水道阻塞案件，德国法院作出的判决，王泽鉴教授认为也是恰当的，因船只被困于水道而不能出来，会影响其市场价值，所以应当赔偿该船所受的损失；而在水道之外的船，仍然可以用于其他用途，只是不能进入水道而已，因此其价值不会受到损害，所以对这些船所受的损失不予赔偿。但对储油库爆炸案件，王泽鉴教授则认为前2小时和后5小时很难区别对待，二者应该都是纯粹经济损失。他并认为，在何种情况下，物之使用不能能够构成对所有权的侵害，应斟酌损害时间长短、物的市场价值、被害人的范围、可预见性等因素，并应当考虑适当限制加害人责任范围的政策考量，根据个案的具体情况来认定。[①]但实际上笔者仍认为很难区别，这种认定具有一定的牵强性和随意性，不能作为一种成熟的方法来对待。

德国侵权法对纯粹经济损失的救济存在很大的局限性，虽然法院通过判例创设了“营业权”，扩张解释了“所有权”，但仍然不能完全缓解救济不足的缺陷，于是德国学者及法院只能扩大契约法的适用，在契约法中寻找救济的途径。

三、契约法的救济

在解决纯粹经济损失问题时，德国比其他国家更广泛地利用了合同责任。扩大合同法作用的原因有三个：首先，也是最重要的一点，除了允许侵权之诉与契约之诉的竞合规则之外，德国侵权法在保护需要法律救济的经济利益方面过于薄弱和狭窄，不能适应实际需求。其次，在违约责任的情况中基本不会发生无限损害的危险，不会使被告对不确定的人承担不确定的责任，没有打开诉讼闸门的危险，因此合同法请求权似乎是个相对安全的道路。[②]另外还有一个重要的原因就是德国合同法证实比侵权法更具有弹性，主要表现在：①德国合同法中，对于合同的成立不要求必须有约因，[③]允许突破合同相对性原理，德国帝国法院就是借助于《德国民法典》第328条中规定的“为第三人利益合同”，来创造出了“附保护第三人作用之合同”

---

① 王泽鉴：《侵权行为法》（第一册），中国政法大学出版社2001年版，第163-164页。

② [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第111页。

③ [德]克里斯蒂安·冯·巴尔著，张新宝译：《欧洲比较侵权行为法》（上卷），法律出版社2004年版，第566页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理论；②德国合同法也不象英国合同法那样，存在着损害赔偿的可预见性规则，[①]合同法中依据法律规范保护目的说对赔偿责任进行限制。要求从合同的意义和目的角度通过解释来确定哪些利益符合合同的保护目的。法官不是根据充分性原则对合同目的进行全面考察和认定，而是对具体合同目的进行个别考察和认定，对方当事人的哪些利益落入合同的保护范围。[②]因此，德国法院能够通过解释，使债务人也对第三人的损害进行赔偿。

（一）缔约过失责任（culpa in contrahendo）

1．缔约过失责任的产生

缔约过失责任是指当事人为缔约契约而进行接触磋商时，因为一方当事人没有尽到必要的注意义务，而导致另一方当事人受到损害的情形，是通过学说和判例逐渐建立和完善起来的一个制度。德国法学家耶林于 1861 年在其主编的“耶林法学年报”第四卷上发表了“缔约上过失，契约无效与不成立时之损害赔偿”一文，对缔约过失责任进行了系统的、深刻的、周密的分析：

“进行缔结合同的人，是从合同交易外的消极义务范畴，进入合同内的积极义务范围，因此承担的首要义务是在缔结合同时必须尽到必要的注意。法律所保护的，并不仅仅是一个已经存在的合同关系，而是应该也包括正在缔结中的合同关系，否则，合同一方当事人将会因此成为他方疏忽或不注意的牺牲品！因合同缔结而产生了履行义务，如果因为存在法律上的障碍而排除此种履行义务时，就会产生损害赔偿责任，因此，合同无效仅指不发生履行效力，而不是说不发生任何效力。简言之，当事人因自己的过失导致合同不成立的，对相信合同有效成立的相对人的信赖利益损害，应当承担赔偿责任。”[③]

耶林提出这个思想后，得到了广泛接受。很快，几部德国法律就体现了这一理论。帝国立法部门很快适应诉讼之要求将耶林的理论规定在《德国民法典》第 122 条（对以错误为由取消自己的意思表示之责任）和第 307 条（对客观的履行不能之过错责任）中。

在《德国民法典》产生后，较早涉及缔约过失责任的一个著名判例就是德国帝

[①] [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编，吴越等译：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，法律出版社 2007 年版，第 62 页。

[②] [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编，吴越等译：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，法律出版社 2007 年版，第 67-68 页。

[③] 王泽鉴：《民法学说与判例研究》（修订版）第一册，中国政法大学出版社 2005 年版，第 83-84 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

国法院在 1911 年 11 月 7 日作出的“地毯跌落案”（Linoleumteppichfall，亚麻绒毯案）（RGZ 78，239）。在该案中，一个顾客在商店内查看地毯，由于商店雇员的笨拙，导致地毯从架子上滚落而砸伤了该顾客。法院认为顾客要求查看地毯以及商店满足其这一要求就导致了一种在买卖的预备阶段存在的类似于合同的关系，它使商店承担了照顾顾客的人身和财产的注意义务。在该判例中，法院适用了“预期的购买者”一词，表明它并不想将这一对合同关系的扩展（扩展至了合同前的阶段）适用于所有的情形。不过这一界限留给了法院在将来划分。潜在的购买者（即仅在商店闲逛而尚没有确定的意图购买特定商品的人）也可能会被纳入进来。[①]

2．缔约过失责任的发展

缔约过失责任在德国民法上的应用范围逐渐扩大。Medicus 从损害的角度将缔约过失责任分为三种类型：（1）第一种类型为与合同无关系的损害，它主要涉及人身伤害和所有权损害。这主要是指，合同谈判的一方当事人在另一方当事人的领域内遭受到升高的危险（如前述的地毯跌落案），并因此而导致人身伤害或所有权损害。此时适用缔约过失责任主要是为了规避适用《德国民法典》第 823 条第 1 款的侵权请求权的障碍。[②]（2）第二种类型是指产生于合同效力存在障碍的情形中的损害（即产生于合同无效的情形）。主要是指参与合同谈判的一方当事人，在有陈述义务时而对合同效力障碍保持沉默，或者在没有充分根据时中断了合同的谈判。这时受害方遭受的损失通常是纯粹经济损失。《德国民法典》第 122 条、第 179 条第 2 款和第 311a 条第 2 款对此有规定。（3）第三种类型是指合同生效而产生的损害。此时，对方当事人并没有因为过错而违反合同义务，只是受到“并不希望的合同”约束的当事人提出，他根本就不想订立该合同或者是仅想订立其他内容的合同。这里涉及的也主要是纯粹经济损失。[③]

---

① 李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社 2008 年版，第 205 页。

② 这主要是指《德国民法典》第 831 条第 1 款第 2 句的免责证明和以前的第 852 条的短期时效规定。第 831 条：（1）为某事务而使用他人的人，对他人在执行事务中不法地加给第三人的损害，负有赔偿义务。使用人在挑选被用人时，并且，以使用人须置办机械或者器具或者须指挥事务的执行为限，使用人在置办或者指挥时，尽了在交易中必要的注意，或者即使尽此注意损害也会发生的，赔偿义务即不发生。（2）以合同为使用人承担第 1 款第 2 句所称事务的处理的人，负同样的责任。第 852 条：因侵权行为所生损害的赔偿请求权，自受害人知悉损害事实或赔偿义务人之时起，因 3 年内不行使而消灭，在不知的情况下，自加害行为发生之时起 30 年内不行使而消灭。

③ Medicus, 3. Leistungsstörungsrecht, in Haas, Lothar u.a. (Hrsg.), Das neue Schuldrecht, Verlag C. H. Beck, München, 2002, S.116-117.转引自李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社 2008 年版，第 206-207 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在现代德国法上，缔约过失责任所适用的主体从两个方面进行了扩展，而并不仅限于进行合同谈判的双方当事人：在债权人方面，它将与债权人有密切联系的第三人也纳入保护范围，即将附保护第三人作用之合同理论延伸到了合同谈判阶段；在债务人方面，它也扩展至了第三人，使第三人也对债权人承担义务，即创设了所谓的“事务管理人责任”。[①]此外，对合同订立具有个人的经济利益的第三人，也被扩展至缔约过失责任的保护范围。这里的标准很严格，间接经济损失并不足够，必要的是，第三人和合同有着如此紧密的联系，以至于可以说他是在为自己的事务行为，并且从经济角度看，他已成为了对方真正的合同当事人。[②]

通过以上几方面扩展，缔约过失责任可以用来解决纯粹经济损失问题。典型判例如德国联邦最高法院在1975年1月21日作出的旧车中介案判决(GBHZ 63,382)。在该案中，原告于1970年9月经过被告的介绍，以3，300马克从第三人M那里购买了一辆旧车。M知道该车曾经发生过事故但却未告知原告。原告购买该车后不久就发现它无法正常行驶，并且技术监督协会以该车不符合交通安全为由要求停止使用。因而原告起诉被告要求赔偿其缔约费用、车款利息、鉴定费用等信赖利益损失。在一审、二审和终审中，原告都获得了胜诉。判决的理由在于，作为专业车商的被告在卖车时，作为M的中介人和代理缔约人就获得了M的“事务管理人的地位”，如果他在缔约时违反了相关的注意和和公开义务，而合同当事人又对其产生信赖的话，就应当承担赔偿后者的信赖损害的责任。这一案件也引发了对“事务管理人责任”这一专家责任类型的讨论。在该案中，承担责任的主体与通常承担缔约过失责任的主体并不相同，承担责任的并不是买卖合同的另一方当事人（M），而是合同一方当事人的代理人，即作为被告的专业车商。而民法上的投资咨询责任更是以纯粹经济损失作为其赔偿客体。[③]

3．德国新债法中的缔约过失责任

在修正后的德国新债法中，缔约过失责任已被明确规定在《德国民法典》第311

[①] 事务管理人责任是指，参与合同谈判的第三人，虽然不是合同当事人但是作为代理人或纯粹的谈判辅助人，但如果要求相对人对自身的特殊信赖，就应当对对方当事人的权利和利益承担注意义务，如果违反了这一义务就要自己承担缔约过失责任，而不是由被代理人承担责任。参见李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社2008年版，第207-208页。

[②] Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum Schuldrecht, S. 190-191. 转引自李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社2008年版，第208页。

[③] 李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社2008年版，第209-210页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

条第 2 款中。[①]上述的代理人责任或“事务管理人责任”、“投资预测责任”也被纳入到《德国民法典》第 311 条第 3 款第 2 句中，即合同之外的第三人也可能对合同相对人承担合同责任。在有关的判决中，法院特别强调，第三人的信任必须要超过一般缔约协商的那种信任，即必须是一种特殊的信赖。但究竟什么是特殊的信赖呢？在早一些案例中，联邦最高法院认为当事人对有关法律行为的状态和履行的前景做了某种担保，方构成“特殊的信赖”；在最近的几个案例中，则认为当事人对意思表示的真实性和完整性做了担保，并对另一方当事人作出决定发生了重要的影响，即构成“特殊的信赖”。从近年的判决来看，构成“特殊的信赖”已经不再要求第三人对整个合同的履行作出担保，而只要对涉及合同订立的重要事项或信息作出担保即可。当然，在具体的案件中，到底当事人间是否产生了“特殊的信赖”，还是要结合实际的具体情况来加以分析。[②]

缔约过失责任的赔偿范围如何？《德国民法典》第 311 条第 2 款并未作出明确的规定。通常认为受害人所得请求的内容为信赖利益，且以不超过履行利益为限，但存在两个例外：一是一方当事人违反保护义务造成对方人身或所有权损害时，加害人所应赔偿的是被害人于其身体或所有权所受的一切损害，即所谓的维持利益，而不限于履行利益；二是加害人所违反的是信赖义务时，如加害人未为适当的告知、说明义务而致对方当事人支出无益费用时，赔偿范围亦不以履行利益为限度。总之，缔约过失责任所保护的范围主要是纯粹经济损失，特别是在违反通知义务的情形下。[③]

（二）“附保护第三人作用之合同”理论

1.“附保护第三人作用之合同”理论的起源

原《德国民法典》上并没有明确规定“附保护第三人作用之合同”制度，其主要是通过判例和学说发展起来的。帝国法院在 1917 年的一个判决，首次明确承认

[①] 《德国民法典》第 311 条规定：“法律行为上和准法律行为上的债务关系 （1）对于以法律行为成立债务关系，以及变更债务关系的内容来说，利害关系人之间的合同是必要的，但法律另有规定的除外。（2）具有第 241 条第 2 款所规定的义务的债务关系，也因下列情形之一而发生：1.合同磋商的开始。2.合同的准备，而在准备合同时，鉴于可能的法律行为上的关系，一方将影响其权利、法益和利益的可能性给予另一方，或者一方将其权利、法益和利益托付给另一方，或者 3.类似的交易上的接触。（3）具有第 241 条第 2 款所规定的义务的债务关系，也可以对不应成为合同当事人的人发生。第三人特别时要求对自己的信赖，并且因此而大大影响合同的磋商或者合同的订立的，尤其发生此种债务关系。”第 241 条第 2 款规定：“债务关系可以按其内容来说使任何一方负有顾及另一方的权利、法益和利益的义务。”条文翻译参见陈卫佐译注：《德国民法典》，法律出版社 2004 年版。

[②] 许德风：《对第三人具有保护效力的合同与信赖责任——以咨询责任为中心》，载易继明主编：《私法》（第 4 辑第 2 卷），北京大学出版社 2004 年版，第 284 页。

[③] 李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社 2008 年版，第 212 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了合同当事人在某些情况下对非合同当事人的第三方同样具有保护义务。在该案中，原来房屋里住了传染病人，出租人请来的医生没有很好地完成消毒工作，因而使承租人的女儿感染了传染病。[①]法院所面临的问题是：承租人的女儿并非合同当事人，是否可以根据合同要求出租人赔偿损失？根据德国民法典第831条第1款之规定，[②]雇主对雇员的不法行为（不一定是过错行为）承担责任的基础是过错推定，而这是可以推翻的，因此雇主可以提出相反证据而使自己免责。[③]在该案中，如果对出租人提起侵权损害赔偿之诉，他可能会因为第831条第1款的规定而免责。而根据德国民法典第278条规定，[④]如果受害人对雇主主张合同法上的损害赔偿责任，即使雇主证明自己已经尽了选任监督义务，也仍然不能免责。

在该案中，德国帝国法院认为，出租人和承租人之间存在着租赁合同，而根据租赁合同，出租人有义务保护承租人的身体健康。“如果租赁一个供家庭使用的住宅，在订立合同时，出租人应当知道一同居住的还有承租人的家属。因此出租人也应当保护与承租人同住的家属的身体健康，如同保护承租人的健康一样。如果合同上的保护义务没有扩张，将不能充分保护与承租人同住的家属的权利……”[⑤]在该案中，帝国法院是依据德国民法典第328条进行判决的。在后来的一些涉及到租赁合同、雇佣合同和承揽合同的案件中，帝国法院也基于同样的推理作出了判决。[⑥]

德国权威学者拉伦茨教授认为，帝国法院以德国民法典第328条“为第三人利益合同”条款作为原告的请求权基础，是不妥当的，因为“为第三人利益合同”的内容是给付义务，债务人有义务向该第三人为给付，而该第三人对债务人享有给付请求权；而在这个新创设的制度中，债务人对于特定范围的第三人，并没有合同上的给付义务，而只是对其负有一定的注意及保护义务，同样该第三人对债务人也没有合同法上的给付请求权，而只是在债务人违反注意义务及保护义务时，可以依据合同法的原则请求赔偿。因此，他把此项新创设的制度称为“附保护第三人作用之

---

① RGZ 91，21。

② 德国民法典第831条第1款规定：“为某事务而使用他人的人，就该他人在执行事务中不法加给第三人的损害，负赔偿义务。使用人在挑选被用人时，并且，以使用人须置办机械或器具或须指挥事务的执行为限，使用人在置办或指挥时尽了交易上必要的注意，或即使尽此注意损害也会发生的，不负赔偿义务。”

③ [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，吴越等译，法律出版社2007年版，第126页。

④ 第278条规定：“在与债务人自己的过错相同的范围内，债务人的法定代理人和债务人为履行其债务而使用的人的过错，可以归责于债务人。不适用第276条第3款的规定。”

⑤ RGZ 91，21（24）。

⑥ 许德风：《对第三人具有保护效力的合同与信赖责任-以咨询责任为中心》，载易继明主编：《私法》（第4辑第2卷），北京大学出版社2004年版，第260页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

合同”，而与传统的“为第三人利益合同”区别开。拉伦茨教授的上述意见，说明了帝国法院判决理由的牵强附会，后来联邦最高法院接受了此观点，在以后的案件中采用了“附保护第三人作用之合同”的提法。[①]

2.“附保护第三人作用之合同”理论的发展

法官通过“附保护第三人作用之合同”制度扩大了合同义务的主体范围。该制度的效力虽然来源于合同义务的“次义务”——照顾义务，但使债务人的风险增大了。最初法院适用这一制度时，比较小心谨慎，只将该制度适用于自然人的人身损害。并且认为该第三人属于债权人的社会关系，且债权人对该第三人负有照顾义务，而债务人对此事实具有认知。因此，该制度的适用范围最初主要限于债权人的家庭成员或者雇员。[②]然而从上个世纪60年代以后，附保护第三人作用之合同制度的适用范围不断拓展。

（1）被适用于纯粹经济损失领域

德国联邦最高法院最初只将“附保护第三人作用之合同”制度适用于比较狭窄的范围，仅适用于与债权人具有私人关系，且债权人对其负有照顾保护义务的第三人的人身损害，但随着社会交易的发展，这样的条件难以满足实际需求，特别是无法满足对“纯粹经济损失”保护的需要，因此，扩大了该制度的适用范围，认为财产损害和经济损失也属于潜在损害的范围。[③]

1965年德国联邦最高法院作出的遗嘱案是一个典型判例，在这个案件中，父亲委托一名律师协助起草遗嘱。但该律师没有按时履行自己的合同义务，在父亲（委托人）死亡之前没有完成遗嘱，致使预期的受益人，其女儿不能继承其父亲的遗产。于是女儿向法院起诉该律师，要求赔偿损失。[④]

在这个案件，联邦最高法院认为，如果当事人没有履行合同义务，导致了第三人的经济损失，而该第三人与合同的履行具有密切关系时，就可以适用“附保护第三人作用之合同”制度，但是这种延伸不得违反诚实信用原则且必须符合合同的目的。因此在该案中，联邦最高法院并没有将该制度的适用范围局限在保护义务的延

[①] 许德风：《对第三人具有保护效力的合同与信赖责任-以咨询责任为中心》，载易继明主编：《私法》（第4辑第2卷），北京大学出版社2004年版，第261页。

[②] [德]Michael Coester、Bsail Markesinis著，邱雪梅译：《德国法和美国法中的金融专家责任——比较法的运用》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第35卷），法律出版社2006年版，第292页。

[③] [德]Michael Coester、Bsail Markesinis著，邱雪梅译：《德国法和美国法中的金融专家责任——比较法的运用》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第35卷），法律出版社2006年版，第293页。

[④] BGH NJW 1965, 1955。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

伸上，最终以此延伸为依据判定：父亲与律师之间签订的委托起草遗嘱的合同，对女儿具有保护效力。[①]联邦最高法院在后来的类似案件中，再次肯定了这个观点，将“附保护第三人作用之合同”制度适用于纯粹经济损失领域。

（2）“特定第三人”的范围日益广泛

德国联邦最高法院在遗嘱案中，将“附保护第三人作用之合同”制度适用于“纯粹经济损失”之后，就不断扩大“特定第三人”的范围，在以后的案件中经常以此制度作为当事人“纯粹经济损失”救济的请求权基础。德国法院因此放松了条件要求，不再认为该制度的第三人应当是特定的，且事先能够确定，并且也不再要求，第三人与债权人之间具有密切的人格法上的关系；此外，也不再要求债权人对第三人的利益具有一定的利害关系。[②]

在1977年的“借记—程序判例”[③]中，德国法院认为：债权人与第三人之间具有合同上的照顾义务足够，而不必须是私人关系，但仍要求第三人与合同相对人之间存在某种关系。然而，很快此种观点被扩展到这样的情形：债权人与第三人是具有相同或相似利益组织中的一员。在“购买者组织判例”[④]中，德国联邦最高法院阐明：“作出指示的当事人是否对系争第三人负有照顾义务，不是裁定如此照顾义务存在的必要前提条件。在案件中，必须考虑到征求专家意见以形成特定组织的决策基础的受益当事人，他通常不仅寻求保护他个人的利益，而且寻求保护组织中其他成员的利益……”。而在著名的“领事判例”[⑤]中，法院认为尽管专家不知道第三

---

① BGH JZ 1966, 142。

② 王文钦：《德国法上“附保护第三人作用之契约”制度的新发展》，载《中外法学》1994年第2期。

③ 具体案情为：因债权人（C）持有债务人（D）的银行帐户，债务人授权C直接领取钱款，并且债务人所在银行（DB）相应地依其指示行事。随后，C将一些发票存入其所在银行CB，CB将这些发票转交给DB。但由于D在DB的帐户已透支，DB没有将这些发票记载在D的帐户中，相应的DB未为发票付款。尽管在这种情形，国内银行协议要求接收行应立即通知债权人银行，但DB没有这样做。因C未收到DB的通知，他以为银行已为发票支付了相应的钱款，继续向D交付货物。然而，几天后C收到有关D未支付的通知。不久之后，D破产了。C向法院起诉DB请求其赔偿损失。理由是若DB及时C，他不会继续与D交易，也不会遭受额外的损失。

④ 具体案情为：C先生要求一位专家D提供一份有关公寓楼价值的陈述，C或C背后对此感兴趣的人的组织中的一员正考虑购买该楼。当C给D各自订单时，这一组织的某些成员，包括了P，才露面。D将其意见交付给C之后，最终P信赖D的价值评估报告，购买了该楼。由于D未能考虑到与一社会住房管理条例相联系的限制，公寓楼的市场价值比D评估的价值低很多，P最后不得不向出卖人支付过高的价金。

⑤ 具体案情为：一位专家（D）起先给一房地产开发商（L）出具了有关一大块建筑用地价值的意见，该商人正在为他的项目寻求投资。L找到了一家生产预制装配式房屋的Danish公司（F）。因而，F要求一家Danish银行（B）贷给L一笔巨款。B考虑将建筑用地作为贷款的抵押，并且试图确定该土地的价值。于是，B请求在Munish的Danish领事C给专家D打电话，询问他几个月前做的价值评估报告是否仍然有效。在电话交谈中，C清楚地向D说明提供的信息用于决定是否发放一笔贷款，但C没有对潜在的贷方做任何说明。专家D再次肯定了其早先所做的价值评估报告，并且应C的要求给C出具了一份书面口头信息确认书。随后，B发放了贷款。但是，由于该建筑项目从未得以实现，B遭受了巨大损失。L破产了，并且专家过高评估了土地的价值。因此，B决定起诉D赔偿损失。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

人的姓名和身份，但只要他意识到“他的合同相对人背后”有第三人，合同效力的保护范围就包括第三人。当德国联邦最高法院在“顶棚案”[①]中将“附保护第三人作用之合同”制度适用于甚至与债权人不享有相似利益的第三人时，或者债权人与第三人属于“相同组织”但双方有利益冲突之时，使自身的哲学达到新的限度。[②]

3．德国债法现代化

对于“附保护第三人作用之合同”制度在德国新债法中的基础，德国学者发生很大的争议。有学者认为，在债法修订中并未将真正的“附保护第三人作用之合同”制度的适用情形纳入到民法典中，因为《德国民法典》第311条第3款规定的是合同当事人对第三人的请求权，和“附保护第三人作用之合同”制度调整的情形——合同外的第三人对合同债务人享有请求权完全不同。[③]

但是，也有的学者认为，第311条第3款第1句是在双重意义上涵盖了第三人——那些享有保护权的第三人，即他人缔结合同的保护范围内所包括的人，以及对与其没有合同关系的人负有保护义务的第三人。关于该条款的其中一项功能，可被视为首次以成文法承认了由法官创造的“附保护第三人作用之合同”制度。[④]

实际上，《德国民法典》第311条第3款第1句的表述非常模糊，并未表明这里的第三人是享有权利还是负有义务。但无论是否承认德国的新债法规定了“附保护第三人作用之合同”制度，由于《德国民法典》第311条第3款第1句并未对第三人的保护界限问题提供明确的根据，因而在现行的德国民法中，和债法现代化之前一样，必须从判例和文献，更确切地说是从对德国民法典的评论中，去推断单个责任的前提条件和构成要件，并等待法官法的进一步发展——或者扩张或者限制。[⑤]

附保护第三人作用之合同理论可适用于对过失不实陈述这一侵权行为类型的解决，特别是在会计师是受公司委托制造财务报表而与公司投资者无利害关系的情

[①] 具体案情为：一幢大楼的所有人（V）正计划出售该楼盘，并要求一位建筑专家（D）提供一份有关此楼价值及修缮状况的报告。当专家检查楼房时，V以某些借口阻止其查看顶棚，并使专家相信顶棚没有缺陷。随后，出卖人将专家报告作为与P签订买卖合同的基础。交易完成之后，买方发现该楼顶棚存在严重缺陷。由于专家对这些缺陷不知情，他把房屋的价值评估得太高了。相应的，P支付过多价金。因此，P起诉D赔偿其损失。

[②] 参见[德]Michael Coester、Bsail Markesinis著，邱雪梅译：《德国法和美国法中的金融专家责任——比较法的运用》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第35卷），法律出版社2006年版，第293-295页。

[③] Diek Lozen/Rolf Wank, Die Schuldrechtsreform, Carl Heymann Verleg, 2002, S.61.转引自李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社2008年版，第223页。

[④] 参见[德]Michael Coester、Bsail Markesinis著，邱雪梅译：《德国法和美国法中的金融专家责任——比较法的运用》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第35卷），法律出版社2006年版，第300页。

[⑤] 李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社2008年版，第224页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

形下，它亦可适用于遗嘱案型。

（三）第三人损害清算理论（第三人损害之赔偿）（Drittschadensliquidation）

原则上合同只保护订立合同当事人，合同的当事人只有在自身受到损害时才能请求实施加害行为的对方当事人予以赔偿，合同当事人以外的第三人即使受有损害，一般也不能依据合同法获得救济，但这会使之陷入不利境地，于是德国法扩张了对合同外第三人利益的保护，即创设了上述“附保护第三人作用之合同”理论和“第三人损害清算”理论。但两者发生的场合不同，“第三人损害清算”理论是指，“凡本于享有契约权利的当事人，与因同契约而拥有利益之人间之特别法律关系，对于因该契约所生之损害，在法律上并非发生于债权人，而系发生于该利益之承受人时，以因该契约而受保护之利益，应延转于该利益之第三者为限，债务人自应就本应由债权人对于第三人加以负责之损害，负赔偿之责任。”[①]

附保护第三人作用之合同和第三人损害清算这两种制度之间的关系还表现为：附保护第三人作用之合同最初是为了避免《德国民法典》第 831 条中的漏洞而产生的，起初仅适用于对人身和财产损害的保护，后来才扩展至纯粹经济损失，而第三人损害清算理论所解决的就是纯粹经济损失的问题，而且不会发生诉讼闸门的危险，因为受害人是特定的。[②]事实上，第三人损害清算制度主要解决的就是纯粹经济损失中的转移损失的问题。

第三人损害赔偿，具有两个特点：（1）仅第三人受有损害。一个损害行为发生后，可牵连引发无数损害，这一连串之损害，大约可分成两个类型：第一类型之损害，为因甲受损害因而乙随着受害，如甲不受损害，则乙之损害将无所附从。此类型之损害，为反射损害。第二类型之损害，为原本应发生于甲之损害，而因甲乙之间的特别法律关系而发生于乙，甲则无损害。要言之，第一类型中，甲乙均受损害，乙所受之损害为甲所受损害之反射，第二类型中，甲未受损害而仅有乙受到损害，乙所受的损害原本应发生于甲，即为转移损失。第三人损害之赔偿，应仅指后一种类型损害之赔偿。因此，实际受损害者，仅第三人而已。（2）实际受损害者与有诉权者分属两人。一个行为可发生一连串损害，但并非所有受有损害的人均能够请求

[①] 朱柏松：《商品制造者侵权行为责任法研究》，台湾五南图书出版公司 1991 年版，第 287 页。转引自李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社 2008 年版，第 225 页。

[②] 李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社 2008 年版，第 225-226 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

赔偿。基于违约而享有请求赔偿权者，限于合同当事人；基于侵权而享有请求赔偿权者，以直接被害人为限。第三人损害赔偿问题中，实际受有损害者为合同当事人或侵权行为直接被害人以外之第三人，而依法就违约或侵权行为能够请求赔偿者，则为合同当事人或侵权行为直接被害人。因此，能够请求损害赔偿者，并没有受到损害，而受到损害的人，则不能够请求赔偿。[①]

典型的第三人损害清算案型主要包括以下几种：[②]

（1）间接代理。间接代理人是合同当事人，但其合同获得的利益应归属于被代理人，而被代理人由于未被披露，并非合同当事人，但却对合同享有利益，若合同另一方当事人违约，则被代理人会受到损失，却不享有合同法上的请求权。

（2）危险负担移转于第三人..一般而言物之危险负担，与物之所有权不可分离，所有权移转时，物之危险负担应该同时发生移转。根据法律规定，有些物之危险负担在该物所有权移转前已经发生。如在《德国民法典》第 447 条第 1 款[③]规定的送交买卖的情形下，货物毁损灭失风险于送交承运人时已转移给买方，但货物所有权并未发生转移，仍在卖方手中，此时，如果因承运人过错造成货物毁损灭失，与承运人订有合同的卖方虽然所有权受侵害，但没有受到实际损害，因货物价金的风险已经转移给买方，买方此时仍必须支付价金，而买方虽受到了不利益，此时却因为并非合同当事人，也不享有货物的所有权，无权提起违约之诉或侵权之诉而获得救济。在第三人致使货物毁损、灭失的情况下，买方仍不能以侵权为由提起诉讼。在海上货物运输中，也是如此，因此此时货物毁损灭失的风险常以船边交货为准，而货物的所有权则以提单移转为准，这样货物的所有人和风险负担人在风险发生时可能不为同一人。

（3）物品不属于合同相对人，因该物品之毁损灭失而导致合同不履行。合同之履行常涉及某一物品，而该物品并不属于合同当事人所有时，倘如合同不履行时，则可能使享有物品所有权的第三人遭受损害。又包括两种情形：①物品占有人根据合同将物品的占有转移给他人，而该他人违反合同义务导致物品灭失或毁损；②物品占有人，因运输物品与他人订立合同，但并不移转物品的占有与他人，因该他人

---

① 曾世雄：《损害赔偿法原理》，中国政法大学出版社 2001 年版，第 214-215 页。

② 主要参考曾世雄：《损害赔偿法原理》，中国政法大学出版社 2001 年版，第 2121-223 页。

③ 第 447 条第 1 款规定："出卖人根据买受人的请求，将买卖物发送到履行地以外的地点的，出卖人一将物交付给运送代理人、运送人或者其他被确定执行发送的人或者机构时，风险即转移给买受人。"

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

违反合同义务导致物品灭失或毁损者。

在以上情形中，在法律上享有请求权之人并无损害，而受有损害的人并无请求权，依损害赔偿的一般规则，二者均不可以请求赔偿，这显然不合情理。于是德国判例特别承认，在上述情形下，请求权人得向债务人主张第三人之损害。基于当事人之间的契约关系或《德国民法典》第 255 条[①]有关请求权让与的规定，损害赔偿请求权人，应将其对债务人能够主张的请求权转移于实际受有损害的第三人或交付其所受领的赔偿物。这有利于解决所谓的第三人损害的问题，因为在第三人损害中，第一顺位被害人通常并未受有损害，损害主要发生于第二顺位受害人身上。[②]

对于纯粹经济损失问题，德国法院表现出了大胆的创造力，从而使得固有的民事责任体系特别是合同责任和侵权责任之间出现了不平衡，特别是以保护义务为基础发展出的缔约过失责任、附保护第三人作用之合同等制度更是将本属于侵权法调整的领域纳入了合同责任的领域进行调整，因此极大的削弱了侵权法的功能。

第三节　法国法中的纯粹经济损失
——放任式体系的代表

一、立法态度

《法国民法典》第 1382 条的基础是“不得伤害他人”的一般原则，该条写道：“任何人因其行为致人损害，如果对其发生有过错，则应承担赔偿的义务。”第 1383 条接着写道：“每个人不仅应就其故意行为所致损害承担责任，也应就其过失行为或不谨慎的行为承担责任。”这条单一原则的外延非常宽泛，内涵也不确定，因此并没有排除纯粹经济损失的赔偿责任。法国立法者并未针对受保护的利益制定一项列举式条款，也未事先限制法官对何种损害可获得赔偿这个问题进行自由裁量。根据主流的观点，禁止加害于他人是一项一般原则，而有权加害仅属于例外情形。因此人们一贯认为，《法国民法典》第 1382 条和第 1383 条并未事先对受保护的权利

---

① 第 255 条规定：“须为物或者权利的丧失而给以损害赔偿的人，只有凭着向其让与有权受赔偿的人依据物的所有权或者依据对第三人的权利而享有的请求权，才负有赔偿义务。”

② 李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结论变迁的一种解读》，北京大学出版社 2008 年版，第 226 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

及利益的范围和性质作出限制，也未事先对受保护群体的范围作出限制。[①]

法国民事责任普通法上的损害，原则上是一种“主观的损害”，即以个别受害人为基准主体，比较该被害人在民事责任原因事实发生后请求损害赔偿时的利益情况，与假设民事责任原因事实未发生时该被害人应有的利益情况，总体比较之后，以其中的利益差距，作为认定损害是否存在及其范围大小的依据。由于损害是“个别被害人”总体利益情况观察比较的结果，不是从“一般第三人”的观点，以同一民事责任原因事实在通常情况下所能导致的利益丧失情况，作为认定损害是否存在或其范围大小的依据，因而将此种损害概念，称为“主观的损害”。而在赔偿范围上，法国奉行“全部赔偿原则”或“损害与赔偿相当性原则”，即损害赔偿范围原则上必须等于被害人所受到的全部损害，不得小于该损害，也不得大于该损害。采取此原则的目的，一方面在于禁止被害人因为损害赔偿而不当获利，另一方面主要在于保障被害人，使其因责任原因事实所受的各种损害，可以全部获得充分而实质的填补。由于此项原则考虑到“个别被害人”的特殊情况或实际需要，可以随着科学技术或社会条件的变迁，立即且具体地反映损害状况，以弹性调整损害赔偿数额，最有利于被害人，使得此项原则成为法国民事责任普通法上的一般原则。[②]

法国法律充分保护人的生命权、身体和精神的完整权，具体的和抽象的人格权和隐私权以及财产权，使它们免受任何行为的干预和损害，包括纯粹经济损失和机会损失，而不论它们是由主要受害人还是次要受害人所遭受的，均是如此。任何损害，根据该法都是可以提起侵权诉讼的，无论是有形的还是无形的或仅是经济的损害，因为《法国民法典》关注的重点是导致损害的事件，而不是原告所享有的特定权利的性质和范围，即原告被侵犯的是何种权益，是绝对权还是纯粹经济利益，并不具有重要意义。也说是说，任何人，只要是因为他人的过错造成的损害，原告都享有法定的赔偿权利。[③]

因此，法国法中并没有区分纯粹经济损失和非纯粹经济损失。换言之，法国法并不依赖纯粹经济损失概念来达到限制侵权责任赔偿范围的目的。从法国最高法院大量的判决中可以判断，同英国和德国法相比的结果是非常特殊的，法国法律体系

---

① [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编，吴越等译：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，法律出版社 2007 年版，第 62 页。

② 陈忠五：《论法国交通事故损害赔偿责任的成立要件——损害、牵连关系与归责关系之研究》，载《政大法学评论》第 97 期，国立政治大学法学院出版 2007 年版，第 16-17 页。

③ 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社 2007 年版，第 55 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

似乎最易于接受纯粹经济损失的赔偿要求。[①]

二、司法实践

在法国，虽然法官和学者没有使用经济利益、经济侵权和纯粹经济损失这些概念，但是，这并不意味着法国法中不存在经济侵权。法国法对经济利益的保护有两种，其一，对故意侵害经济利益的保护，诸如干预他人合同关系而产生的侵权责任，这是法国司法通过一系列判例确立的。其二，对过失侵犯经济利益的保护。

（一）干预他人合同关系而产生的侵权责任

在 20 世纪之前，法国法由于受到罗马法的影响，否认合同对第三人的绝对效力，严格固守合同相对性原则，认为第三人即使引诱、干预合同一方当事人的履行合同义务的行为并因此而导致合同相对方的经济利益受到损害，第三人也不对合同相对方承担侵权损害赔偿责任，受害人仅能就其自己遭受的经济利益损害，请求合同债务人对自己承担违约责任，而不得请求第三人对自己承担侵权损害赔偿责任，因此，合同不具有绝对性的效力。如 Baranger V. Bourdais (1982)一案中， Baranger 在巴黎的商业代理行由 Bourdais 买下，双方约定 Baranger 承担竞业禁止义务，即不得再在巴黎自行从事相同行业或受雇于他人从事相同行业，然而第三人 Condray 不顾双方合同中的竞业禁止义务规定而雇佣了 Baranger。Bourdais 于是向法院起诉 Baranger 和 Condray，法院准许其对 Baranger 提起的违约救济，但是驳回了原告对 Condray 提出的诉讼请求。法院认为，“至于 Condray，由于 Condray 与 Bourdais 之间自始即不存在合同关系……Condray 作为合同关系之外的第三人，完全不必对 Baranger 的违约行为承担责任。”法院最终依据《法国民法典》第 1165 条的合同相对性原则，认为被告 Condray 与原告之间并没有不雇佣 Baranger 的合同关系，因此其有权雇佣 Baranger。[②]

20 世纪以后，由于社会情况发生变化，法国法院便重新界定合同相对性原则，认为不应以合同相对性原则为由否定第三人侵害债权的侵权责任。在 1908 年的 Raudnitz v. Doeuillet 一案中，法院首次允许合同债权人以《法国民法典》第 1382 条的规定为依据向第三人提起侵权诉讼。在该案中，巴黎时装设计师 Doeuillet 挖走

[①] Willem H. van Boom, Pure Economic Loss: A Comparative Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.9.

[②] 王文钦：《论第三人侵害债权的侵权行为》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第 6 卷），法律出版社 1997 年版，第 760 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Raudnitzo 数位高级雇员，1901 年 6 月又与 Raudnitz 雇佣的饰边师 Richard 女士签约，答应给其优厚薪水，并同意补偿 Richard 因违反其与 Raudnitz 之间的雇佣合同所应承担的违约责任。在 Richard 履行后一个合同之前，与 Raudnitz 又重新达成协议，Raudnitz 为 Richard 增加薪水，并支付其违反与 Doeuillet 之间所签订的合同应承担的违约金 10000 法郎。之后，Raudnitz 起诉 Doeuillet，要求赔偿损失，即原告为了留住 Richard 所额外支付的费用。1908 年法国最高法院判决认为，被告 Doeuillet 以承诺补偿 Richard 违反与原告 Raudnitz 签订的前一个合同所导致的损失为条件，从而“促使”其违反前一个合同，故被告对此应该承担侵权责任。于是最高法院维持巴黎上诉法院的判决，明确主张不能以被告与原告之间无合同关系为由而否定被告承担责任。最高法院认为，“对于前一个合同来说，被告 Doeuillet 是合同之外的第三人，因此上诉法院的判决并不是让被告 Doeuillet 承担违约责任，而是让其对自己的故意为自己谋利的侵权行为承担责任，正是其这种诱使违约的行为导致并促使了合同债务人违反前一个合同。”此案中 Raudnitz 原来也以不公平竞争为由起诉 Doeuillet，但由于未能证明被告存在“恶意”，巴黎上诉法院未予认可。因此如果在该案中坚持合同的相对性原则，则对原告有失公允，也违反了法律的公平和正义精神。正是基于此种利益平衡和价值判断，法院直接依据《法国民法典》第 1382 条之规定判决被告承担侵权责任，从而否定了以合同相对性原则为由而排除第三人承担侵权责任的观点。[①]

后来，在另外一些案例中，法国法官也依据 Doeuillet 案确立的原则进行判决，从而建立起了故意干涉他人合同的诉讼制度。在现代法国，此种诉讼制度并不限于某一种类型的侵犯合同关系，只要行为人干涉了他人的合同关系，就应该承担侵权责任，因此法国民法建立起了不可侵犯合同的一般原则，且将之适用于非常广泛的领域。[②]

法国通过判例确认了合同具有绝对效力，认为，第三人不得非法干预他人之间的合同关系，明知他人之间有合同关系而依然引诱他人违约、妨害他人履行合同义务或干预他人合同关系并因此导致合同债权人经济损失的，第三人必须对合同债权人承担侵权损害赔偿责任。第三人对他人合同利益的尊重，主要保护的是对合同债

[①] 王文钦：《论第三人侵害债权的侵权行为》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第 6 卷），法律出版社 1997 年版，第 760-761 页。

[②] 张民安：《第三人契约性侵权责任研究》，载《中山大学学报》（社会科学版），1997 年第 4 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

权人的纯粹经济利益，因此是对纯粹经济损失提供保护的重要方式，是现代侵权行为法效力拓展的重要表现，也是现代法律效力扩张的重要表现，具有重大的理论及实践意义。[①]

（二）过失侵权法对经济利益的保护

法国财产上的损害可以分为被害人的总体财产因侵权行为的发生而积极地减少，以及本能够正当合理期待增加而未增加的消极地减少两种情形。前一种称为“所受损害”，后一种称为“所失利益”。《法国民法典》第1149条明文规定所谓“损害”包括“所受损害”与“所失利益”二种，该条规定：“债权人之损害赔偿额一般而言是指其所遭受之损失与其被剥夺之利益”。[②]

由于所失利益经常涉及种种“期待利益之落空”、“商业利益之侵害”或“纯粹经济损失”，此种利益丧失的形态复杂多样，其是否确实存在及范围如何，经常难以认定，而且如果一律允许对所失利益的赔偿，是否会过度加重行为人的损害赔偿责任，并且涉及如何适度合理的限制承担损害赔偿责任者的责任范围问题，是各国侵权责任法上所共同面临的难题。然而，这个问题在法国实务的演变发展过程中一直不成为问题，因为法国实务上一向将所受损害与所失利益的赔偿等同视之，似乎并没有特别限制所失利益的损害赔偿责任。换言之，各种期待利益、商业利益或纯粹经济利益之丧失是否能够请求赔偿的问题，法院审判实务在认定上大多采取“自由宽松”的立场，并没有限定以被害人的“人身”或“物”直接受到侵害为前提，也不问此种利益丧失是否为同一被害人的“人身”或“物”被侵害所造成的结果，也不区别当事人间是否有合同关系，不问是基于违约责任或侵权责任请求赔偿，也不问加害原因、加害情节或加害人故意或过失的严重程度，原则上均肯定此种利益丧失属于一种能够请求赔偿的损害。[③]

法国判例认为，如果被告侵犯了原告的财产并因此而导致原告收入的减少，原告有权要求被告承担损害赔偿责任；同时，即便是对财产的损害所产生的后果，只是一种纯粹经济损失，原告也有权要求被告承担侵权损害赔偿责任。这在众多的案例中得到说明。在1965年的交通堵塞案件中，由于被告的过错导致了一起交通事

[①] 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社2007年版，第68-69页。

[②] 陈忠五：《法国侵权责任法上损害之概念》，载《国立台湾大学法学论丛》第30卷第4期，国立台湾大学法律学院出版社2001年版，第26-27页。

[③] 陈忠五：《法国侵权责任法上损害之概念》，载《国立台湾大学法学论丛》第30卷第4期，国立台湾大学法律学院出版社2001年版，第27页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

故的发生，从而使马赛市中心的交通被阻塞，原告为一家公交公司，因此导致其公交车无法正常发车，减少了载客量而导致营业损失。于是原告起诉被告要求其就原告的营业损失承担赔偿责任。被告辩称，原告就塞车时间与损失的计算，只是一种假设而且为间接的损失，但法院认为，马赛市民平时不需要耗费很多时间来等候公车，然而却因被告的过失，造成相当长时间的塞车，并使原告的公交车延后发车，因此而减少了车票收入，这种损害并不是假设也不是间接的。因此，法国最高法院作出判决，由于被告引起的交通事故导致原告公司的公共汽车被耽搁，被告应当赔偿原告因此而减少的收入损失。[①]

在 1970 年挖断天然气管道的案件中，被告在从事公共工程建设时，其推土机不慎损坏了原告的天然气管道，中断了原告的天然气供应并因此导致原告的工厂停产，原告根据《法国民法典》第 1382 条和第 1384 条的规定，要求被告对自己因为停产而减少的收入损失承担赔偿责任。法国最高法院认为："在确认双方当事人对事实无争议以及此种诉讼应当建立在《法国民法典》第 1382 条和第 1384 条的基础上之后，上诉法院认为，原告所遭受的损害是天然气管道中断所造成的直接后果，因为此种天然气的中断导致了原告被迫停止经营活动，因此，原告的损害与被告的行为之间具有直接的因果关系，上诉法院的这种判决是建立在正确的法律基础之上的。"因此法国最高法院认为，如果被告在施工时破坏了天然气管道并由此中断了原告的天然气供应，导致原告因停产而遭受收入损失，被告应当承担侵权损害赔偿责任。[②]

法国行政法院也遵守同样的原则。在著名的电缆案 Conpagnie Générele de Travaux Hydrauliges (SADE) v. Soci été Thomson – Houston – Hotchkiss - Brandt (STHHB)案中，被告 SADE 在进行公共工程的施工时，其雇员过失切断了专为原告公司 STHHB 提供电力的但属于法国电力公司的电缆，因此，原告被迫停止生产 1 小时零 10 分钟。因为原告与其电力供应商之间所签订的电力供应合同中对此种损害做了极大的限制，所以原告没有对法国电力公司提起合同之诉，而是对 SADE 提起侵权之诉，要求它对自己的损害承担责任。法国行政法院认为，"原告 STHHB 所遭受的损失是被告 SADE 在进行公共工程施工时所造成的直接后果。由于暂时性的

[①] 参见邱琦：《纯粹经济上损失之研究》，国立台湾大学法律学研究所 2002 年博士论文。
[②] 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社 2007 年版，第 56-57 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

电力供应中断对原告所造成的停产影响，一审法院对原告所遭受的损害做了正确的评估并且判决被告加以赔偿……”。[①]

从上面的案例可以看出，即使经济损失不是因为对财产的有形损害所导致的，而是所谓的纯粹经济损失，法国判例也认为它们是侵权行为的直接后果，原告可以要求被告承担责任。[②]

三、责任控制工具

法国民法典中侵权行为法的一般条款规定非常宽泛，因为授予了法官相当大的自由裁量权，法官可以依据社会发展的需要来创设法律规则，而且法国法更是依赖于法官的造法行为，来对纯粹经济损失提供保护。法国法官通常不会费尽心思地去分析，损害的性质是有形的还是无形的，或只是纯粹经济损失性的，而是一视同仁地对待每一个损害案件，即都是以过失或危险为基础。因此，法国法院并不像英美法或德国法一样，发展出一套独特规则体系来处理纯粹经济损失问题，而只是根据侵权责任的构成要件，即损害、过失、因果关系，对每一个具体的侵权案件进行处理。[③]

与英国侵权法和德国侵权法不同，法国侵权法也保护因他人过失所造成的经济损失，允许受害人对此提出侵权法上的赔偿请求。虽然法国法官们，并没有在他们的赔偿判决中提及经济利益，但是，他们显然愿意判处英国案例不愿意在过失侵权行为中判处的纯粹经济损失，只要这些过失所导致的经济损失符合“确定性”和“直接性”的要件。[④]由于法国民事责任普通法上的损害概念原则上是一种“主观的损害”，而赔偿原则采用“全部赔偿原则”或“损害与赔偿相当原则”，导致加害人承担的赔偿责任过于严苛，因此，法国法主要是使用“确定性”和“直接性”来作为责任控制工具。

（一）损害的确定性

所谓损害的确定性，是指在某一基准点时，损害必须确定存在。基准时点以前已经发生的损害，属于“现在的损害”，是确定存在的损害。基准时点以后才会发

[①] 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社 2007 年版，第 57 页。

[②] 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社 2007 年版，第 57 页。

[③] 朱广新：《论纯粹经济上损失的规范模式——我国侵权行为法对纯粹经济上损失的规范样式》，载《当代法学》2006 年第 5 期。

[④] 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社 2007 年版，第 55-56 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

生的损害，还没有现实发生，仅是一种可能会发生的损害，此种“将来的损害”是否具有确定性，不能一概而论。关键在于，因时间经过而导致未来的人、事、物状况不确定的因素，在损害继续实现过程中所占的比例或份量。也就是说，应该以损害在将来“发生的可能性”的“或然率的高低”，来决定“将来的损害”是否能够请求赔偿。假如损害虽然不是绝对不可能发生，但其可能发生的或然率太低或偶然性太高，则仅是一种单纯的或主观的假设或臆测而已。此种损害，属于一种“假设性”或“臆想性”的损害，不具有“确定性”，不能请求赔偿。反之，如果损害不但可能发生，而且依据一般客观事实，其可能发生的或然率相当高，则此种损害，属于一种“潜在性”或“展望性”的损害，具有“确定性”，能够请求赔偿。[①]

在法国，可予赔偿的损害应当是确定性的损害，而不能是不确定性的损害。但事实上，哪些损害属于确定性的损害，哪些损害属于不确定性的损害，则是很难明确加以区分的。对于今天的法国法官而言，损害的确定性得到了拓展，即只要有足够的可能性，即为损害的确定性。总的说来，实际发生的损害当然具有确定性，因此，可以予以损害赔偿，而对于未来的损害、假想的、或然的损害以及机会的损失是否具有确定性，则不无困难。[②]

1．未来的损害

在法国，即便是未来的损害，还没有完成的损害，但只要此种未来的损害是必然会发生的话，则也具有确定性，至少就法律而言具有确定性。相反，如果未来的损害是可以避免的话，则最好的办法是采取预防措施以避免此种损害的发生，而不认为其具有确定性。根据法国判例法，未来的损害是一种确定性的损害，因此，它与所谓的或然性损害不同，或然性损害即一种臆想性的损害，不具有确定性，因此，不能予以赔偿。法国判例指出：“虽然法官不可能就纯或然的损害判处损害赔偿金，但是，如果此种损害是未来的损害，则应另当别论，在此种情况下，法官在事实上将此种损害看做是某种状态的物的确定性和直接性的后果，看作是可以立即加以确定的损害。”[③]例如，那些因他人的侵害而遭受残疾的人可以要求他人赔偿其在未来的岁月中将要遭受的损害，此种损害即为未来的损害，具有确定性，应该给予赔偿。

---

① 陈忠五：《产前遗传诊断失误的损害赔偿责任》，载《国立台湾大学法学论丛》第34卷第6期，国立台湾大学法律学院出版社2005年版，第91页。

② 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社2007年版，第131页。

③ 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社2007年版，第131-132页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.“机会损失”理论

在法国，作为可以赔偿的损害要具有确定性，非确定性的、臆想性的损害等均难以获得损害赔偿。介于此种确定性和臆想性的损害之间的损害即为中间损害，这种中间损害能否得到赔偿，在法国法中则不无疑问。为了提高受害人的地位，法国最高法院提出了著名的“机会损失理论”。此种理论主要适用于获取某种利益的可能性被剥夺、丧失避免某种损失的机会等。学者认为，机会损失理论虽然适用于丧失获得某种利益的机会和丧失避免某种损失的机会两个领域，但是它主要适用于前一种领域，在这种情况下，获得某种利益的机会的损失就不再仅仅是一种或然性的损害，因为获得利益的机会代表着受害人的财富，在其财产中已经具有了一种可以依据可能性来予以计算和确定的价值。[①]

在法国，有关机会损失的判例很多。例如，1961 年的法国判例认为，侵害人的侵害行为导致原告丧失了参加考试的机会，原告可以要求侵害人对未能参加考试而导致的损失承担赔偿责任。到了 1969 年，法国判例确认，因为外科手术而丧失了痊愈或生存机会的那些人，有权要求外科医生对自己的此种机会损失承担侵权损害赔偿责任。在 1989 年，法国判例又确认了因丧失获得某种程序保障的机会的人对他人提出机会丧失的赔偿请求。进入 20 世纪 90 年代以后，法国司法判例又在丧失职业晋升机会的领域里适用机会丧失理论，认为，如果受害人因为死亡或身体受到伤害而导致了职业晋升机会的丧失，即使此种晋升机会相对而言是不确定的，受害人也有权要求侵害人对自己的机会丧失承担损害赔偿责任。法国一份具有相当说教性的判例指出：“机会丧失这种损害具有直接性和确定性的特征。”[②]

（二）损害的直接性

《法国民法典》第 1151 条规定，虽然因为债务人的欺诈而没有履行债务，债权人就所受损失和所失利益的损害赔偿，仅以不履行合同而直接发生者为限。此种规定虽为合同性规定，但也同样适用于侵权损害赔偿领域。因此在法国，要求损害必须是某种事件的直接后果，损害同损害事件之间不应间隔太远。学者认为，损害的直接性要件表面上看是要求在过错与损害之间必须存在因果关系，但是，当人们要求损害具有直接性时，通常是为了排除那些间接受害人的损害赔偿请求权，因此，

[①] 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社 2007 年版，第 132 页。
[②] 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社 2007 年版，第 132-133 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

损害的直接性与因果关系是有区别的。在法国，人们通常认为，当第三人实施侵权行为而导致债务人死亡并因此而使债权人的债权不能获得清偿时，该债权人不能以如果债务人活着，其债权即可获得清偿为由而要求侵害人对自己的债权承担损害赔偿责任。这是法国判例所确立的规则，也是法国学者所明确承认的规则，因为债权人所遭受的损害是一种间接损害而非直接损害。[①]

第四节　纯粹经济损失处理模式的分析比较

一、英国模式分析

英国法官们在处理纯粹经济损失问题时，表现出了很大的谨慎，采取实用主义的态度，因此英国法是作为实用主义体系的代表，类似的国家还有英格兰及荷兰。

由于英国僵化的合同法对对价的坚持，它不能保护法律上的陌生人，使其免于经济损失。因此，在英国对于纯粹经济损失的保护所面临的选择就是或者偶尔扩张其侵权行为法，或者完全否认这些诉讼。

大陆法中的侵权法规范通常采取“一般条款”或“限制性一般条款”模式，而英国法则与此不同，其侵权行为法并没有一般性的概括条款，而只是采取列举方式，创造出很多案型来解决实际生活中出现的各种侵权行为。其侵权行为法体系包括类似故意侵权的古代侵权行为与类似过失行为的现代侵权行为，其中有一系列故意经济侵权行为，如欺诈、侵害贸易、诱使违约、假冒、公共机构里的不当行为、威吓和共谋等。如果被告故意引起了该类损失，则对纯粹经济损失的请求权就可以依据这些侵权行为而得到赔偿。然而，如果损失是由于过失行为所导致的，就不能依据这些诉讼类型。因此，原告最主要的救济途径必然是过失行为法。

在著名的唐纳格布诉斯蒂文森（Donogbue v Stevenson）案中，Atkin 勋爵阐明了非常著名的“邻居法则”。根据这个规则，一个人在他应该合理的预见损害发生的可能性但并没有尽到合理注意的时候，他就负有相应的注意义务，并因此应该对损害后果承担相应的责任。在此后的许多年里，以此法则为基础，可预见性都被认为是判断注意义务的标准。[②]此后该类侵权行为已经被视作涵盖各种过失行为的一

---

① 张民安：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社 2007 年版，第 133-134 页。

② 彼得•凯恩著，王仰光、朱呈义、陈龙业、吕杰译：《阿蒂亚论事故、赔偿及法律》，中国人民大学出版社 2008 年版，第 69 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

般条款。在对实际损害（人身伤害或财产损害）提供保护的领域，有关情形原则上是如此。但 Murphy v Brentwood DC 这一权威判例指出，过失侵权行为并非主要适用于纯粹经济损失赔偿。这意味着原告遭受损害的性质决定了防止纯粹经济损失发生的义务是否存在。然而，最近在涉及经济损失责任的案件中，上议院已经开始对上述标准进行细化，在一系列案件中，发展出了对注意义务进行界定的三重标准：首先，被告没有采取合理注意而导致原告可能遭受某种损害后果是否具有预见的可能性；其次，在原告和被告之间是否存在充分的密切关系；最后，在本案的任何情形下，要求被告承担此种义务是否公平合理。[①]因此英国法官们只有基于功利主义理由满意地认为从社会和经济角度都适于这么做的时候，他们才会愿意在特定的个案里确定“注意义务”。其深层的疑虑是基于对责任过于宽泛的担心。

事实上，普通法以任何人原则上并不负有防止纯粹经济损失发生的义务这一原则作为起点。对这一义务加以承认仅是例外情形，这些例外情形只涵盖狭窄的事实领域，其肇始于 Hedley Byrne & Co. Ltd. v Heller & Partners 一案。到目前为止，例外仅限于受到信赖的过失不当陈述行为（在存在事实合同的情况下）、过失干扰合同履行、为前雇员写推荐信时的过失侵害名誉行为、起草遗嘱时的职业过失行为以及违反制定法义务的行为。这些例外的一致特点是将被告的责任风险定量限制于确定数目的原告，或者更好的情况下是单一的原告。[②]这样，无限经济动荡之危险得以避免。此外，还要求存在比经济损害的可预见性更能够证明当事人之间存在更密切联系程度的其他因素，如被告需要对原告的经济福利承担责任且原告对此信赖。这样，纯粹经济损失赔偿请求权人的范围受到限制，如同看不见的相对性范式构筑了侵权法中的因果关系。[③]

英国法官们以开放的态度表达了他们的实用主义。政策裁量并没有被掩盖在因果关系或归责性的特定观点之下。英国法官们拒绝通过邻居原则的逻辑含意而被推着去承认宽泛的过错理论。除了相关性和可预见性，需要有其他一些事项，以在财产损失的领域起用“注意义务”的概念。英国法官愿意继续在普通法的发展中充任

[①] 彼得•凯恩著，王仰光、朱呈义、陈龙业、吕杰译：《阿蒂亚论事故、赔偿及法律》，中国人民大学出版社 2008 年版，第 69 页。

[②] [意]毛罗・布萨尼、[美]弗农・瓦伦丁・帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 104-105 页。

[③] [德]克里斯蒂安・冯・巴尔、乌里希・德罗布尼希主编，吴越等译：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，法律出版社 2007 年版，第 115 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

建筑师的角色。[①]

在英国法，尤其在设计财产损害的侵权法案件里，法律政策的适用是普通法系内部文化的一个明显特征。然而，英国的法律政策不能与类似法官的公共政策或德国的诚信原则等大陆法系概念混淆在一起。英国的法律政策概念不假定一项据以在司法适用里进行限制的法律规则，而是为当下审理的案件及未来创设一项规则。而且，每次求助于法律政策的时候，这项规则都会发生变化。[②]

因此，英国合同法由于对价的坚持，对于纯粹经济损失的保护只能适用侵权行为法，但普通法的传统是对纯粹经济损失不予赔偿，后来司法上出现了松动，但条件却一再变动，现在基本上是基于注意义务的认定 ，但背后仍有法律政策的考虑。综上，英国法对于纯粹经济损失问题的处理可以概括为：普通法的不赔传统，司法的波折反复和侵权法的救济偏好。

二、德国模式分析

德国对于纯粹经济损失问题的处理方式最主要的特点是有限的侵权法与宽泛的合同法，体现了保守主义的特点，类似的国家还有奥地利、葡萄牙、瑞典及荷兰。

《德国民法典》第823条，采取“绝对权利”的清单方式，有意排除了任何对纯粹经济性质之损害的赔偿。因此，作为一项规则，纯粹经济损失在侵权行为法里得到赔偿是不可能的。侵权法里只有一些例外情况，但原告必须在《德国民法典》第823条之外的条款里去寻找诉因。虽然德国侵权行为法自其制定，一个世纪以来没有什么变化，但判例法出现了很多实际的变革。如，德国侵权法虽然要求有侵害权利（“绝对权利”）的行为，但通过扩张解释在传统的权利里加入了新的权利，如“营业权”。其次通过把纯粹经济损失解释为应属制定法目的范围的方式，把第823条第2款关于侵害“其目的在于保护他人之法律”的行为的措辞变成了允许就该等侵权行为产生之纯粹经济损失进行赔偿的途径。最后，对第826条的主观意图进行宽泛解释，认为“如果他意识到在行为时可能发生损害的可能性且对此默认”即可，而无需认定“被告有实际的致害意图”。然而此规则适用的情形有限，通常只适用

[①] [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第105页。

[②] [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第105页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于：第三人在合同一方当事人违约行为时的参与行为、为获得个人利益而以其他债权人的利益为代价延迟某人的破产、在有义务提供信息的场合提供了错误信息或未能提供信息。[①]

由于侵权行为法未能对纯粹经济损失提供有力的保护，于是德国法官开始广泛地利用合同救济。扩大合同法的作用有三方面的原因：首先，是由于侵权法被认为在保护需要法律救济的所有经济利益方面过于薄弱和狭窄。其次，合同法请求权似乎没有打开诉讼闸门的风险，因为在违约情况下发生无限损害的危险较少。最后，德国合同法中不存在可预见损害赔偿规则。[②]

德国法官和学者扩大了合同责任的范围，突破了《德国民法典》确立的界限，将合同义务的范围扩张至默示的注意义务，并且这些义务可存在于合同缔结之前（即缔约过失责任），也可存在于合同终止或履行之后。最重要的革新在于法官和学者降低了合同的相对性限制，使这些义务也可用于保护非合同当事人。其中最主要的手段是创设“附保护第三人作用之合同”，将合同之外的第三人置于合同的保护范围，使其能够对合同当事人违反合同附随义务的行为，尤其是导致纯粹经济损失的行为提起诉讼。附保护第三人作用之合同的功能类似于侵权行为法，因为受其保护的第三人与合同当事人之间无需存在密切的个人联系，也无需事先将第三人特定化。同时，此类合同也不受德国侵权法中的“绝对权利”要件影响，因而允许对纯粹经济损失进行赔偿。目前，所有这些规则在德国法中均获得了牢固的立法，并且大多数规则都被德国新债法所采纳。因此，在英国视为纯粹侵权问题的许多案件，在德国是通过合同之诉来得到处理。[③]

综上，德国法对于纯粹经济损失问题的处理可以概括为：立法的拒绝赔偿、司法的松动和契约法的救济偏好。

三、法国模式分析

《法国民法典》第1382条和第1383条的理论基础是“不得伤害他人”这一基

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第110-111页。

② [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编，吴越等译：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，法律出版社2007年版，第62页。

③ [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编，吴越等译：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，法律出版社2007年版，第117页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本原则，其并未事先对受保护的权利及利益的范围和性质作出限制，也未事先对受保护群体的范围作出限制，而且由于这一原则的外延宽泛，内涵又不确定，所以并未排除纯粹经济损失的赔偿责任。一般认为，法国的一般条款反对通过探求法律规则之目的来确定被告责任范围的学说。但法国法并不像英国法那样有相关“义务”的要求，因此因果关系的作用并未被弱化。其不法性的这一概念几乎看不见了：因为它已经完全渗透到过错、损害以及因果关系这些具体的责任要件里了。然而在自由裁量的层面，政策的适用更难以被预测到，因为法国在该层面并不创设例外，而只是把某一特定案件的否定结果归罪于因果关系过于薄弱或者原告的损失不够确定。这里不法性不是一个可分割的障碍因素，而只是适用行为、过错、损害以及因果关系这些具体责任要件的结果。在这个层面拒绝对纯粹经济损失进行救济的裁判是不为法学研究所知的。但是显然潜在的对于侵权行为人可能承受过度责任的关注影响了这些判决，但没有人能肯定这点。①

法国法的一个独特之处是其合同和侵权概念互不重叠，这一规则在整个欧洲都是独一无二的，它也许推动了法国法朝着允许纯粹经济损失获赔的方向前进。对于一个其一般侵权条款将纯粹经济损失纳入规范范围的制度而言，该规则因其给该制度带来了适用的确定性而受到称赞，否则就会缺乏理论工具来防止漫无边际的竞合或从其适用范围里排除纯属合同的损害。另外此规则还有另外一个重要作用，这个强制选择鼓励了认为合同法和侵权法应该以相同的方式动作，因此法国法的规则倾向于缓解对纯粹经济损失的反对意见，而能让人预期侵权法和合同法一样可以获得同等的结果。②

法国法所表现出来的表象是：对纯粹经济损失最大限度的容许以及对那些在其他国家通常用来反对赔偿之强硬政策论辩最大限度的无动于衷。综上，法国法对于纯粹经济损失问题的处理可以概括为：宽松的立法、苛重的赔偿责任和侵权法的救济偏好。

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 94-96 页。

② [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 96-97 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

四、三种模式的比较

英国、德国和法国分别作为实用式体系、保守式体系和放任式体系的代表，对于纯粹经济损失问题的处理各有其独特之处。虽然路径方式不同，但对于很多案例的处理结果却是相同的，其分歧并没有象看起来这么大。

首先，放任式体系和实用式体系虽然有着显著的理论和实践上的不同之处，但他们最终还是通过侵权法内在的技术对纯粹经济损失进行筛选和优化。而德国法律制度甚至排除了对纯粹经济损失的事前通道，这一预防作用体现在其仅规划了对某些列明权利之侵害责任的文本里。因此，对于纯粹经济损失的救济，英国和法国采用侵权法的方式，而德国更多的是运用合同法的方式。

其次，英国作为实用式体系的代表，重要的特征就是谨慎的个案分析方法。该方法仔细研究就纯粹经济损失给予赔偿所具有的具体社会经济含意。对赔偿做出选择的主要方法是通过“注意义务”的概念。注意义务问题是法官们公开贯彻的司法中政策制定事项。每一个新情势都要求有特别的判断，以确定到底是否存在防止损害的义务。除非这一问题得到肯定的判断，否则没有理由走进一步的程序去考虑侵权责任法的通常要求是否得到满足。[①]英国法官们以开放的态度表达了他们的实用主义。政策裁量并没有被掩盖在因果关系或归责性的特定观点之下。[②]德国由于侵权法对纯粹经济损失救济的局限，而合同法却有相当的灵活性，于是德国法中的纯粹经济损失的赔偿时常得到合同法和其他制定法机制广泛的外部支持。法国法的一个难以察觉和确定的特征，为可使用隐蔽的技术手段将责任问题加以控制。法国的法官即便像一些观察家所猜测的那样采用任何政策来限制纯粹经济损失的赔偿，他们也不会公开加以限制，更不会公开承认。法官通过对一般条款的一般要件（尤其是因果关系要件）巧妙地加以处理来秘密运用此类政策，但这种司法倾向是不公开承认且不确定的。[③]

最后，法国与其所采用了最宽泛的一般责任条款相配套，采用了独特的禁止竞合原则，其合同和侵权概念互不重叠，而英国和德国则是允许竞合的。

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 92 页。

② [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 105 页。

③ [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编，吴越等译：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，法律出版社 2007 年版，第 110-111 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章　纯粹经济损失赔偿责任的排除、成立与限制

纯粹经济损失是一个不产生于对人（生命、身体、健康、自由或其他人格权）的伤害或对财产（有形和无形财产）损害的损失。如前面章节分析所显示的，很多法律制度对于纯粹经济损失的赔偿非常不情愿。我认为解决纯粹经济损失责任问题的关键在于下面问题的答案，为什么侵权法区分保护对人身或财产的损害及纯粹经济损失，为什么对人身和财产的保护要比对纯粹经济损失的保护慷慨得多，责任排除规则背后的政策考量究竟是什么，哪一些纯粹经济损失类型是不受责任排除规则约束的。通过对这些问题的回答，希望可以从中找出成立纯粹经济损失赔偿责任的重要因素，以寻找解决纯粹经济损失赔偿问题的可能方案。

第一节　区分保护的原因

冯·巴尔教授在总结纯粹经济损失的概念时，指出其第二个流派是将纯粹经济损失认定为非作为权利或受到保护的利益侵害结果存在的损失。[①]从这个定义里也揭示出了纯粹经济损失所侵害的利益，并非权利也非受法律保护的利益，因此就包含了一个法律命题——纯粹经济损失不在赔偿范围内，也即纯粹经济损失的基本赔偿规则为责任排除规则（the exclusionary rule），指对于案件中产生的纯粹经济损失原则上不予赔偿。因此纯粹经济损失概念与责任排除规则是相对应的，提出纯粹经济损失概念的目的就是把属于纯粹经济损失的各类损害置于赔偿范围之外。[②]

很多法律制度将对人身和财产的有形损害及纯粹经济损失予以区别保护，而有些国家虽然法律没有明文规定对这两种不同的损害予以区别保护，但是在对纯粹经济损失进行赔偿时，也往往会以各种理由，如因果关系的远隔性等来拒绝赔偿，其拒绝的背后仍有政策的考量。在前面章节的分析基础上，我们将总结一下对这两种损害予以区别保护的基本原因。

[①] [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔著，焦美华译：《欧洲比较侵权行为法》（下卷），法律出版社 2001 年版，第 33-34 页。

[②] 张新宝：《侵权责任构成要件研究》，法律出版社 2007 年版，第 171 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

一、诉讼闸门

在人身伤害和财产损害的案件中，很容易通过物理规律的运作来实现确定责任的限制，摩擦和重力决定了物体运动最终会停止下来。由高速行驶的汽车和拳打造成的实质损害的量是有自我限制的，即使在发生连锁反应的案件中，介入力通常对于使施害物体的运动停止下来是有必要的。这些介入力提供了对责任的一个自然限制。[①]

然而物理规律并没有为经济损失提供同样的限制。经济关系是如此紧密地相互交织在一起，以至于其中一个破裂可能将产生影响深远的结果。此外，经济损害的连锁反应在没有其他力量介入的情况下从一个人流向另一个人。法院面对着的纯粹经济损失案件，因而面临着无限大范围之责任发生的可能性，既没有一个容易被作为标记的中间点，也没有准备求助于像介入原因这样的传统责任限制的工具。[②]因此，纯粹经济损失案件中受害人的数量、损失的范围可能极为广泛，由此可能引发的对“诉讼闸门”的疑虑，是将纯粹经济损失置于可赔偿范围之外的主要理论依据。

诉讼闸门论据实际上基于三个不同的理由：第一个理由是认为在一些案件中如果允许对纯粹经济损失进行赔偿，可能会有无数的原告，因此导致无数的诉讼以致于法院将不堪重负。第二个理由是担心普遍宽泛的责任将给被告过重的负担，会使被告承担的责任与其过错程度完全不成比例。第三个理由认为现代法律的一个大趋势是扩展侵权责任，而纯粹经济损失只是这个大方向的一部分，而这一趋势应该得到控制。[③]

然而，Jaap Spier 和 Oliver Haazen 正确地提出这个问题：“但是如何对导致周围人经济损失的油厂爆炸的受害人解释，如果他们仅仅遭受经济损失（利润的损失），则他们的索赔将被驳回，而如果他们的机床被卡住而只不过产生非常少的修理费用，则会满足其索赔请求？”他们指出，对财产的损害甚至人身伤害可能产生巨大的影响。然而，从个案的情况看，诉讼闸门论据往往具有很少的重要性。因为大部分的意外事故并没有产生一系列的损失，他们会问，为什么诉讼闸门论据在这类案

---

① [美]D. W. Roberston 著，刘慧译：《义务的新领域：纯粹经济损害》，载张新宝主编：《侵权法评论》2003 年第 1 辑，人民法院出版社 2003 年版，第 182-183 页。

② [美]D. W. Roberston 著，刘慧译：《义务的新领域：纯粹经济损害》，载张新宝主编：《侵权法评论》2003 年第 1 辑，人民法院出版社 2003 年版，第 183 页。

③ 参考[意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 13-14 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

件中禁止索赔。[①]

答案可能是对于纯粹经济损失的赔偿不能仅仅依赖于具体原告的损失是大还是小。实际上，如果我们检查竞争法，我们会发现起决定性的不是导致竞争者的损失数量，而是不公正。损失的数量不相干的原因是，如果极小的损失将得到赔偿而遭受非常严重损害的受害人必须自己忍受这些损失，则是不能令人满意的。从受害人的观点看，将是相反的，因为一个严重受损害的受害人比只遭受极小损害的人，更迫切需要保护。然而，水闸（诉讼闸门）论据并不仅基于此想法，即单一案件中受害人的赔偿金数额可能是巨大的。这产生于以下事实，即原则上如果人身伤害或对财产的损害能够归责于侵权行为人，则其必须赔偿所有随之而生的纯粹经济损失。而且，如果单独此论据就是决定性的，问题可以通过对责任强加最高限额而得到解决。当然，只在纯粹经济损失案件中如此做则是不一致的；同样的论据也适用于人身伤害或财产损害案件。但是如果后类损失是由被告的过错导致的，则这样的限制是不被赞成的；只在严格责任中，一些法律制度强加责任限额。这说明在特殊案件中的损失数额不能因为水闸（诉讼闸门）论据就被认为是决定性的因素。[②]

而且，如果原告损失的巨大数额是诉讼闸门论据中唯一重要的因素，被 Jaap Spier 和 Oliver Haazen 提出的附加问题则是令人非常不安的。他们评论说："实际上，侵权行为法的目的是赔偿不当行为导致的损失。为什么对于纯粹经济损失则不同？"实际上，这似乎是不合理的，一个导致财产损害的不当行为人必须赔偿修理的费用，而对于他错误行为导致的纯粹经济损失则没有责任。[③]

其次，当法院认为受害人过多因而被告不应当承担责任的话，则无异于嘲讽法律的无能。法律存在的目的就是要使那些应该得到救济的不当行为得到法律的救济，而不论其成本大小，即使其成本是"洪水般大量的请求"，该救济的还是应该得到法律的救济；任何法院都不能以担心给自己带来太多的工作为由而拒绝救济，这只能是对自己无能的承认。[④]

最后，如果一个人对于纯粹经济损失负有广泛的义务，则几乎永远会有大量的

---

① Helmut Koziol, Compensation for Pure Economic Loss from a Continental Lawyer's Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.142.

② Helmut Koziol, Compensation for Pure Economic Loss from a Continental Lawyer's Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.142.

③ Helmut Koziol, Compensation for Pure Economic Loss from a Continental Lawyer's Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.143.

④ William Prosser, International Infliction of Mental Suffering: A new Tort, (1939) 37 Michigan Law Review, 874, at 877. 转引自余艺：《过失致人纯粹经济损失不予赔付规则及其突破》，载《政治与法律》2007 年第 1 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

原告，因此，每个人都将会由于过失行为而承担不可估量的风险，这将导致过度威慑，并且将会不合理的限制所有个体的行为自由。因此对自由的过度限制，只有通过不向人们施加对他人纯粹经济利益的注意义务，才能得到避免，所以纯粹经济损失只能在有限的范围内得到保护。然而，有人会问：哪些理由能够解释对纯粹经济损失不负有注意义务，及在何种程度上是令人信服的。这很难回答。

二、维护人们的基本行为自由

由于权利是否存在，其主体、内容或范围如何，一般而言相当具体特定，因而在侵害权利的情形，行为是否可能造成损害、被害人为谁、损害规模或范围多大等，一般而言加害人可以事先知悉或合理预见。因此，在侵害权利的情形中，经由“权利”被侵害此一概念为媒介，责任是否成立、责任范围如何，均在加害人可以合理预见的范围内，制度设计本身已经足以适度合理限制加害人的责任，不至于动辄对加害人造成庞大的、难以负荷的赔偿负担。在权衡“被害人权利保护”与“加害人行为自由”二项价值之后，法律政策上没有特别限制加害人责任的必要。[①]

反之，由于纯粹经济利益是否存在，通常不易察觉，利益的主体为谁，有时难以确定，利益的内容或范围如何，可能非常微小，也可能相当巨大，因而在侵害纯粹经济利益的情形中，行为是否可能造成损害、被害人为谁、损害规模或范围如何等，加害人通常事先难以知悉或合理预见。基于纯粹经济利益的这种难以具体特定的性质，可能会发生加害人在不易察觉利益存在的情形下，只因一时之疏忽不慎，却造成被害人人数众多，损害规范非常巨大，完全超出一般人可以合理预见范围的结果。从而，在侵害纯粹经济利益的情形中，责任是否成立、责任范围如何，容易发生失控泛滥现象，制度设计上无法借助于“纯粹经济利益”被侵害这个概念，来适度合理限制加害人责任，加害人可能动辄得咎，必须对众多不确定的被害人负担金额巨大、难以负担的损害赔偿责任。在权衡“被害人利益”与“加害人行为自由”两项价值之后，法律政策上确实有正视如何合理限制加害人责任的问题。[②]

同样是侵害“经济利益”的情形，将契约责任与侵权责任相比较，可以更好地

[①] 陈忠五：《论契约责任与侵权责任的保护客体：“权利”与“利益”区别正当性的再反省》，载《国立台湾大学法学论丛》第36卷第3期，国立台湾大学法律学院出版社2007年版，第152-153页。

[②] 陈忠五：《论契约责任与侵权责任的保护客体：“权利”与“利益”区别正当性的再反省》，载《国立台湾大学法学论丛》第36卷第3期，国立台湾大学法律学院出版社2007年版，第153页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

说明为什么侵权法上要限制对纯粹经济损失的赔偿责任。契约关系上的经济利益，原则上是由合同当事人双方经由合同予以自由约定创设的结果，其是否存在、主体、内容、范围等，当然相当具体特定，当事人均可以事先知悉或合理预见，并经过合同约定风险的合理分配，或者透过价格机能反映在交易对价上，或是透过保险机制分散转嫁风险。从而，债务人违反合同义务导致侵害债权人的“契约利益”时，契约责任是否成立，契约责任范围如何，通常在债务人可以合理估计的范围之内，债务人不至于动辄得咎，必须对众多不确定的被害人负担赔偿范围巨大到无法承受地步的损害赔偿责任。这就是为什么在契约责任中，法律政策上没有必要专为经济利益被侵害的情形，思考如何合理限制加害人责任这一问题。

而在侵权责任中，当事人在契约关系外，因某一侵权行为偶然地结合而发生“损害赔偿”这种债的关系，并未如契约责任一样，事先经过接触、磋商或谈判，有意识有目的地依照自由意志而发生债的关系。由于纯粹经济利益种类复杂多样，其是否存在、主体、内容及范围，通常不易确定，当事人也难以事先知悉或合理预见，当然也就无法建立合理分配风险或分散转嫁风险的机制。从而，行为人不法侵害他人纯粹经济利益时，侵权责任是否成立，侵权责任范围如何，通常不在行为人可以合理预见的范围内，如果将纯粹经济利益与权利完全等同视之，使其受到同等程度的保护，确实有可能使加害人动辄得咎，必须对众多不确定的被害人负担赔偿范围巨大到无法承受地步的损害赔偿责任。因此，对于侵害纯粹经济损失的情形，法律上确有必要合理限制其责任，否则将严重限制行为人的行为自由。

三、优越法益论据

通常人们认为人身法益的位阶在法律上要高于财产法益，财产法益中的有形财产价值的位阶又高于一般的财产利益，相比起经济损失而言，人身损害和有形财产损害更应当得到法律的保护，因为有形损害是永久的，人身损害甚至无法以金钱完全弥补，而经济损失并不一定构成社会损失，可能只是可得利益的丧失。《德国民法典》也正是以此观点来构建自己的侵权责任体系的，将权利与利益区别保护。[①]还有人认为，把经济损失纳入赔偿圈会挤出一些更重要的法益。[②]

---

① 李昊：《纯经济上损失赔偿制度研究》，北京大学出版社 2004 年版，第 55 页。

② 徐海燕、朱辰昊：《纯粹经济损失赔偿制度研究——兼论证券市场中介机构不实陈述的民事责任》，载《甘肃社会科学》2008 年第 3 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

哲学上的价值观认为，无形财富不应与身体完整权和物质财产一样受到同等保护。人比物重要，而物又比钱重要。法律根据不同利益的轻重顺序提供保护。认为“以人类价值观为基础的法律制度（假设该法律制度反映了社会的正确价值观）对有形财产提供的保护应大于对无形财富提供的保护。”[①]因此，主要的人格权等级最高；对物权和无形财产权等级稍低些。纯粹经济的利益，如获得利润的机会，在此级别的最末端。这个事实不利于对纯粹经济利益给予广泛保护，因为如果这样保护的话，则每个人的行动自由将会受到极大的限制。

另外，在界定应受保护的特定利益的范围时，除了考虑权利人希望自己的权利受到保护外，也还需要考虑行为人行为自由的利益及普通大众的公共利益。生命权、健康权、自由权、所有权有明确的内容并且外人很容易察知。合同权利仅在具体个案，其内容才可能明确，但也仅是双方当事人知晓，而第三人从外界很难知道合同债权的具体内容。纯粹经济利益即使在具体的个案中，通常也不具有确切的内容，且第三人从外界根本无法知晓纯粹经济利益是否存在及其具体的范围。[②]

如果对内容不明确且第三人难以知晓的法益，如纯粹经济利益给予广泛的法律保护，则会使他人承担过高的注意义务，会对他人的行为自由造成极不合理的限制。因此，对于法益的保护，尤其是纯粹经济损失的赔偿责任，应当予以适当限制，以维护行为自由。

四、保险因素

发达国家的保险业及保险意识都比较发达，很多人都投保，使大部分意外事故通过保险来获得赔偿。加害人可以投保第三者责任险，被害人可以投保意外事故险，而使自己遭受的纯粹经济损失获得保险金的补偿。因而，在现代社会中，分配的主要问题不再是财富，而是风险。对于此类案件，法院也经常着重考虑谁能够以最小的成本避免风险，通常也会将责任判给能够以更小的成本避免损失的一方。而对于纯粹经济损失案件，通常认为似乎受害人更能够通过投保意外事故险而分散风险，而加害人由于此前难以预见受害人之范围而难以投保第三者责任险。

[①] [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编，吴越等译：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，法律出版社 2007 年版，第 109-110 页。

[②] 海尔穆特·库奇奥著，朱岩、张玉东译：《欧盟纯粹经济损失赔偿研究》，载《北大法律评论》第 10 卷第 1 辑（2009），北京大学出版社 2009 年版，第 248 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

但是虽然保险可以在许多情况下合理地分散风险，分配损失，然而仅以受害人投保更容易，因而更容易承担风险为由，就拒绝对其遭受的纯粹经济损失进行赔偿，应当讲这种理由是极其功利的，且不符合法律的公平正义观。事实上，我们不应当只考虑谁更容易承担风险，而是应当考虑谁更应当承担风险。[①]

五、经济分析的视角[②]

经济学视角下，由于侵犯所有权而造成某种资源毁坏或不能使用所形成的损失，与纯粹经济损失有本质的区别。例如一座房子被烧毁，那么整个社会资产就减少了被烧毁的房子的价值。此例中，社会损失等值于受害者的损失，而且损害赔偿相当于社会损失。无论是在无过错责任还是过错责任的情况下都应对受害都予以赔偿，这样才能让整个社会形成预防损害的最优激励机制。

但是在纯粹经济损失的情况下，受害者损失与社会损失就可能不一致。例如，整个社会的损失可能小于各个受害者所遭受损失之和。在这种情况下，完全的损害赔偿会使社会形成一种过度的预防机制。按照有关责任规则，如果损害赔偿高于侵权人造成的社会损失，这将形成过度震慑作用。那么，潜在的侵权人就会采用一种经济学角度来看过高的损害规避成本。在分清可能的过度震慑之时必须清楚，法律体系是否对注意义务已经作了确切的定义，侵权人是否事前知悉这种注意义务；或者，侵权人是否事先获得了法庭最后会采纳何种注意标准的可靠信息。

如果一种必要的注意标准事先为侵权人所熟知，那么从效率的角度看，由此引起的责任形式就不成问题，也会造成过度震慑。因为过度赔偿会激励潜在侵权人十分谨慎地遵守注意标准。因此，在明确界定注意标准的情况下不会出现过度震慑的情况。

但是在现实生活中，潜在的侵权人常常很难准确预测到，法庭最终会采用何种注意标准。在事先没有明确注意义务时，纯粹经济损失的过度赔偿会导致过度的损害预防成本（过度震慑）。因为侵权人在遵守自己所选定的注意标准的情况下，仍担心有可能会承担的责任，以及需要数倍地赔偿自己可能造成的社会损失。由于不

---

① 余艺：《过失致人纯粹经济损失不予赔付规则及其突破》，载《政治与法律》2007年第1期。

② 这一部分主要参考了[德]汉斯-贝恩德·舍费尔、克劳斯·奥特著，江清云、杜涛译：《民法的经济分析》（第四版），法律出版社2009年版，第285-293页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

安，潜在的侵权人有足够的动力将损害预防成本一直提高到非理性的程度，从而在一定程度上保证其行为无过失，以规避过度责任的风险。从经济学角度看，这是一种没有效率的结果。

法律制度可能采取不同的方法来防止这种不良状况。在德国法中，原则上损害赔偿被限定在违反善良风俗的故意侵害（例如《德国民法典》第 826 条），抑或触犯某个保护法如刑法（例如欺诈）的情况下。因为此时侵权人事前非常清楚其行为是有过错的。因而，原则上也就不存在由于过度赔偿引起过度震慑的问题。

另外一个可能的方法为显著责任，即只有在侵权人有明显过错时才须承担责任。在个体受害者损失巨大而整个社会损失轻微的情况下，这样的显著责任规则比一般的过失责任更富效率。鉴于法律安全度更高，显著责任也避免了过度赔偿所导致的过度震慑这种情况。另外，即使加害人看来这种注意尺度并不显著，通过对注意进行一些必要的明确界定也可以避免过度震慑。

有些学术著作建议，计算出社会损失的大小，受害者只能在此额度内受偿。这虽然前后一致了，但是问题也随之而来，即究竟是否能在一定程度上对市场损失进行非任意的计算，如果答案是肯定的，那么法院是否能够在处理相关信息能力有限的情况下完成这项任务呢？

如同许多国家的法律制度包括德国在内，纯粹经济损失虽然在合同法中得到保护，却不在侵权法的保护范围之内。维克托·戈德堡（Victor Goldberg）提出的理论在一定程度上解释了这种模式什么时候有效、为什么有效的问题。让我们以罗宾干船坞诉燧石公司一案对此予以分析，此案案情作了少许改动。

某船东以每月 100 的市场价格将轮船租赁给某经纪人。由于市场上突然出现吨位短缺，此经纪人可以将此船以每月 300 的价格转租给下家。在租赁合同期间船东与某船坞签订轮船维修合同，让船坞对轮船进行常规检修。在检修过程中船坞由于过错将船损坏，导致该船一个月内不能使用。船东丧失了向承租方收取 100 租金的请求权。但是船东可以要求与之有维修合同关系的船坞支付这笔损失作为损害赔偿。虽然经纪人不用支付这笔 100 的租金，但是由于轮船不能使用，他损失了其下家 300 的租金。经纪人不能从船坞处获得纯粹经济损失总计为 200 的损害赔偿，因为经纪人与船坞并无合同关系。他只能转而求助于侵权法上的请求权，但侵权法却并不涵盖纯经济损失。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

让我们将此案例稍做改动，假定船东直接将船出借给最终用户，取得租赁收益300。此时船东可以从船坞得到 300 的损害赔偿，因为船东在这里可以合同相对方的名义要求对这种损失进行赔偿。这两个案例仅仅在法律结构上有所不同，其经济特征完全一样，但是处理的方式却大相径庭：其中一个案例只有部分损失得到赔偿，另外一个案例却得到全部损失的赔偿。原因何在？

戈德堡认为，原因在于合同关系的阻碍对于第三人的影响无法确定。我们假定，市场走势不是向上，而是向下发展（事前就已经显示出这样的可能性），此时租船仍须支付租金100，而随后的市场租赁价格却降到月租30。因此，无论是转租给下家或自用，经纪人在船租价格下滑时遭受的损失为 70。此时的责任情况又该如何呢？在第二个案例中的损害赔偿额为30，这与实际损失相当。相反，在第一个案例中船坞须赔付的损失为船东所失的租金 100，而经纪人所损失的租金仅为转租给下家的租金30。由于经纪人在船舶维修时不必支付租金，经过这样一个不利事件他反而获取了 70 的利益。为达到法律执行的效率，损害赔偿额度应等同于实际损失，那么本案所导致的额外利益应返还给侵权人。但是实践中这根本不可能。承租方大多会保持缄默，不让任何人知道他通过船坞的侵权行为而意外获利。如果第一个案例中的损失获得赔偿，就此类损害案例的总体情况而言，其赔偿总体上接近实际损失，因为只有实际受害者可以向法院申报损失，而那些通过他人损害行为获取利益的人则无此可能。如果要根据侵权法对此类纯粹经济损失予以赔偿，这条规则就相当于筛子，它会仔细地筛选留下所有由损害行为所造成的纯粹经济损失，而将由此获得的纯粹经济利益筛选掉。这常常会形成这样一个局面，侵权人所须赔付的总数往往超过所有预期损失之和。这样就产生了损害预防成本最优激励机制。不同于侵权法，合同法中不会出现这种效应。就具体案例来讲，如果船东直接将船出借给最终用户，船东得到的损害赔偿就不是100，而只是30。

侵权法规定纯粹经济损失的不可赔偿性，是因为它考虑到对于第三人的损害既可能造成纯粹经济收益，也可能造成纯粹经济损失。虽然侵权法可以对损失进行补偿，但是另外一点也同样重要，即侵权法不能剔除这种纯粹经济利益，并将此利益补偿给加害人。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二节　公认的受保护的经济利益范围

虽然有很多理由反对对纯粹经济损失进行救济，但是我们仍然可以看到，在一些领域里，各国都对一些经济利益提供保护，因此存在着一些公认的受保护的经济利益范围，如各国民法在合同法、故意侵权行为法、和一些保护性的制定法领域内，都对纯粹经济损失提供有效的法律救济。下面我们将对这些领域进行详细地分析，希望能从中找出为什么这些经济利益会受到民法的保护？

一、合同责任

在市场经济体制中，人们通过自由自愿的交换来满足各自的需求，并增加社会财富，因此通过经济利益的交换来促进社会资源的最大程度的有效分配。合同法就是规范交换的法律。合同一方当事人违约，将会侵犯另一方当事人的合同债权，除责任竞合的情形外，另一方当事人遭受的通常是纯粹经济损失。对于在交换和交易过程中发生的纯粹经济损失，如何进行分担或赔偿，如何进行救济和处理，也正是合同法中违约责任的主要任务和内容。

人们宁愿以契约的方法而不愿以侵权的方法对其经济利益提供保护，因为人们认为，原告应当通过与潜在的侵权人直接订立合同的方式来寻求对其经济损失的赔偿，通过与他人订立合同的方式来分配可能存在的经济利益遭受损害的风险，他们可以规定义务人履行合同时的特定标准，可以排除或限制义务人承担的损害赔偿责任的范围。如果原告不能通过合同的方式对自己可能要遭受的经济损失加以保护，则他应当对其风险予以保险，通过责任保险方式使自己的经济损失得到保护。如果当事人之间已经订立了合同，确定了义务履行条款和损害赔偿的排除或限制条款，那么，法律再规定不同的义务履行标准和通过一般性的注意义务而实行不同的法律责任规则，是没有理由的。如果当事人没有订立此种合同，则人们认为受害人应当自己承担其所遭受的经济损失。[①]

现代法律之所以要求原告以合同性分析方法对其经济利益加以保护，主要是基于最基本的社会权利的考虑：任何人均不享有要求免受他人过失干预的道德性权利，相反，他们负有通过合同的方式购买此种保护，通过合同方式对其经济损失予

[①] 张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 613 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

以保险或自己承担他人过失侵权所导致的后果的道德义务，因此，合同法是保护原告免受他人过失干预行为影响的适当法律机制，因为合同法倡导经济利益和经济活动的自我决定和自我控制，反对经济利益和经济活动的国家干预和公共控制。[①]

因此在合同法上，所有法律制度都规定，合同一方当事人应就其给对方当事人造成的纯粹经济损失承担责任。合同法与侵权法对待纯粹经济损失的明显不同态度，能够为我们在侵权法上合理确定纯粹经济损失的赔偿条件提供一些启示。我们首先需要明确的是为何在合同法上对纯粹经济损失进行全面的保护。

合同是是当事人意思自由的产物，是否缔结合同，同谁缔结合同，合同的内容具体是什么，都由当事人自主自愿地选择。在合同缔约的过程中，通过磋商价格和控制交易成本，以及选择担保等工具，当事人可以有效的计算和防范纯粹经济损失发生的风险、程度及范围，也可以预先合理的约定所发生损失的分担和处理。因此，合同当事人可以预见并防范纯粹经济损失的发生，而且发生后的承担，一般也是当事人可以接受的。而且在合同交易中，增加财富的前提和保证，就是对方的违约或者违法行为给己方造成经济损失时，自己可以依照合同法得到救济，而这里的经济损失，主要是纯粹经济损失，合同法主要的保护对象就是纯粹经济损失，而不是人身伤害或物的有形损害。

综上可以认为以下理由可能是重要的：

首先，诉讼闸门理由在合同法中是不适宜的：在违约的情况下，只有合同当事人的纯粹经济损失有可能被损害，因此，没有任何可能产生大量原告的危险。

其次，合同只包含一方当事人对另一方当事人的义务。因此，仅涉及对合同当事人双方行为自由的限制，而不会出现对他人的行为自由进行限制的情形。

此外，因违反合同而消极影响对方当事人的纯粹经济利益时，对另一方当事人来说是可以预见的，并且内容也是确定的。

另一方面，合同当事人似乎对于他们利益的被侵犯有广泛保护的需求，包括他们的纯粹经济利益，因为他们使自己在经济上易受另一方当事人的影响。因此，如此亲密接触的后果是，每一方当事人有大量的机会影响另一方当事人的纯粹经济利益。因此，合同当事人的利益依赖于另一方当事人的谨慎行事，尤其是他们的纯粹经济利益。如果没有纯粹经济利益的广泛保护，则合同当事人的风险太大。

[①] 张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 613 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

最后，值得注意的是，通常合同当事人双方都追求商业利益。如果某人追求自己的商业利益，并因此严重损害其他人时，则承担较高程度的注意义务似乎是合理的。

二、近似于合同关系

缔约过失责任，是指缔约人或其缔约磋商辅助人故意或过失违反先合同义务而给对方造成信赖利益或固有利益的损失时应依法承担的民事责任。而先合同义务是指缔约人双方为签订合同而互相磋商时依诚实信用原则逐渐产生的注意义务，它包括互相协助、互相照顾、互相保护、互相通知、互相忠诚等义务。[①]

缔约过失责任的范围在德国民法上的应用逐渐扩大，在债权人方面，它扩展至了与其有着密切关系的第三人，即将附保护第三人作用的契约延伸至了合同谈判阶段；在债务人方面，它也扩展至了第三人，即创设了所谓的“事务管理人责任”；另外还扩展至对合同订立具有个人的经济利益的第三人。因此，缔约过失所保护的范围主要是纯粹经济损失，特别是在违反通知义务的情形下。[②]

人们普遍认为，当事人双方互负的特殊的注意义务，在签订合同之前就已经存在。因此，如果当事人一方没有尽到必要的注意而使对方遭受纯粹经济损失时，则要承担缔约过失责任，这种责任是介于合同责任和侵权责任之间的责任方式。[③]法院和学者支持赔偿纯粹经济损失的意愿，在缔约过失责任领域是不受限制的，并且扩展至邻近的其他领域或特殊关系领域，这些能被描述为近似于契约关系。[④]

在英国 Hedley Byrne 一案中也认为，只有在当事人之间的关系近似于契约关系时，一方才对另一方承担注意义务，如果没有尽到此种注意义务，而给他人造成损害，则行为人应当对他人承担侵权责任。因此一方当事人在作出陈述时对与自己有特殊关系的另一方总是要承担注意义务，[⑤]而不论双方之间是否存在合同关系。

这种“等同于契约关系”，也即当事人之间的近因性，是指一种法律上的关系或法律所认可的关系。因此如果双方当事人之间存在某种近因关系，被告即被要求

---

① 马俊驹、余延满：《民法原论》（第三版），法律出版社 2007 年版，第 539 页。

② 李昊：《交易安全义务论——德国侵权行为法结构变迁的一种解读》，北京大学出版社 2008 年版，第 207-212 页。

③ 海尔穆特·库奇奥著，朱岩、张玉东译：《欧盟纯粹经济损失赔偿研究》，载《北大法律评论》第 10 卷第 1 辑（2009），北京大学出版社 2009 年版，第 250 页。

④ B. Feldthusen, Economic Negligence, The Recovery of Pure Economic Loss (4th edn. 2000),18.

⑤ 参见张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 645-646 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对原告承担注意义务，而如果违反此注意义务给原告造成纯粹经济损失时，被告应当承担损害赔偿责任。

三、故意侵权造成的纯粹经济损失

与责任排除规则联系在一起的是由过失行为引起的经济损失，而不是故意不当行为。所有的法律制度都同意：如果相关行为是可归责、不道德且违反公共政策的，那么其故意所致的纯粹经济损失应是可获赔的。在所有的法律制度中，随着归责程度的提高，似乎也存在获赔范围随之扩大的趋势。为了裁度合理的限制范围，法官和立法者都应该考虑其他诸如行为人意识状态这样的重要因素。[①]因此，行为人的主观意识状态也成为纯粹经济损失是否可以得到赔偿的决定性因素之一。

这一类型的侵权行为主要包括：第三人故意侵害债权、故意不实陈述（欺诈）、通谋损害第三人利益、假冒、引诱违反合同、恶意诽谤、滥用垄断优势和非法干涉交易等。

四、间接损失

我们前面已经指出，经济损失哪怕是与原告最为轻微的人身伤害或财产损害存在联系，只要它符合胜诉的其他所有要件，则所有损失无疑均可获得赔偿。因此普遍承认，即使在侵权行为法中，当经济损失是因法律所保护的权利被侵犯而随之产生的，则必须赔偿经济损失。即使被告不能预见损失的总额，也要承担赔偿责任。[②]这种“寄生性损失”之所以能够获得赔偿，是因为它以受害人存在实际损害为前提，这种间接损失在任何国家均受保护。

五、关联损失中的例外

如前面所分析的，拒绝纯粹经济损失请求的大多数司法管辖区仍然承认这个规则的某些例外。在关联损失案件中，特别是在人身伤害和死亡的案件中，配偶和孩子，因为失去经济支持，并且有时候因为非金钱损失，而会特别给予一定形式的赔偿。这里，排除规则及不打开诉讼闸门的明确政策似乎不适用于人身伤害的受害人

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 8 页。

② [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔著，焦美华译：《欧洲比较侵权行为法》（下卷），法律出版社 2001 年版，第 189 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的亲属所遭受的纯粹经济损失。

六、转移损失

另外一个例外是在转移损失的案件中，即这个损害正常情况下应由受害人一方承受，但由于受害方和第三方之间的特殊关系而事实上由第三方承受。这是大多数国家所承认的一个例外。对于转移性损失能够达成共识，无疑是因为自由主义国家和保守主义国家的法官皆承认，从侵权人的角度来看，转移性损失是一种中性责任，其所带来的困难更多是技术性的而不是政策性的或衡平性的。[①]

第三节　纯粹经济损失赔偿责任的限制

一、成立纯粹经济损失赔偿责任时应考虑的因素

根据前述的对两类损失的不同保护原因及已经确认的经济损失的赔偿责任，可以总结一下成立纯粹经济损失赔偿责任时，应该予以考虑的一些因素。

（一）当事人的主观心理状态

正如前文所述，与责任排除规则联系在一起的是由过失行为引起的经济损失，而不是故意不当行为。所有的法律制度都同意：如果相关行为是可归责、不道德且违反公共政策的，那么其故意所致的纯粹经济损失应是可获赔的。[②]

根据核心侵权行为法，故意导致损害是成立纯粹经济损失赔偿责任的决定性因素。如果侵权行为人故意，则纯粹经济损失的责任一般可以成立。

（二）潜在原告数量无限制的可能性

排除规则的首要赞成理由就是诉讼闸门理由，担心原告的数量会无限多。而已确认的受保护的经济利益的范围中，合同责任对纯粹经济损失的无限制赔偿也是因为没有无限多原告的危险，并且在类合同关系以及扶养费案件中也是因为潜在原告的数量是有限的。

因此潜在原告的数量的有限性是纯粹经济损失赔偿责任成立的重要因素之一。

[①] [德]克里斯蒂安·冯·巴尔、乌里希·德罗布尼希主编，吴越等译：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，法律出版社 2007 年版，第 123 页。

[②] [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 8 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

如果没有潜在原告数量无限制的风险，则有可能会成立纯粹经济损失赔偿责任。

（三）损失的可预见性

可预见性是邻居原则的基础，如果被告能“合理预见”到他的行为（作为或不作为）会对原告造成损失或损害，那么被告就被认为存在注意义务。这种可预见的损害是指“行为人如果尽到必要的注意，则可能避免或可能将损失降至最低的损害”，只要求行为人依据行为前所获得的有效信息作出判断。[①]

在契约责任中，一方当事人因违约而对另一方当事人的纯粹经济损失承担责任的原因之一，就是他明显地知道其违约将给对方带来什么样的损害，而如果损失是不可预见的，则不用承担责任。而在第三人侵害债权的案件中，被告对原告所遭受的纯粹经济损失承担责任的原因之一就是被告对原合同的认知，也即对其行为将给原告造成的损害是可以预见的，如果被告对原合同不知情，则其不能预见到侵害债权的行为会造成原告的损失，这样的情况通常是不成立责任的。

对人身伤害和财产的有形损害承担赔偿责任的一个原因也是，这些利益是法律所明文保护的利益，是易于察知的，且有明确的内容，对其的损害也是被告可以预见的。

纯粹经济利益通常是不易察知的，且没有明确的内容，因此对其提供广泛的保护，将会严重限制人们的行为自由。然而如果在具体的个案中，对原告所遭受的纯粹经济损失是被告所能够察知且可预见的，则被告应当承担赔偿责任。

综上，纯粹经济损失的可预见性也是成立纯粹经济损失责任时就予以考虑的一个重要因素。

（四）近因性

正如合同法中的责任及缔约过失责任所证实的，邻近因素或特殊关系在成立纯粹经济损失责任时是非常重要的。原因在于如果当事方之间有密切接触，则导致损害的机会大得多，因此他们每一方都不得不依赖于另一方对其利益行使适当的注意。而且，如果存在近因性，则照顾另一方的利益也容易得多且更恰当。[②]

在不实陈述类型的案件中，专家过失陈述对第三人所造成的纯粹经济损失的赔

---

① 参见毛大春、王枫：《英国侵权法的注意义务述评》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第21卷），金桥文化出版（香港）有限公司2001年版，第453-454页。

② Helmut Koziol, Compensation for Pure Economic Loss from a Continental Lawyer's Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.147.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

偿责任，能够成立的其中一个原因也是因为专家与第三人之间有类似于合同的关系，而德国则直接以“附保护第三人作用之合同”理论将此等同于合同责任来处理。

所以，当事人双方之间如果具有近因性和特殊关系，也说明当事人之间接触的密切性，责任的成立上更接近于合同责任，则成立纯粹经济损失责任的可能性会加大。当事人关系的近因性也是成立纯粹经济损失责任时应予考虑的重要因素。

（五）额外的注意义务

排除规则的一个重要理由，就是认为广泛保护纯粹经济损失，会对人们的行为自由施加严重的限制，导致人们承担额外的注意义务。

我们前面已经指出，经济损失哪怕是与原告最为轻微的人身伤害或财产损害存在联系，只要它符合胜诉的其他所有要件，则所有损失无疑均可获得赔偿。因此普遍承认，即使在侵权行为法中，当经济损失是因法律所保护的权利被侵犯而随之产生的，则必须赔偿经济损失。即使被告不能预见损失的总额，也要承担赔偿责任。[①]这种“寄生性损失”之所以能够获得赔偿，是因为它以受害人存在实际损害为前提，是由于侵犯了法律所保护的权利而导致的，因此对被害人这样的纯粹经济利益进行保护，并没有使行为人负担额外的注意义务，因为行为人本来就负有不得侵犯法律所保护的权利的义务，因此行为自由也没有被进一步限制。

此外，在关联损失案件中（特别是在人身伤害和死亡的案件中），配偶和孩子，因为失去经济支持，并且有时候因为非金钱损失，而会特别给予一定形式的赔偿。这里的重要因素之一也是没有给被告施加额外的注意义务，因为被告本来就负有尊重他人生命和身体的义务。

最后，转移损失案件，即这个损害正常情况下应由受害人一方承受，但由于受害方和第三方之间的特殊关系而事实上由第三方承受，也是大多数国家所承认的予以赔偿的一个例外。存在例外的原因之一，也是没有对被告施加额外的注意义务，因为第三方的纯粹经济损失是从被法律所保护的权利被侵犯的受害人那里所转移的损失，被告原本就负有不得侵害受害人权利的义务，因此对第三人的纯粹经济损失承担责任没有进一步限制其自由。

综上，我们可以看出，被告有没有被施加额外的注意义务，也是成立纯粹经济

[①] [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔著，焦美华译：《欧洲比较侵权行为法》（下卷），法律出版社 2001 年版，第 189 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

损失责任时应考虑的一个重要因素。如果要求被告对原告的纯粹经济损失承担责任，则必须没有使被告承担额外的注意义务，也即对其行为自由没有进一步的限制，则这样的责任成立是合理的。

（六）合理的信赖

在Hedley Byrne一案中，Lord Moris和Lord Reid均将原告对被告陈述的信赖作为原告请求被告承担侵权责任的检验标准。“显然很重要的一点是原告对另一方建议存在‘合理信赖’。”[①]此种理论认为，如果第三人对专业人士的陈述存在合理的信赖，则专业人士就应当对该第三人承担注意义务，如果未尽到此种注意义务而给第三人造成经济损失的话，则专业人士当承担过错侵权责任。在Hedley Byrne一案以后，英美法存在大量判决，均以此标准进行判决，并且学者也赞同被告是否因为过失虚假陈述对第三人承担义务的判断标准之一，就是原告对被告的合理信赖。[②]

在合同责任中，要求违约一方对非违约方遭受的纯粹经济损失承担赔偿责任的原因之一，也是因为合同双方当事人之间具有信赖关系，一方信赖对方会遵守合同，会对已方的经济利益给予必要的注意。缔约过失责任的一种类型就是一方违反了对方的信赖，因此给对方造成信赖利益的损失，所以要对对方的纯粹经济损失承担赔偿责任。

因此双方之间是否存在合理的信赖，是成立纯粹经济损失赔偿责任的一个重要因素，特别是不实陈述类型中。

（七）潜在原告的保护手段

排除责任的一个理由就是保险因素。很多人认为纯粹经济损失可由加害人投保第三者责任险或者由被害人投保意外事故险而获得补偿。也就是说如果原告有其他获得保护的途径，即有其他保护手段的话，则不成立侵权责任。或者至少认为原告自己也具有一定的过错，可以适用与有过失理论来减轻或限制被告的赔偿责任。

在专家责任中，很多国家都承认专家对第三人的民事责任，特别是在招股说明书责任中特别承认专家对中小投资者的责任，其中很重要的一点就是中小股东缺乏获得信息的其他途径，也就是除了信赖招股说明书中的陈述外，没有获得真实信息的有效途径，因此认为应对中小股东的利益负责。但是对于银行的责任则不同，一

① B. S. Markesinis ans S. F. Deakin, ibid, p87.
② Bruce Feldthusen, Issues in Tort Law, ibid , p190.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

般认为不成立，因为银行有获得信息的其他途径，也就是有保护自己的手段。

所以，如果潜在原告没有通过其他方式保护自己利益的能力，则可能成立由此产生的纯粹经济损失的责任。潜在原告的保护手段也是成立纯粹经济损失责任时应予以考虑的重要因素。

（八）原告经济损失的重要性

如上面所指出的，在人身伤害和死亡的案件中，配偶和孩子对于其失去经济支柱的相关损失，尤其会被给予某种形式的赔偿。赞成这样例外的原因除了我们之前提到的，还有一点比较重要的就是，这种损失对原告来说是非常重要的，他们的生计受到了威胁，因为他们的生计是以第一受害人的经济支柱为基础。对其进行保护也反映了法律的人文关怀，大多数人认为对其进行赔偿是正当合理的。

在电缆案件中，不赞成成立责任的一个原因之一，就是这些损失对原告来说大多是微不足道的，没有足够的重要性。对其不予赔偿也是大多人认为是正当合理的。

因此，原告所遭受的纯粹经济损失对其的重要性，也是成立责任时应考虑的一个重要因素。

（九）金钱上的利害关系

金钱上的利害关系作为被告就其过失陈述对第三人承担注意义务和侵权责任的一种检验标准也是由 Hedley Byrne 一案确立的，因为 Lord Devlin 在该案中认为，因为过失不实陈述诉讼是建立在“等同于契约关系”的基础上的，因此，如果被告对相关的交易享有金钱上的利害关系时，则他对第三人作出陈述时，就必须承担注意义务，这就相当于合同的相对性规则和对价性规则一样，要求当事人之间互相承担注意义务，如果未尽到注意义务，则要承担相应的侵权责任。此案后，英联邦均承认，被告享有金钱上的利害关系是产生注意义务的一种根据。[①]

在合同责任中，一方因自己的违约而对另一方的纯粹经济损失承担责任的原因之一，也是因为合同当事人双方都是为了自己的经济利益而行事，并且希望通过合同的履行获得收益，因此彼此之间承担较高水平的注意义务。

在专家责任中，专家有没有获得报酬，也成为一个重要因素。在承认专家的不实陈述所导致损害的赔偿责任时，决定性的也是专家做出陈述是为了自己的经济利益，即收取费用。如果专家做出陈述没有任何经济利益，则责任能够减轻，甚至可

[①] 张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 649 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能不成立责任，但当专家知道他的陈述是不真实的，则除外。

综上，有没有金钱上的利害关系，也即被告是否追求自己的商业利益，也是成立纯粹经济损失责任时应予以考虑的一个重要因素。

二、以既有的侵权责任构成要件合理限制纯粹经济损失的赔偿责任

侵权责任法以合理分配社会生活风险为任务，政策上有必要针对各种千变万化、复杂多样的社会生活利益，根据其价值位阶，作一定程度的筛选控制，以合理限制侵害利益时的损害赔偿责任。因此侵权责任法应当分别权利侵害与利益侵害，而给予不同程度的保护。但是怎么用技术手段来区别保护权利与纯粹经济利益？结合我们上面所分析的成立纯粹经济损失赔偿责任时应考虑的因素，是否可以以既有的侵权责任构成要件——损害、过错、因果关系，根据其概念本身所负载的规范功能，使其成为筛选控制的工具，在责任的成立上作出适当的判断，以达到适度合理限制加害人责任的目的？

（一）损害

损害是一种“不利益”，是指因一定的行为或事件使某人受法律保护的权利和利益遭受不利益的影响。[①]并非一切民事权益遭受侵害，都会得到法律的保护，民事责任法所保护的民事权益，应当符合质和量两方面的要求。

1. 损害的正当性——质的要求

损害的正当性，是指损害是具有“赔偿适格”、“能够请求赔偿”性质的损害，只有侵犯了法律政策上认为正当的、值得保护的利益时，才发生损害赔偿责任。被害人请求赔偿的损害是否具有正当性，是一个具有浓厚价值判断与政策选择的问题，并且会随着时代社会变迁情形或风俗道德观念演化趋势，而发生变化。权利为现有的法律体系所承认，不会发生不法、不当或不道德问题，当然具有正当性。但利益，如纯粹经济利益，因其范围广泛，种类繁多，内容也复杂多样，有些可能发生不法、不当或不道德问题，因此侵害纯粹经济利益，只有当该利益是正当的、值得保护的利益时，被害人受到的纯粹经济损失才能够请求赔偿。

2. 损害的严重性——量的要求

损害的严重性，是指民事责任法所保护的权益，必须具有一定程度的重要性，

[①] 王利明：《侵权行为法研究》（上卷），中国人民大学出版社 2004 年版，第 350 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能够请求赔偿的损害，必须具有一定程度的严重性。因此，极度轻微的不利益，或不具有重要意义的损失，只能认为是一种群体社会生活中所应容忍的不便或不适，而不能认为是一种真正的损害。因此在电缆案件和交通堵塞案件中，大多数人遭受的纯粹经济损失只是一种生活上的不便，不具有严重性，因此不能够得到赔偿。而在导致他人人身伤害的案件中，多数国家认为配偶和孩子失去扶养费的损失可以给予特别的赔偿，就是因为他们的损害比起雇主或债权人的损害，更具有严重性。因此损害的严重性这个条件，可以发挥一定的筛选过滤功能，在众多可能被侵害的纯粹经济利益中，排除一些对被害人影响非常轻微的不便或不适，达到合理限制加害人责任的目的。

在成立纯粹经济损失赔偿责任时应考虑的因素中，经济损失的重要性也即损害的严重性的体现。

（二）过错

过错是指行为人从事了在法律上和道德上应受非难的行为，包括故意和过失，通常认为对故意的判断采取主观标准，而对过失的判断采取客观标准。[①]在纯粹经济损失的案件中，如果是故意导致的，所有国家都承认赔偿责任，问题是对于过失导致的纯粹经济损失，如何进行控制和筛选？

如前所述，由于纯粹经济利益具有难以具体特定的特性，使得在侵害纯粹经济利益的情形下，可能会发生加害人完全无法预见其行为是否可能造成损害、被害人为谁、损害规模或范围有多大，却只因一时之疏忽，就必须负担被害人人数众多，损害规模巨大，超出一般可以合理估计范围的赔偿责任。因此，为了兼顾行为自由这一价值，保障个人的行为自由或经济活动的自由，避免侵权责任发生失控泛滥的现象，制度上确实有必要适度限制纯粹经济损失的赔偿责任，以行为人对于纯粹经济损失的发生具有一定程度的可预见性为必要。我们可以通过过失这一要件，使其承担筛选和控制的机能，以合理考量纯粹经济利益的不确定性与不可预见性、范围广泛、难以精确估计等特点，而将纯粹经济损失的赔偿责任限制在行为人对于其损害结果具有“预见可能性”的情形。因此对于纯粹经济损失而言，如果纯粹经济利益的存在、主体、内容或范围具有预见可能性，则应该成立赔偿责任。在纯粹经济损失的案件中，在具体在认定加害人是否存在过失时，即在考量加害人对于损害能

[①] 王利明：《侵权行为法研究》（上卷），中国人民大学出版社 2004 年版，第 472 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

否预见时，应当考虑以下因素：

1. 双方当事人间的特殊关系或近因性：如果双方当事人之间具有近因性，则说明对于对方的利益损害具有预见的可能性，相比一般人而言，可能轻过失就能够成立纯粹经济损失的赔偿责任。

2. 额外的注意义务：如果要求当事人承担纯粹经济损失的赔偿责任，会使对方负担额外的注意义务，则说明当事人对对方的纯粹经济损失缺乏预见的可能性，很可能会不成立相关责任。

3. 合理的信赖：如果双方当事人之间存在合理的信赖，则纯粹经济利益更容易受到侵害，要求对方具有较高程度的注意义务，如果没有尽到较高程度的注意义务，则说明具有过失，很可能会成立纯粹经济损失的赔偿责任。

4. 潜在原告的保护手段：如果原告仍有保护自己经济利益的其他手段，说明原告自己对于纯粹经济损失的发生也具有过错，可以运用与有过失的理论，合理减轻加害人的过错。

5. 金钱上的利害关系：如果当事人双方之间存在着金钱上的利害关系，如收取了一定的费用，则加害人应比没有金钱上的利害关系时承担更高程度的注意义务，因此所需的过失程度会小于通常情形下所应具有的过错程度。

过失的认定是一个有待具体化的标准，应当由法官在具体的个案中，根据案件的具体情况，综合考虑各相关因素来做客观的判断。

（三）因果关系

侵权责任中的因果关系，是指行为或物件与损害事实之间的前因后果的联系，是确定责任的归属与控制责任范围的重要要件。[①]在纯粹经济损失的赔偿中，因果关系具有重要的意义：一方面，因果关系可以决定损害赔偿责任的有无，如果有介入外来原因而使因果关系中断，则有可能使加害人不承担责任；另一方面，因果关系也可以起到限制纯粹经济损失赔偿范围的作用。因为对纯粹经济利益的侵害，有可能会导致漫无边际、无休无止的赔偿责任，因此有必要通过因果关系的判断来截断因果关系的链条，限制其赔偿责任。“对于纯粹经济损失是否应当补偿，很大程度上要界定因果关系的问题。纯粹经济损失所提出的问题仅仅是‘遥远性’，即原告的哪些附随经济损失可以归结为被告的行为，只有在纯粹经济损失案件中法院才

[①] 王利明：《侵权行为法研究》（上卷），中国人民大学出版社 2004 年版，第 386 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

会面对复杂的局面。”[①]

在西方有些国家，也采用“可预见性理论”来确定因果关系。该理论认为，如果损害结果的发生，属于行为人在实施行为时能够预见的范围内，则该行为就可以构成原因。此理论的根据在于，任何人都应当和能够预见估计其可能承担的责任范围，行为人只能对其结果具有预见可能性时，才具有选择行为的自由，如果对其结果不具有预见可能性，则没有选择行为的自由，因此不应当承担责任。因此运用因果关系这一要件，可以排除一些因果联系上过于薄弱、牵强、偶然或不确定的损害项目，达到适度合理控制责任的目的。如前所述，法国就是运用因果关系这一具体的构成要件来控制对纯粹经济损失的赔偿责任，并且在实务中，法国也经常从因果关系的证明活动此一问题着手，要求被害人负举证责任及证据证明力的评价，以此达到合理限制责任的目的，这种做法也是值得我们借鉴的。

因此，对于纯粹经济损失的救济，我们可以适用更严格的侵权责任构成要件，同样可以达到合理限制责任的目的。

[①] B.S.Markesinis, A Comparative Introduction to the German Law of Torts, 3th. ed., Oxford: Clarendon Press, 1994, p.43.转引自王利明：《侵权行为法研究》（上卷），中国人民大学出版社 2004 年版，第 383 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章　纯粹经济损失的类型

第一节　纯粹经济损失的分类

纯粹经济损失发展的过程中，也有学者试图为赔偿确定一个统一的标准，但纯粹经济损失诉讼案件种类繁多复杂，很难确定一个赔或不赔的简单标准。当抽象——一般概念及其逻辑体系不足以掌握某生活现象或意义脉络的多样表现形态时，大家首先会想到的补助思考形式是“类型”。[①]两大法系中的纯粹经济损失理论的发展都是通过判例而形成的，经过司法实践的积累，各国都发展了一些相对固定的案件类型，纯粹经济损失朝着类型化发展。

一、学理上的分类

由于纯粹经济损失的形态复杂多样，对其赔偿问题背后总有一些法律政策的考量，因此不同的学者从不同的角度对纯粹经济损失进行了分类。

王利明教授认为纯粹经济损失的主要形态包括四种：间接致损、失去使用价值的损失、不实表示和专家责任。[②]张新宝教授将纯粹经济损失分为：意外致损的直接经济损失、间接性经济损失、相关经济损失、缺陷产品或缺陷建筑物的价值减损、未履行的失职责任、误导和服务过失。[③]张民安教授则认为可由过失侵权法加以保护的纯粹经济损失类型包括：因过失误述而导致的纯经济损失、因职业服务过失而产生的纯经济损失、产品责任中的纯经济损失、因对相关财产的侵害而产生的纯经济损失。[④]李昊博士将纯粹经济损失分为：直接引起的纯经济上损失、并存性的纯经济上损失、关联经济损失、瑕疵（缺陷）产品或建筑的减损价值、第三方引起的经济损失。[⑤]葛云松教授认为纯粹经济损失的主要类型为：债务人不履行债务，使债权人发生的损害、第三人侵害债权、第三人因填补他人侵权行为所致损害而发生

---

① [德]卡尔·拉伦茨著，陈爱娥译：《法学方法论》，商务印书馆 2003 年版，第 337 页。
② 王利明：《侵权行为法研究》（上卷），中国人民大学出版社 2004 年版，第 372-374 页。
③ 张新宝：《侵权责任法原理》，中国人民大学出版社 2005 年版，第 210-211 页。
④ 张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 628 页。
⑤ 李昊：《纯经济上损失赔偿制度研究》，北京大学出版社 2004 年版，第 8-10 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的损失及其他纯粹经济损失。[①]

台湾学者王泽鉴教授则将纯粹经济损失分为两类：直接侵害和间接侵害。而直接侵害包括：营业竞争、引诱违约、阻塞道路交通、制造销售有缺陷商品、专门职业者提供不实资讯或不良服务等。间接侵害包括：侵害某人人身，致第三人受有经济损失及侵害某人之物，致第三人受有经济损失。[②]

对纯粹经济损失的分类影响最大的，也是欧洲通行的分类，是毛罗•布萨尼（Mauro Bussani）及弗农•瓦伦丁•帕尔默（Vernon Valentine Palmer）在《欧洲法中的纯粹经济损失》一书中的分类，其将纯粹经济损失分为反射损失，转移损失，公共市场、运输通道和公用设施的关闭、对错误信息、建议和专业服务的信赖四类。[③]

台湾学者邱琦在其博士论文《纯粹经济上损失之研究》中，提出了一个比较特别的分类方式。她认为，欧美学者的分类方式，虽然有助于将法律事实的内涵认识清楚，但不能清楚地认识到法律效果，特别是在非契约当事人间发生纯粹经济损失的情形，尤其如此。因此，她提出，以加害人与被害人之间有无利益交换作为起点，在合同责任和侵权责任这两个极点之间，存在无数有层级的利益交换的中间形态。而利益的交换，又可分为自愿交换和非自愿交换。利益本身，又可分为期待利益与完整利益。所谓期待利益，即信赖合同有效成立所得的利益（信赖利益）或因合同履行所得的利益（履行利益）；而完整利益，即被害人于损害发生前完整状态的利益。从而在合同责任与侵权责任这两个极点之间，形成了逐渐增加的利益交换的序列，在此序列中，每一类纯粹经济损失均有其位置。由于合同责任是当事人自治的结果，而侵权责任具有其他价值因素因而限制个人自治，所以她认为，当事人间利益交换的自愿程度越高，所造成的纯粹经济损失的责任则越接近合同责任，其损害赔偿，则越应该按照合同法来加以规范；而当事人间利益交换的自愿程度越低，所造成的纯粹经济损失的责任越接近侵权责任，越应该以侵权责任法来对其赔偿责任加以规范。按照这种方式，她将纯粹经济损失分为五种情形：（1）双方当事人之间具有契约关系，被害人因给付不能、给付迟延、不完全给付所遭受的纯粹经济损失，

---

① 葛云松：《纯粹经济损失的赔偿与一般侵权行为条款》，载《中外法学》2009 年第 5 期。

② 王泽鉴：《侵权行为》，北京大学出版社 2009 年版，第 297 页。

③ [意]毛罗・布萨尼、[美]弗农・瓦伦丁・帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 8-12 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

受合同法规范。（2）双方当事人之间虽无契约关系，但存在着利益的自愿交换。此时双方并非无任何关系的陌生人，而是可能具有某种特殊的信赖关系或密切关联性，例如缔约过失责任，或一方具有特别的专业知识或自愿承担责任。（3）双方当事人之间既无合同关系，且也非自愿交换利益，但依据具体情况，一方必须尽到相当程度的注意义务，例如遗嘱案件。（4）双方当事人之间，既无合同关系，且也非自愿交换利益，为加害人侵害第三人的生命、身体或所有权，而导致被害人受到纯粹经济损失。（5）纯粹经济损失发生权利化现象，因此构成过失侵权责任，或者加害人故意以违背善良风俗的方法损害他人，或加害人违反保护经济利益的法律，致使受害人遭受纯粹经济损失，则均应该依据侵权责任法加以规范。[①]

邱琦博士的分类法，其实是把整个民法领域中的纯粹经济损失问题，作整体全面的考虑，并且以利益的分类及利益交换的自愿程度作为划分标准，分别确定各种类型与合同法和侵权法的密切程度，从而找出适合的调整手段。这一划分方法与我们前面一章的分析，有契合之处，比如我们也认为双方具有合同关系及类合同关系是，成立纯粹经济损失赔偿责任需要考虑的重要因素，但是这只是需要考虑的因素之一，还有许多其他因素也具有很重要的意义，但这种分类方法并没有揭示出来。

上述学者的划分方法，无疑都具有一定的法学理论和实践意义，但是这些类型划分更接近于抽象的概念，缺乏具体性和直观性，并且类型之间的交叉和重叠较多。

二、实践中的常见类型

上述学理上的分类是学者在复杂的纯粹经济损失现象中高度抽象出的一些类别，而实践中各国经常讨论的类型有：

（一）电缆案件

实务中的常见类型，即加害人过失损害某物，造成其所有人的财产损失，然而却导致第三人遭受纯粹经济损失，为反射损失的一种。英国的 Spartan Steel v Marting 一案是这类纯粹经济损失的经典案例。[②]

（二）遗嘱无效案件

也是实务中的常见类型，即律师或公证人因过失导致提供的服务有瑕疵，并因

---

① 邱琦：《纯粹经济上损失之研究》，国立台湾大学法律学研究所 2002 年博士论文，第 11-13 页。

② 具体案情见上文第 11 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

此而导致第三人遭受纯粹经济损失。典型案例是英国1985年的White v. Jones案，父亲与两个女儿吵架，因此修改遗嘱剥夺了她们的继承权。后来双方和好，父亲准备改回遗嘱，重新给她们分配遗产，然而由于父亲委托的律师的过错，在父亲死亡前未能及时修改遗嘱，导致两个女儿未能继承遗产。于是他的两个女儿起诉律师，要求承担赔偿责任。法院判决律师在服务中存在过失，因此应承担赔偿责任。该案中女儿的损失就是纯粹经济损失。[①]

（三）不实陈述案件

实务中的常见类型，即具有专业技能的专门职业者（如会计师、鉴定人等）过失作出不符合事实的说明，导致信赖该陈述的第三人遭受损害。该第三人通常与专业人士并无合同关系，但却信赖专业人士的陈述，并以此为据作出某项安排，但因该陈述并非事实，因此而遭受到纯粹经济损失。在此领域颇具代表性及指导意义的案例是英国上诉法院1964年判决的Hedley Byrne & Co. Ltd. V. Heller & Partners Ltd.案。[②]

（四）公共设施损害案件

也是日常生活中最常见的纯粹经济损失类型，指行为人过失损坏某些公共设施，而导致依赖此设施的人遭受纯粹经济损失。此类案件中，最常见的是交通堵塞案件，行为人过失造成交通事故，将使大量的人遭受经济损失，如不得不绕道而导致增加汽油费或车费，有些人因迟到而被单位罚款，还有人因迟到而丧失晋升机会或丧失订立合同的机会等等。这类案件与电缆案件类似，也是会产生无数的原告。

（五）雇员和家庭成员人身伤亡案件

雇员人身伤亡尽管不是对企业经营权的直接干扰，但也将使企业的经营受到影响，造成企业的利润损失。家庭成员的人身伤亡将使其他家庭成员支出医疗费、护理费等导致现实财产的减少以及可得收入的减少。此类案件中，雇主和家庭成员并没有任何有形损害，遭受的仅是经济损失，为纯粹经济损失。

（六）第三人侵害债权案件

第三人侵害债权，一般造成债权人的合同债权不能实现，但并没有损害债权人的人身健康或其它有形财产，因此给债权人造成的损失也仅为纯粹经济损失。通常

---

① 龚赛红：《中国民法视野中的纯经济损失——兼评我国的研究现状》，载《北京化工大学学报》（社会科学版）2008年第4期。

② 具体案情见上文第16-17页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

包括非法引诱债务人违约、与债务人恶意串谋不履行合同义务和直接侵害债务人的人身、自由或财产并造成债务人不能履行合同义务等情形。

第二节　反射损失

一、概述

典型的“反射损失”产生于一方当事人财产或人身受到实际损害，而该损害进而引致原告权利受损的情况。这种情况是三维式，一些学者也将其称为“关联经济损失”。直接受害人受到了某种实际损害，而原告则是只发生经济损害的次级受害人。[①]

反射损失通常包括两种类型：侵害某人的人身（死亡或伤害），致其他与该被害人有亲属或契约关系之人受有财产损失；侵害某人之物，致其他之人（尤其是债权人）遭受财产上损失，此类损失的典型代表为“电缆案件”，后文将以电缆案件为典型进行分析。

二、各国的具体观点

（一）人身伤害导致的反射损失

1．英国

在英国法中，在非法造成人身伤害案件中，侵权人对任何遭受经济损失的第三人不负有注意义务，因为他与受害人之间没有合同。对第三人经济损失案件的法律政策是，除非在非常特殊的情形下，譬如由于非法死亡导致依赖者遭受赡养费或者对家庭受害成员支付的医疗费用，否则这种损失应该存在于他们产生的情形中。[②]

2．德国

在德国法中，在非法造成人身伤害案件中，遭受经济损失的第三人对侵权人不能根据《德国民法典》第 823 条第 1 款提起诉讼，因为其绝对权利没有受到侵犯。《德国民法典》第 823 条第 2 款或者第 826 条对其也无助益，因为没有证据表明侵

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 9 页。

② [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 185-186 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

权行为人违反保护他人的法律规定，或者其行为存在故意并且违反了公序良俗。因此，如果因他人造成雇员伤害而导致雇员无法提供服务的损失，雇主没有直接的侵权请求权。但是在雇主根据法律向工人持续支付的范围内，雇主自动代位行使工人对侵权人的请求权。[①]《德国民法典》第844条第2款[②]赋予了那些死者对其有或将有法定扶养义务者的损害赔偿请求权，即“扶养费损失”属于可赔偿性的纯粹经济损失。[③]

3．法国

法国作为放任性体系的代表，对因人身伤害或死亡而导致的反射损失赋予请求权。雇主支付给受害工人的工资和其他花费，将由侵权行为人全额偿还。雇主同时拥有两种请求权，一种是根据一般条款直接从其自身的权利产生，另一种则是以代位侵权请求权的方式出现。[④]在典型的Football Club de Metz v. Wiroth案件中，上诉法院裁定，任何遭受金钱损失的人，即使是法人，都有权根据《法国民法典》第1382条的规定向加害人索赔。在该案中，一名著名的职业球员在汽车事故中受伤。法院裁定，对于加害人的过失直接造成的损失，俱乐部有权获得金钱赔偿。[⑤]因此，对于第三人反射性的财产损失，原则上保护一切合法利益的法国甚至将合同对方当事人也纳入了这一请求权人的范畴。[⑥]

（二）财产损害导致的反射损失

如果原告因为被告损害第三人的财产而遭受了纯粹经济损失，原告是否有权要求被告对自己的纯粹经济损失承担侵权损害赔偿责任？现代社会，人与人之间的联系越来越密切，第三人财产的使用不仅仅是关乎财产所有权人利益的大事，而且也是关乎那些使用该种财产的人的利益的大事，被告的行为如果导致他人财产的毁损

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第187-188页。

② 《德国民法典》第844条第2款规定：“在侵害发生时，死者与第三人处于其据以对第三人依据法律规定负有扶养义务或者可负有扶养义务的关系中，并且因死者被杀害，第三人被剥夺扶养请求权的，赔偿义务人即必须在死者在推测的生存期间会负有扶养义务的限度内，通过支付定期金向第三人给以损害赔偿；准用第843条第2款至第4款的规定。即使在侵害发生时第三人已被孕育成胎儿但尚未出生，赔偿义务也发生。”

③ [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔著，焦美华译：《欧洲比较侵权行为法》（下卷），法律出版社2001年版，第227页。

④ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第180页。

⑤ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第181页。

⑥ [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔著，焦美华译：《欧洲比较侵权行为法》（下卷），法律出版社2001年版，第227页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

或灭失，遭受损害的将不仅是物之所有权人，而且也包括物之使用人。在此种情况下，被告对物主承担有形损害，各国法律均予以认可，而被告能否对物之使用人承担赔偿责任则存在疑问。原告可能享有合同性财产权益——如租赁合同，或者可能享有非合同性财产权益——如被许可使用。

电缆案件是此类损失中最常见的“标志性”案件类型。这类案件以过失挖断电源电缆导致相关人经济损失的生活事实为典型代表，泛指类似的过失行为导致停电、停水、通讯、煤气管道中断等，进而引发他人停工、停业等经济损失的情形，在现代法律中约定俗成的被称为电缆案件。[①]

在电缆案件中，提供公共服务的公司，如电力公司、燃气公司、通讯公司等在日常生活中常处于经济上的垄断地位，并且在提供服务时，往往会利用其垄断地位，在与接受服务的人签订的格式合同中多订有免除或限制其赔偿责任的条款。[②]还有一些国家，担心这些公共服务性质的公司会承担过重的民事责任而导致破产，因此而影响到社会和经济的稳定，于是对这些行业多采取一定的保护政策。因此，如果因公共服务中断而遭受经济损失的人，往往会因为合同条款的约定或制定法的规定，无法向这些公司请求赔偿，或者无法得到足够的赔偿。于是，有的原告试图起诉过失损坏公共服务设施的人，希望通过侵权法的规定使自己遭受的经济损失得到赔偿。但是在这类案件中，被告损害的电缆等公共服务设施，其所有权属于提供服务的电力或其他有关公司，而非原告所有，原告是因他人财产受到损害而遭到损失，为反射损失，也即原告仅遭受到纯粹经济损失，并无实质损害。[③]

电缆案件是引起巨大纯粹经济损失的典型案件，对涟漪效应的害怕是普遍存在的，一些人甚至怀疑它可能没有尽头，因为物理规律不适用于纯粹经济损失的因果关系。如果没有具体的法律界限，这可能导致无限的，不可预见和难以估量的责任。这个论据似乎被广泛接受，大多数欧洲司法制度都以此种不方便是日常生活中固有的为基础，拒绝对纯粹经济损失予以任何补偿。但是这个理由是不能令人信服的，因为“日常生活中的风险”这个概念是一个模糊的概念，其本身并未揭示拒绝赔偿背后的内在的政策选择。[④]损害事件是普遍存在的这样一个事实，其本身并不能证

---

① 王泽鉴：《侵权行为法》（第一册），中国政法大学出版社 2001 年版，第 100 页。

② 张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 670 页。

③ 张国宏：《纯粹经济损失研究》，中国人民大学 2006 年博士学位论文。

④ Willem H. van Boom, Pure Economic Loss: A Comparative Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.26.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

明没有责任，因此需要对其背后的政策考量作进一步的阐述。

1．英国

在英国，电缆案件中的停工损失是不能获得赔偿的。因为英国法官认为仅纯粹的生产损失而没有对财产造成任何实际损害时，根据责任排除规则是不能获得赔偿的。典型的案件为 Spartan Steel v. Martin 案，[①]法院以丹宁勋爵的观点为代表认为，此类纯粹经济损失不应赔偿的主要理由是对诉讼泛滥的担忧，而且总体而言用户所受的损失并不大，通常仅为一定的不便，且也可通过一定的方式，如投保或自备发电器等来避免或减轻损失，因此属于原告在社会生活中应当容忍的损失。而且如果允许对此类纯粹经济损失进行赔偿，将会使被告面对无数的原告与赔偿请求，并且损害的查证极为困难，因而甚至会引发道德风险，所以不应该赔偿。[②]

丹宁勋爵的见解在英国法中得到普遍认可，成为英国法院对于电缆案件的基本态度。然而从丹宁勋爵不予赔偿的理由上可以看出，此种主张是基于常识和经验得出的结论，而并非遵循法律逻辑的结果。他认为，电缆案件中的纯粹经济损失，通常就是一种生活风险，是每个人都应当忍受的生活风险，而风险应由遭受损失的社会团体来承担，而不是由一个个体来承担，这虽然没有多少逻辑，但它仍是法律。[③]

因此，对于电缆案件中纯粹经济损失的赔偿，英国法多出于政策的考量，采取责任排除规则而对损失不予赔偿，只有在极少数的案件中，如果受到损害的原告人数有限甚至是唯一的，而且被告对于原告损害具有高度的可预见性时，才可能会得到例外地赔偿。然而，这种例外要求的条件很严格，因此出现的例外情形非常少见。[④]

2．德国

在德国，根据《德国民法典》第 823 条第 1 款，无论是直接造成损害的发生抑或经过系列事件传导后造成了损害，任何人都须对其造成的人身伤害或者财产的损害承担责任。如果为了维持特定的目标就必须有不间断的能源供应，那么切断供应导致目标不能实现的人，在法律上同时造成了目标不能实现的损失。因此在电缆案

---

① 具体的案情及判决见上文第 11 页。
② [1973]1 Q. B. 27, at 37-38.
③ 张国宏：《纯粹经济损失研究》，中国人民大学 2006 年博士学位论文。
④ 张国宏：《纯粹经济损失研究》，中国人民大学 2006 年博士学位论文。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

件中，如果原告受到了财产损失（机器损失）时，他就有权根据《德国民法典》第823条第1款请求赔偿。这种请求包括了已出现的金钱损失，因为这种损失并不纯粹是经济方面的。[①]依据《德国民法典》第252条[②]的规定，失去的利益也包括在内。

所以在德国电缆案件中，如果原告能够证明自己受有有形损害（机器损失）时，他们就可连同间接经济损失获得赔偿。[③]也就是说，如果在电缆案件中，原告不仅受有停工损失，而且机器也受到了有形损害时，则机器损失和停工损失都能获得赔偿，因为这里德国法院将停工损失视为间接经济损失，而不认为其是纯粹经济损失。

但是如果原告不能证明他们受到了财产损失，而仅有停工损失，则其不能获得赔偿。企业所有权人曾试图在这类案件中援引“已设立且正营业的商业企业的权利”作为获得赔偿的依据。但是，他们没有成功，因为德国联邦法院认为，在（公用）电缆受损导致生产损失时，“已设立且正营业的商业企业的权利”并没有受到影响。为了认定侵权，法庭一直以来要求，被告的行为必须与企业经营具有关联关系，如行为直接指向企业或者对其事务尤其是对诸如市场营销活动的经营进行了干涉。但是，假如被告的行为仅仅像对其他受害人或者其财产，比如其他家庭、消费者等造成了影响一样，影响了企业，这是不够的。由于绝对权未受到侵害，原告的损失属于纯粹经济损失，不能根据《德国民法典》第823条第1款获得赔偿。并且，德国联邦法院认为，一些法典中的个别条款的立法目的并不在于保护停电造成的生产损失，因此原告也不能依据《德国民法典》第823条第2款获得赔偿。而且，原告如果不能证明被告的行为存在故意和恶意，则也不能依据《德国民法典》第826条获得赔偿。[④]因此，在电缆案件中，如果原告仅有停工损失，则在德国被视为纯粹经济损失，原告不能获得赔偿。

3．法国

在法国电缆案件中，原告根据《法国民法典》第1382和第1383条之规定，原则上可以就停工损失获得赔偿。因为理论上，在法国法中，财产损失和纯粹经济损

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第139页。

② 《德国民法典》第252条“所失利益”规定：“待赔偿的损害也包括所失利益。根据事物的惯常运行或者特殊情况，特别是根据所作的准备和所采取的预防措施，可以极大的可能性期待得到的利益，视为所失利益。”

③ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第143页。

④ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第150页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

失没有任何区别，两类损失都属于实际损失这一大类。因此案件调查的重点将集中于生产损失是否足够直接以及是否应当认定因果关系具有充分性的问题上。如果原告的赔偿请求存在阿喀琉斯之踵（Achilles heel）般的致命弱点，法官将以因果关系的措辞对其进行认定和表述，譬如主张失去的利润不确定，或者质疑相同的损失是否由于不同的方法或者不同的原因所造成的。因此，因果关系一般规则中固有的巨大灵活性，为一定程度上的默示决策留有余地。[①]

三、成立责任的要件分析

（一）人身伤害导致的反射性损失

根据普遍观点，对于人身伤害导致的反射性损失的请求不予考虑，基本理由是：允许请求将会导致法律界限和后果不确定，重点在于受损害一方仅仅是第二受害人。这个立场基本是合理的，因为我根据们前面所分析的反对责任的因素几乎都适用于这样的案件，如可能产生大量的原告，侵权人与第二受害人之间没有近因性，侵权人对第二受害人所遭受的经济利益没有可预见性。赞成责任的理由只有一个能被接受，即对于侵权行为人来说，没有附加额外的注意义务，因为不管怎么说，他都禁止伤害他人，这与第二受害人的纯粹经济损失无关，因此对可能被间接伤害的后者的保护，没有对侵权行为人增加额外的注意义务。但是仅有这一个赞成的理由，是不足以成立责任的，因为这个理由自身没有足够的份量来反驳所有的反对理由，只有当这个理由同其他理由相结合，才有可能成立对纯粹经济损失的责任。

根据侵权责任构成要件分析，也可以得出同样的结论。首先，原告受有损害；其次，由于第二受害人可能众多，且其与原告之间的关系为被告所不知的，所以通常情况下被告对于原告受到损害是不可预见的，所以不能认为被告负有过错。

因此，此种案件中对于第三人的纯粹经济损失，通常是不用赔偿的。

（二）财产损害导致的反射性损失

根据我们前面章节所分析的成立纯粹经济损失责任时应考虑的因素，显示在电缆案件中，反对赔偿的因素占了绝对多数：第一，一般情况下，原告不存在故意，而只是过失挖断电缆。第二，电缆案件似乎是无限损失的经典例子，因为能够导致

[①] [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第128、154页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一连串的损害，因此诉讼闸门的理由非常充分。第三，通常原被告双方互不认识，双方之间没有近因性，即没有特殊关系，没有类合同关系。第四，原告仍有保护自己的手段，如自备发电器以防止此类损害的发生。第五，原告的经济损失对于被告来说，是不明显的且没有具体的内容，也即被告对原告的经济损失没有可预见性。第六，一般而言，这样的经济损失对于原告来说具有较少的重要性。唯一赞成成立责任的因素是被告没有负担额外的注意义务，因为不管第三方的经济利益如何，在电缆案件中被告应该尊重所有人的财产，所以没有强加被告以额外的注意义务。但是单独此一个赞成因素是不足以成立责任的。

根据侵权责任构成要件来具体分析是否能够成立纯粹经济损失的赔偿责任：首先，原告的损害，大多数时候并不具有严重性，只是轻微的生活上的不便；其次，被告没有故意，只是过失挖断电缆，能否构成过错，还要考虑具体因素：首先双方当事人之间没有特殊关系或近因性，也不存在合理的信赖关系，也没有金钱上的利害关系，因此被告对原告的损失没有预见的可能性，多不能构成过错。而且原告可以通过自备发电器来防止此类损害的发生，因此原告对于损害的发生也是具有过错的，可以适用与有过错理论。

根据以上分析，可以得出结论，在这样的案件中，第三方的纯粹经济损失是没有必要赔偿的。但是在特殊情况下，如果电缆是专供原告使用的，而且被告对于原告的损害是易于察知且可预见的，在此种情况下，根据案件的具体情况，法官有可能会认定被告存在过错，原告的纯粹经济损失有可能得到赔偿。但这只是极少数的例外情况。

（三）例外救济

大多数法律制度承认，在人身伤害和不法死亡的案件中，对于配偶和孩子失去的扶养费应当特别给予某种形式的赔偿。在这样的案件中，责任排除规则的例外适用是合理的，因为有相当多的重要因素赞成对配偶和孩子失去生活费进行赔偿：首先，不会产生大量的原告，因此诉讼闸门理由不成立；其次，不会对侵权行为人附加额外的注意义务，因为他必须要尊重受害人的人身，也就是他侵犯了最高等级的权利，即对生命和健康的权利；再次，配偶和孩子的扶养费是易于察知的且有明确的内容，因此侵权人对此具有可预见性；最后，配偶和孩子的生活费损失对他们来说是非常重要的，他们的生活依赖于受害人的生活费，因此他们的生计受到了严重

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的威胁。

而且这样的例外情况下也是符合侵权责任的构成要件的，首先，配偶和孩子受到严重的损害；其次，被告对于配偶和孩子失去的扶养费损失具有预见的可能性，因此可以认定被告存在过错；最后，配偶和孩子的损失与被告的加害行为之间存在因果关系。

因此，在人身伤害和不法死亡的案件中，对于配偶和孩子失去的扶养费应当特别给予某种形式的赔偿，而且这也是公平公正合理的，符合法律的人文主义关怀。

四、实例分析——重庆电缆案

（一）案情介绍[①]

2005 年 7 月 15 日 9 时许，被告重庆市黔江区永安建筑有限责任公司（简称永安公司）在所承包金三角河堤段工程的施工过程中，损坏了被告供电公司埋在该地段的 10KV 电力电缆，导致输电线路中断，造成原告民族医院停电 26 小时，影响了原告民族医院的正常经营。事故发生后，被告永安公司于当日支付被告供电公司维修材料费 10000 元。被告供电公司于次日上午将被损坏的线路予以修复，并于 12 时左右恢复通电。原告民族医院认为由于被告的行为导致其营业损失，于是起诉到法院要求被告永安公司与电力公司赔偿其损失 3 万余元。

一审法院根据《电力法》第 60 条第 3 款之规定，认为被告永安公司在建设施工过程中，因其注意义务不够而损坏了被告供电公司的电力设施，导致停电事故发生，并影响原告民族医院的正常运行而造成其可得收入减少，其行为符合侵权行为的构成要件，而被告供电公司在其供电设施遭受损坏后积极履行抢修义务，其行为无过错，不应承担民事赔偿责任。于是判决被告永安公司赔偿原告民族医院经济损失 25000 元。

二审法院重庆市第四中级人民法院认为，供电公司与民族医院之间存有供用电合同关系，供电公司没有对涉案电缆线实施侵权行为，也没有与永安公司共同实施侵权行为，故民族医院基于侵权之诉向供电公司请求赔偿不当，供电公司在本案中不对民族医院负赔偿责任。而用户因电缆被挖断而遭受损失，系“后续损害”，该种情形下的“后续损害赔偿”，一般仅限于人身权、所有权，即除经济损失系因用

[①] 参见重庆市高级人民法院编：《重庆审判案例精选》（第二集），法律出版社 2007 年版，第 191-196 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

户的人身或所有权遭受侵害而发生者外，原则上不予赔偿。并且认为纯粹经济上损失应否赔偿，一般从以下几个方面进行考量：1、电力企业是法定的供应者，因过失不能提供电力时，无须对消费者所受的经济上损失负赔偿责任；2、电力中断，事所常有，事故发生后，人身或物品未遭受损害的情况下，虽对人们的生活造成不便，有时产生经济上损失，但电力供应短期即告回复，纵有经济损失，亦属轻微，一般人观念中多认为对此应负容忍义务。有人自备供电设施，以防意外；有人投保，避免损失等等；3、被害人对于此等意外事故，若皆得请求经济上损失的赔偿，则其请求权将漫无边际，严重地加重了加害人的赔偿义务，有违公平正义，也不利于整个社会经济的发展。综上所述，除经济损失系因用户的人身或所有权遭受侵害而发生外，原则上不予赔偿。对《中华人民共和国电力法》第 60 条第 3 款的适用，应当基于上述适当限制加害人赔偿责任的政策考量，对“损害”作限缩解释为因“人身或所有权遭受侵害而发生的损害”。因此认为民族医院要求赔付停电期间的营业损失，性质属于纯粹经济上损失，于是判决驳回原告的诉讼请求。

（二）判决分析

原审法院认为原告民族医院的收入损失与被告永安公司挖断电缆线导致停电的事故之间有相当因果关系，且根据《电力法》第 60 条第 3 款之规定“因用户或第三人的过错给电力企业或其它用户造成损害的，该用户或第三人应当依法承担赔偿责任”，判决被告永安公司赔偿原告民族医院一定的收入损失。

二审法院认为虽然被告的行为与原告的损失之间具有一定的因果关系，但是原告的损失为后续损害，为纯粹经济损失，并且将《电力法》第 60 条第 3 款规定之“损害”作限缩解释为因“人身或所有权遭受侵害而发生的损害”，于是根据诉讼闸门、优越法益及日常生活中固有的风险等理由，判决被告无需对原告承担赔偿责任。

这起案件是典型的电缆案件，被告过失挖断电缆，导致原告停电，因此减少了营业收入。原告的损失是纯粹经济损失，是因第三人的财产损害而导致的反射损失，二审法院的判决理由显然是参考了丹宁勋爵在 Spartan Steel v. Martin[①]案件中的判决理由。[②]应该讲二审法院的判决理由还是比较充分的，且判决结果也是正确的。但

[①] 具体案情见前文第 11 页。
[②] 具体判决理由见前文第 19-20 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是这个案件如果运用侵权责任的构成要件来分析，可能更有说服力。因为被告对原告的损害没有预见的可能性，而且原告自己也应当通过自备发电设施来减轻此类损害的发生，因此原告自己对于损害的发生也具有一定的过错，所以被告没有过错，从而不应当对原告的营业损失承担赔偿责任。

第三节　转移损失

一、概述

转移损失的情形是指，C 造成了 B 财产或人身的实际损害，但 A 和 B 的合同（或法律本身）将通常属 B 的损失转移给了 A。因此通常落在原始受害人头上的损失却转移给了次级受害人。损失从其“自然”承受人转移到“偶然”承受人使其区别于反射损失的情形。在反射损失情形下，所涉损失并未发生转移，而是对次级受害人利益的单独损害。这些转移经常发生于租赁、买卖和保险协议或其他合同。该等合同将财产权利与使用权利分开，或者重新分配具体的风险分担。

转移损失发生的典型案例有两类：（1）因合同而发生的转移，如 A 与 B 就 B 的船舶签订期租合同，而 C 的过失行为导致船舶不能行驶，致使 A 在修理期间内不能利用该船。这里 B 受到财产损失，并且通常 B 作为所有权人也可获赔因船只不能使用引致的间接损失。但根据船舶租约，船只的使用权被转移给了 A。因为 A 不存在任何财产损失，他受到的只是纯粹经济损失。因此，通常应属 B 的损失因双方之间的合同关系而转移给了 A；（2）因法律规定而发生的转移，如 A 的雇员 B 因 C 的侵权行为而导致数月不能工作。然而制定法要求 A 继续支付 B 的薪水，即使 B 不能完成相应的工作。因此，通常应属 B 的损失却因为制定法的规定而转移给了 A。这就是 C 的过失行为和工资继续支付法令共同作用的结果。下文将以此两个典型案件进行分析。

二、各国的具体观点

（一）因合同关系而发生的转移损失——船舶租赁案件

1．英国

在英国，遭受船难的船舶承租人对于为碰撞事故负责之人，既不能就碰撞事故

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

发生前的成本获得赔偿，也不能就由于修理而取消的航行收入获得赔偿。[①]

在 the Mineral Transporter 案件中，枢密院同样为英国法阐明如下，为使用船舶而支付费用的租船者，对于船舶受损导致的经济损失没有赔偿请求权。这一案件遵循了 Spartan Steel v. Martin 的基本原则，目前普遍认为，在财产因过失受有损害时只有对该财产存在所有者权益或者占有利益的人能对经济损失提起诉讼的定理方面，该案是个权威。根据 the Mineral Transporter 判决，为了侵权诉讼的目的，并无足够的理由赋予排他性使用海船的海事合同以占有利益。[②]

英国法中通过司法政策解释其立场，支持将海船的保险费用施加于对于使用海船有经济利益关系的人。在租船合同中，在租赁期间，承租人在法律上比所有权人具有更强的占有权利；法院倾向于认为，承租人而非所有权人应当承担使用海船的损失风险，并且因此对此风险进行投保。[③]

2．德国

在德国，遭受船难的船舶承租人就失去的利益对于为碰撞事故负责之人具有侵权请求权，但前提是它已经占有该船舶。[④]

由于和违法行为人之间缺乏合同关系，承租人请求权的依据只能是侵权。惟一可论证的适用条款是《德国民法典》第 823 条第 1 款。因此，船舶承租人必须证明其绝对权利受到了侵害。根据租赁合同，使用船舶的权利不是《德国民法典》第 823 条第 1 款所保护的权利。在德国法中，承租人不享有财产权。相反，他的权利只是合同上的权利因而是相对权，即只能对抗出租人。对于第三人而言，该权利本身不能受到保护。但是，合法占有一般认为是一种受《德国民法典》第 823 条第 1 款保护的绝对权利（即其他权利）。占有人不能就物件的实际损害主张赔偿——这种损害是侵犯所有权人的财产权，因此请求权一般属于所有权人本人。但是，如果占有人有权使用该物并且损害造成其用途减少，这就构成对占有的侵犯，占有人可就此获得赔偿。因此，如果承租人已经占有该海船，它就可以获得赔偿。如果损失发生

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 221 页。

② [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 221 页。

③ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 221 页。

④ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 225 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于承租人接管海船之前，受到影响的则仅仅是合同权利，则不存在请求权。[①]

3．法国

在法国，根据特别海事法律基于过错分配责任的规定，加上《法国民法典》关于可获赔损失性质和范围的规则，船舶承租人应当就其损失从为碰撞负责的船东处获得赔偿。根据过错原则，被告所有权人将为船员的过失承担代负责任。船舶承担人必须证明因果关系，以及损失的确定性和直接性。[②]

4．小结

关于承租人对收入损失的赔偿请求，这个问题显示出私法中包含的概念对纯粹经济损失的分析是何等的重要。本案暗含的概念与侵权法会予以保护的财产利益和合同利益的种类相关。对海上碰撞事故存在过错的当事人是否侵犯了船舶承租人获得认可的利益，或者侵权人是否仅仅侵犯了承租人基于合同条款的排他性占有船舶的合同权利？根据这些“利益”的性质和顺位，不同体系给予不同的解答。

在英国这样的实用式体系中，我们看到这种利益被视为不足以成为过失请求权的依据。海事合同可能会授予原告以占有利益，但是这并不足够构成使用船舶的占有权利。因此，船舶承租人损失的收入并非源于侵权法认可和保护的先前财产利益，由此这属于不可获赔之纯粹经济损失。

在德国保守式体系中，原告的占有权益在侵权法获得略高程度的保护。德国的律师不主张承租人的合同权利应作为财产权利获得保护，相反他们认为这是《德国民法典》第823条第1款下的其他权利，并且因此可以将其归入绝对权利的范围。但是，从这一结果来看，他们对侵害的原告实际占有（其间占有人和物之间存在直接性）和侵害其仅仅是占有的权利做出了区分。只有第一种才能获得阿奎利亚责任的保护。可以得出，如果在碰撞事故发生之际公司实际占有船只，德国法将对承租人的收入损失给予赔偿。我们将会注意到，在区分这种占有权的不同顺序时，这种体系似乎提供了一种混合种类的法律认可，这种认可似乎在财产和合同之间混合。因此有学者认为，这种对某物享有的个别权利是一种第三类权利。

在法国这样的放任式体系中，船舶承租人受影响利益的性质对于解决问题作用

[①] [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第225页。

[②] [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第217-218页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

甚微或者没有作用。即使将承租人对船舶的利益描述为不过是在承租期间进行占有的合同权利，如果能够相对确定地证明损失的数额，那么被剥夺的利益也可能获得赔偿。对这些国家而言，侵权人过错侵犯的仅仅是相对权（也称为“相对”权利）也可能成为施加阿奎利亚责任的起点。

（二）因法律规定而发生的转移损失——雇员受伤案件

1．英国

对于支付给受伤雇员的金钱，雇主不能从侵权行为人处获得赔偿。在英国法律中，无论是根据成文法还是合同约定，病假工资都是可予扣除的救济金，侵权行为人及其承保人可以要求将病假工资从人身伤害赔偿中扣除。[①]

在英国法律中，如果发生不法人身伤害，侵权人对任何遭受经济损失的第三人并不负有注意义务，其理由或者是侵权人与受害人之间存在合同，或者根据法律规定他们必须将救济金移交给受害人。因此，在类似的案件中，雇主无权请求侵权人赔偿病假工资或者任何其他支出。[②]

在衡平法中，总是可能发生代位诉讼。但是如今，仅在保险金赔偿案件中才能清晰地看到这一原则的适用。在针对人身伤害事故的政策中不发生代位清偿，因此其功能不适合于弥补雇主不得不向受伤雇员支付工资或者病假工资发生的损失。[③]

2．德国

在德国，只有通过代位行使雇员自身的请求权，雇主才能对受伤雇员的支付获得侵权行为人的赔偿。

根据《德国民法典》第823条第1款规定，雇主没有请求权，因为他的绝对权利没有受到侵害。第823条第2款及第826条对他也无济于事，因为没有证据显示侵权人违反了保护雇主的法律，或者其行为存在故意而且违背了公序良俗。最后，雇主也不能根据第845条[④]的规定对损失的服务请求赔偿，因为该条款仅适用基于法律产生的义务，而不适用像本案那样根据合同产生的义务。总之，对于他人造成

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第173页。

② [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第173页。

③ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第173页。

④ 《德国民法典》第845条规定：“在杀害人、侵害身体或者健康的情况下，以及在剥夺自由的情况下，受害人依照法律规定对第三人负有在家务或者工商业中提供劳务的义务的，赔偿义务人必须通过支付金钱定期金向第三人对失去的劳务给予赔偿。”

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

雇员伤害而导致雇员无法提供服务的损失，雇主没有直接的侵权请求权。[①]

根据 1994 年持续支付法令第 3 条的规定，雇主对工人负有持续支付费用的义务。同时，该法第 6 条规定，在雇主根据法律向工人持续支付工资的范围内，雇主自动代位行使工人对侵权人的请求权。因此，雇主可以通过提出代位请求权而对违法行为人提起诉讼。[②]

通过法律规定赋予直接代位权的作法维持了侵权法的基本原则，即任何人不能对其由于他人绝对权利受到侵犯而遭受的损失请求赔偿。这一原则还同时避免了工人不正当的收益和雇主的过度损失。当法定代位权规则不适用，法庭即会暗示，雇主代位行使工人的权利是雇佣合同中的一项义务。[③]

3．法国

雇主支付给受伤雇员的工资和其他花费，将由侵权行为人全额偿还。根据 1985 年 7 月 5 日法令第 29 条的规定，对雇员支付病休期间全部薪水的雇主有权向加害人提出请求，要求其赔偿已支付的金钱。根据该法第 30 条的规定，雇主在这种情形下代位行使受害人对加害人的追诉权利。但是，例外的是，他不能就受害人的精神损害赔偿权利行使代位权。雇主分期支付的任何社会保险款项，雇主也可根据该法令第 32 条的规定获得赔偿。[④]

三、成立责任的要件分析

根据我们前面章节所分析的成立责任时应考虑的因素，也认为应该允许对转移损失进行赔偿。首先，诉讼闸门理由不成立。因为承受转移损失的次级受害人，根据合同关系或根据法律规定是确定的，且没有无限多原告的危险。第二，对于侵权行为人没有附加额外的注意义务，因为侵权行为人本来就负有保护原始受害人的人身权和财产权的义务。第三，损失是可以预见的，因为如果没有原始受害人和次级受害人之间的合同关系或法律规定，同样的损失是发生在原始受害人身上，只是由

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 176 页。

② [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 176 页。

③ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 176 页。

④ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 166 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于原始受害人和次级受害人之间有合同关系或由于法律的相关规定，将本应由原始受害人承受的损失转移给次级受害人。

根据侵权责任的构成要件进行分析，也得出同样的结论。首先，原告受到了损害，此种损害是正当的且具有严重性；其次，被告有过错，因为被告对损害的内容和数量具有预见的可能性，也没有导致被告承担额外的注意义务，所以被告对原告的损失是具有预见的可能性的，因此应认定被告存在过错；最后，被告的行为与原告的损失之间具有因果关系。所以在转移损失的案件中，对次级受害人的损失进行赔偿是合理的。

从侵权行为人责任的角度而言，转移损失的安全对其是中性的，而且它可能带来的困难更多的是技术上问题而不是政策或者衡平问题，必要时可以引入代位请求的方法，因此也可避免对不确定责任的担心。支持做出赔付判决的另一些理由是：虽然一些规则的意外适用纯属偶然地排除了他的责任，但对原始受害人明显负有责任的侵权行为人不应从中受益。根据冯•巴尔的说法，转移损失的概念目的在于“避免一些人求助于那些原意不是保护他，而是保护其他人的规则”。[①]

第四节　公共市场、运输通道和公用设施的关闭

一、概述

在公共市场、运输通道和公用设施的关闭类案件中，经济损失不是产生于此前对任何人财产或人身的伤害。也许存在实际损害，但它是对公共领域里“不属于个人所有的资源”的损害。一个单纯的过失行为可能导致不得不关闭那些没有所有权人的市场、高速公路和航道。但关闭行为直接地把经济损失加之于那些其生计密切地信赖于这些设施的人们。

公共设施损害案件，如同电缆案件一样，也是引起巨大纯粹经济损失的典型案件，对涟漪效应的害怕是普遍存在的，一些人甚至怀疑它可能没有尽头，因为物理规律不适用于纯粹经济损失的因果关系。如果没有具体的法律界限，这可能导致无限的，不可预见和难以估量的责任。这个论据似乎被广泛接受，大多数欧洲司法制

[①] [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第9-10页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度也都以此种不方便是日常生活中固有的为基础，拒绝对纯粹经济损失予以任何补偿。[①]本文将以交通堵塞案件为典型进行分析。

二、各国的具体观点

（一）英国

在英国法中，交通堵塞案件中的原告的纯粹经济损失不能获得赔偿，因为根据上诉法院在 Spartan Steel v. Martin 中采用的过错经济损害方法，对于其他道路使用者不存在过错法上的注意义务——避免阻碍道路以防止对其造成纯粹经济损失。[②]

一直以来，英国法律就拒绝承认，对非直接源于请求人财产受损的金钱损失提起的诉讼，能够产生建立在过错基础上的法定损害赔偿请求权。在特别情形下，这一规则可能存在例外。但是，对于这些例外来说，核心问题是近因关系、责任承担以及伴随信赖。而在交通堵塞案件中，显然不具备任何一条。另外，布里奇法官在 Caparo 案中将其解释为“这种情形应当是这样的，即法院认为为了另一方的利益而对于一方施加特定范围的注意义务是公正、公平和合理的”。然而，根据公共政策考虑，没有人会认为在交通堵塞这样的案件中认定注意义务是合理的。因此，正如丹宁勋爵所评论，“这种风险应当由整个社会来承担而不是由某一方来承担。”[③]

（二）德国

在德国法中，交通堵塞案件中的原告不能证明《德国民法典》第 823 条第 1 款规定的权利遭到了侵犯。陷于交通堵塞的人，其自由受到侵犯。但是，对于 《德国民法典》第 823 条第 1 款的自由的一般解释并不支持上述主张。主流观点认为，它仅仅包括个人人身自由的能力比如离开某地，由于交通堵塞案件中原告仍可以离开现场，狭义上他仍具有这种自由。通过特定的运输方式比如轿车自由移动，并不受《德国民法典》第 823 条第 1 款的保护。将车辆被限制视为侵犯了原告的财产权也是不可能的。联邦法院已经判决，丧失对船舶的使用构成这种侵犯权利的行为，案中有一艘驳船被困在运河中长达几个月。但是，德国联邦法院也曾裁决，通过公共道路进入的土地之所有权人被妨碍了数小时，但他不能对财产权利受到侵犯提出

---

① Willem H. van Boom, Pure Economic Loss: A Comparative Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.26.

② [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 317 页。

③ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 317 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

请求。相对而言，交通堵塞的情况更像第二种情形而不是第一种情形。因此，法院很可能驳回基于侵犯财产提出的诉讼请求。在交通堵塞案件中，使用公路的权利不认为属于《德国民法典》第823条第1款保护的其他权利，另外也不存在根据《德国民法典》第823条第2款的诉讼请求，即根据违反保护他人的法律提出的请求。即使被告违反了交通规则，这些规则的目的也不在于保护其他道路使用者，使其不致因为交通堵塞遭到耽搁。[①]

因此，在德国法中，类似交通堵塞的案件中驳回诉讼请求，是受到了担心责任过度扩大的强烈刺激的。可能的结论是，机动车陷于交通堵塞的人自由受到限制，并且因失去自由遭受的损失属于《德国民法典》第823条第1款的规定范围。但是，德国法院认为这种决定将会使在拥挤的道路上导致事故的任何人，承担一种几乎没有限制范围的责任，而且会导致诉讼泛滥。因此，德国联邦法院已经指出（尽管有些模糊），失去对公路的使用或者通道短期被阻塞，属于任何人都应承担的一般风险。[②]

（三）法国

在法国法中，根据1985年7月5日第85-677号法律确立的汽车事故的成文法责任，原告不能就纯粹经济损失从被告处获得赔偿。但是依然可以根据一般条款，即《法国民法典》第1382条对纯粹经济损失获得赔偿。在有些类似的案件中，马赛市政府对于由于交通事故导致其公共汽车无法运行而遭受的损失获得赔偿。交通阻塞减少了市政府的收入，一审法院认为该损失既不是臆断的损失也不是间接损失。最高法院拒绝撤销该判决，并宣布下级法院的判决在法律上是合理正当的。[③]

因此在法国法中，同电缆案件一样，同样在交通堵塞案件中，也很难说对这种情形下的纯粹经济损失是否可以获得赔偿。法国的法官拥有最大的裁量权，可以不惧最高法院推翻判决而对纯粹经济损失做出是否赔偿的判决。尽管审理法官可能认定这种损失是直接损失，但有学者警告说，这种认定是没有意义的，因为法官根据

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第319-320页。

② [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第320页。

③ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第312-314页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

他们给予赔偿或者拒绝给予赔偿的要求，来认定损失是直接损失还是间接损失。[①]

三、成立责任的要件分析

根据我们前面章节所分析的成立纯粹经济损失责任时应考虑的因素，显示在交通堵塞案件中，同电缆案件一样，反对赔偿的因素占了绝对多数：第一，一般情况下，原告不存在故意，而只是过失造成交通阻塞。第二，交通堵塞案件也是无限损失的经典例子，因为能够导致一连串的损害，因此诉讼闸门的理由非常充分。第三，通常原被告双方互不认识，双方之间没有近因性，即没有特殊关系，没有类合同关系。第四，原告的经济损失对于被告来说，是不明显的且没有具体的内容，也即被告对原告的经济损失没有可预见性。第五，一般而言，这样的经济损失对于原告来说具有较少的重要性。唯一赞成成立责任的因素是被告没有负担额外的注意义务，因为不管第三方的经济利益，在交通堵塞案件中被告应该遵守交通规则，所以没有强加被告以额外的注意义务。但是单独此一个赞成因素是不足以成立责任的。

根据侵权责任构成要件来具体分析是否能够成立纯粹经济损失的赔偿责任：首先，原告的损害，大多数时候并不具有严重性，只是轻微的生活上的不便；其次，被告没有故意，只是过失挖断电缆，能否构成过错，还要考虑具体因素：首先双方当事人之间没有特殊关系或近因性，也不存在合理的信赖关系，也没有金钱上的利害关系，因此被告对原告的损失没有预见的可能性，多不能构成过错。并且即使原告的损失具有严重性，也很难认定原告损失与被告的行为之间具有因果关系。

根据以上分析，可以得出结论，在交通堵塞案件中，第三方的纯粹经济损失是没有必要赔偿的。

第五节　对错误信息、建议和专业服务的信赖

一、概述

那些在经济事务方面提供建议、准备数据和提供服务的人常常都明白，这些信息将被提供给客户，并被那些与之没有合同关系的第三人所信赖。如果粗心地编辑

[①] [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第314页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

或提供了建议、信息或服务，这并不必然构成提供者对其客户的违约（即使构成违约，损害赔偿也被严格限制为经济损失范围）。但信赖的第三人却因此遭受了纯粹经济损失。

这类案件的两个典型是：（1）过失服务：如当一个公证人或律师过失未做一份被请求的遗嘱，遗嘱人死亡，如果正确的立遗嘱，将从遗嘱中受益的预期受益人将因此遭受纯粹经济损失。这是一个对任何法律制度理论界做重要检验的典型案例：继承权的纯粹经济预期应否得到保护？（2）不实陈述：20 世纪侵权行为法发展的一个显著特征就是专家责任的兴起，特别是专家对第三人的民事责任，因涉及纯粹经济损失，其发展更是引人注目。专家第三人民事责任实际上是建立在过失不实陈述行为基础之上的，对此问题应如何规则，成了各国讨论的热点。下文将以此两个典型案例进行分析。

二、各国的具体观点

（一）过失服务类型——遗嘱无效案件

1．英国

在英国，预期的受益人可以就被继承人根据遗嘱打算让其继承的金钱，要求存在过错的公证人或律师进行赔偿。根据上议院对 White v. Jones 案[①]的判决，为客户草拟遗嘱的律师，由于其过错导致受益人根据遗嘱享有的权利无法实现时，必须对遗嘱指定的受益人承担责任。上议院认为，律师过失未做一份对特定第三人有利的遗嘱，是对预期受益人的注意义务的违反，[②]因此应对其遭受的纯粹经济损失承担责任。

由于采用侵权方法对明显不公的情形进行救济，而不是将其交由立法者由其提供法定救济，规定可以根据立遗嘱人的意愿对错误草拟的遗嘱进行修订以将利益赠与。由于此，White v. Jones 案件的判决已经受到了批判。但其仍是个权威判决，它为受益人因遗嘱效力的瑕疵遭受的纯粹经济损失提供了例外的赔偿。[③]

2．德国

---

① 具体案情见上文第 81-82 页。

② Willem H. van Boom, Pure Economic Loss: A Comparative Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.23.

③ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 303 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

德国1961年2月24日《联邦公证法》（2002年4月27日修订）第19条第1款规定，公证人对于违反专业义务直接造成的所有损失（包括纯粹经济损失）承担赔偿责任。此条显然适用于遗嘱案例，因为它规定公证人对于其受雇草拟遗嘱下受益的第三人负有职业义务。德国公证人对于违反职业业务造成的损失根据法律承担责任，主要原因在于他承担公共职能（尽管委托人向其支付报酬）。这种责任的依据在于过错，但是职业标准是很高的，在草拟遗嘱时犯错误明显证明了存在过错。如果被告不是公证人而是律师，结果可能也会是一样的。否则，预期的受益人可以根据“附保护第三人作用之合同”理论以受被继承人和律师之间签订的合同保护的第三人的身份提起诉讼，也能使自己的纯粹经济损失获得赔偿。[①]德国联邦最高法院在1965年作出的遗嘱案是一个很有典型意义的判例。[②]

3．法国

根据法国法，预期的受益人肯定能够从公证人或律师处获得损害赔偿，他或者从公证人或律师的承保公司获得赔偿，或者从保证基金中获得赔偿，或者最后从公证人的个人财产中获得赔偿。根据《法国民法典》第1382条的规定，公证人必须对其错误和遗漏行为承担责任。由此，任何人只要能够证明公证人存在过错（或者疏忽）、自己受有损害以及二者存在因果关系，都可以成功提起诉讼。公证人颁发含有法律错误或者纯粹形式错误的证书是存在过错的。预期的受益人明显遭受了损失，因为他不能继承被继承人希望他继承的遗产。公证人的错误明显导致了纯粹经济损失，预期的受益人将可能获得赔偿。[③]

（二）不实陈述——专家第三人责任

1．英国

英国的主要法律渊源为判例法，是从权威先例中引出具体规则，因此具有针对性和技术性的特点，其并不拘泥于法律自身的体系，而是可以随着社会状况的改变而加以改变。而英国法中专家第三人责任的发展，也集中体现了此特点。

（1）Hedley Byrne案之前的英国法

---

① [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第308-309页。

② 具体案情及判决见前文第34-35页。

③ [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社2005年版，第300页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在普通法的传统上，并没有一般的过失责任概念，主要是通过相对性原则来实现对过失责任的限制。英国1842年的Winterbottom v. Wright案[①]确立了相对性原则，即过失侵权责任只成立于被告对原告负有注意义务时，而注意义务是否存在，则必须从当事人间是否具有合同关系加以推断。[②]即如果当事人间具有合同关系，则存在注意义务，也即可以成立过失侵权责任，否则则无。

在20世纪30年代的Donoghue v. Stevenson案[③]中，突破了相对性原则的限制。在该案中，法官Lord Atkin认为被告对原告承担注意义务，因此应承担过失侵权责任，并提出一项重要的原则——邻居原则，并以可预见性作为认定注意义务存在与否的标准，如果被告对原告的损害具有可预见性，则被告对原告承担注意义务，反之，则无注意义务的存在，成为英国侵权法上最著名的判决理由。然而后来的判例对邻居原则采取了限制性解释，认为此规则只能适用于人身损害或财产损害的情形，而不能适用于纯粹经济损失的情形。[④]

（2）Hedley Byrne & Co Ltd v. Heller & Partners Ltd.案[⑤]及其确立的规则

英国法关于过失不当陈述最重要的判例为Hedley Byrne，该案也是对于过失造成纯粹经济损失予以赔偿的第一个肯定判例。该案确立了一些解释注意义务存在的理论。主要包括：特别关系的理论、责任的自愿承担理论、合理的信赖理论及金钱上的利害关系理论。[⑥]

在Hedley Byrne一案的规则确立以后，出现了很多以此案例为根据进行判例的案件，于是专家对委托人外的第三人承担注意义务的范围被拓展了，以至于专业人士把20世纪60年代到90年代这30年期间称为“黑暗时代”。

---

① [1842]10 M. & W. 109，152 Eng. Rep. 402。基本案情：因被告即马车出租人之疏于维修保养，致原告即马车承租人A之受雇人于驾车时，因马车之瑕疵而受伤。由于原告与被告之间并无契约关系，因此原告不得对被告主张契约责任；又因为以往之判例于认定被告对原告之侵权行为注意义务时，从未曾以被告对第三人之契约义务为依据，因此法院认定原告亦不得对被告主张侵权责任。

② 邱琦：《纯粹经济上损失之研究》，台湾大学法律学研究所2002年博士论文，第96页。

③ 基本案情：原告购买被告所制造之啤酒，开罐饮用后发现液体中残留有蜗牛尸体，造成原告身体健康之损害。

④ 周学峰：《审计师对第三人过失性虚假陈述责任比较研究》，《比较法研究》2007年第6期。

⑤ 基本案情：原告为广告代理商，被告是原告客户E公司的开户行。E委托原告预订电视台的广告时段和报刊的广告版面。按行业惯例，广告代理人是广告合同当事人，须按时向广告主支付费用，而不论其委托人是否已支付费用。原告对E财务状况有所质疑，故向其开户行询问其财务状况，被告回复：E日常商业活动良好，是一值得信赖的公司，原告信赖了该意见。数月后E进入清算程序，原告损失17，000英镑，于是主张被告不负责任地出具存有过失之意见，故诉求其赔偿损失。由于被告口头答复原告时曾声明“不承担责任”，法庭认为该声明等同于一排除责任的声明，导致注意义务不存在，故判决原告败诉。

⑥ 参见张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社2002年版，第645-649页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）Caparo Industries plc v. Dickman 案[①]及其确立的规则

20 世纪 90 年代被 Caparo 案遏制住了专家对第三人承担注意义务的扩张趋势，终结了 Hedley Byrne 案以来的责任不断扩大的局面，Caparo 案代表了英国司法界在专家对第三人责任问题上的转向。

该案终审法院认为对于注意义务的认定，必须是公平且合理的，认为如果让会计师等专业人士对委托人之外的第三人承担注意义务，将使专业人士对不特定人承担不特定的责任，会导致不公平且不合理的结果。[②]显然，法院拒绝认定责任存在的背后，为诉讼泛滥的担忧，这也是影响法院认为注意义务是否成立的重要因素。该案确立了三阶段判断法，来判断注意义务是否存在：损失的可预见性、当事人间关系的近因性、公平公正的政策因素。[③]

因此英国法对于专业人士因不实陈述对委托人以外的第三人承担责任的认定，是从注意义务理论入手，通过三阶段判断法来判断专业人士对特定范围内第三人是否具有注意义务，如果具有注意义务，则承认专业人士对第三人的侵权责任，使第三人的损害可以通过侵权法得到救济。

2．德国

在德国司法实践中，主要用以下方法来解决专家责任问题。

（1）默示成立之资讯合同

德国自帝国法院开始，就把默示成立之资讯合同作为在实务中经常采用的专业人士对第三人承担责任的请求权基础。认为如果某人的职业范围就是对有疑问的事情给予建议，并且其对第三人是知悉的，则如果第三人需要一个可信的资讯，来进行某些事情的处理，如果专业人士在其往来信函中，就重要之点给予了信息，则应该认为双方之间已经成立了咨询合同。[④]虽然这种见解备受争议，但德国联邦最高法院仍然承认默示成立之资讯合同的理论。[⑤]

对于默示成立之资讯合同理论，德国联邦最高法院给出了一些界定条件：（1）

---

① 基本案情：A 公司委托被告会计师制作财务报表，并以该报表为基础，制定股票承销价格。原告信赖被告之稽核，而向 A 公司之其他股东大量收购股票，最后持有 A 公司股份百分之九十。收购结束后，发现公司财务报告显示 120 万英镑的税前利润，但实际上公司亏损额已超过 40 万英镑，因此原告遭受严重亏损，遂起诉被告请求赔偿损失。

② 邱琦：《纯粹经济上损失之研究》，台湾大学法律学研究所 2002 年博士论文，第 110 页。

③ 参见毛大春、王枫：《英国侵权法的注意义务述评》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第 21 卷），金桥文化出版（香港）有限公司 2001 年版，第 453-455 页。

④ BGZ52，365（366f.）。

⑤ 姜世明：《德国自由业者民事责任之请求权基础》，《法令月刊》第五十一卷第三期，第 27-28 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

成立默示成立之资讯合同的情形应该涉及到一个具体的陈述，如报告；（2）提供资讯的人应该知道该资讯对于第三人具有重要性；（3）提供资讯的人应该知道第三人将依据其给出的资讯而对其财产作出法律上的处分。[①]

（2）“附保护第三人作用之合同”制度

德国判例学说所独创的“附保护第三人作用之合同”，是指一些特定的合同一旦成立，就不仅在合同双方当事人之间产生了权利义务关系，而且债务人对与债权人具有特殊关系的第三人，也负有注意及保护等附随义务。债务人如果没有尽到这些附随义务，对该范围内的第三人所受到的损害，也依据合同法的规定承担赔偿责任。[②]“附保护第三人作用之合同”制度，在实务上发展出了一些要件，如：第三人接近给付，第三人的利益纳入债权人的范围，债务人对于第三人接近给付及债权人利益具有可认知性，以及第三人具有保护的必要性。开始德国法院严格恪守这些条件，然而在后来的发展中，德国联邦最高法院，已原则上放弃合同一方当事人必须对第三人的命运负责，即第三人的利益属于债权人范围之内的严格要件，而且即使第三人与合同一方当事人之间具有利益对立关系时，也不妨碍将第三人纳入保护范围的可能性。[③]

（3）缔约过失责任

德国 Canaris 教授认为，专家与委托人以外的第三人之间的关系属于一种准合同关系：具有特殊技能的专家声称自己值得信赖，并且请求他人对其陈述予以信赖。他人因此听从了专家的意见，并且基于对专家意见的信赖而作出了一些影响其财产状况的重要决策。所以，他认为出现了缔约过失责任的要素，没有必要另外寻找专家与委托人以外的第三人之间可能存在的，能与责任相联系的其他合同关系。[④]Canaris 教授的观点影响了德国新债法，并将其规定在新债法中的第 241 条第 2 款，及第 311 条第 3 款中，即根据债务关系的内容，一方可能承担照顾对方权益的义务，并且即使是非合同当事人之间也可能存在这种照顾义务。这种照顾义务特别产生于第三人在一定程度上付出了信赖，且因此对合同的谈判和订立具有显著影响的情形。因此，专家基于缔约过失责任的规定直接对第三方承担责任，而无需特别考虑

---

① 姜世明：《德国自由业者民事责任之请求权基础》，《法令月刊》第五十一卷第三期，第 28 页。

② 王泽鉴：《民法学说与判例研究》（第 2 册），中国政法大学出版社 2001 年版，第 34 页。

③ 姜世明：《德国自由业者民事责任之请求权基础》，《法令月刊》第五十一卷第三期，第 29 页。

④ Michael Coester、Basil Markesinis：《德国法和美国法中的金融专家责任——比较法的运用》，邱雪梅译，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第 35 卷），法律出版社 2005 年版，第 299 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

专家与其契约相对方的关系及契约相对方与第三人之间的关系。[①]

因此，在德国专业人士第三人责任的请求权基础，以前是德国法院创造的默示成立之资讯合同或“附保护第三人作用之合同”，现在是根据德国新债法的规定，因此，专业人士第三人责任成为基于缔约过失责任而产生的直接责任。[②]

3．法国

在法国，第三人因过失不实陈述而遭受纯粹经济损失，可以直接依据法国民法典第 1382 条的一般条款规定提出请求。需要原告向法院证明的仍然是侵权行为的构成要件：加害人的过失、原告的实际损失、二者之间的因果关系。因为在法国法上，纯粹经济损失和人身伤害及财产损害没有区分，都是属于实际损失的范围，并且被一体保护。[③]

然而虽然法国侵权制度没有特别注意纯粹经济损失所代表的损害类型，但像不实陈述这样的案例是对关注潜在问题的例证，即对第三人不确定的、过度的责任问题。一些人坚持认为法国法官完全明白这些危险。然而，他们的关切没有以英国法官的那种方式表达出来，后者通过对“注意义务”情势仔细地剪裁将责任加以限制。在法国，人们认为法官转而将因果关系条件的限制性适用作为控制方式。由于这从未被公开表述出来，所以很难直接考量该政策。下级法院对因果关系的判断受到理论的约束及法国最高法院的监控，但最高法院没有就此问题制定清楚的规则。因此，这种不采取立场的做法导致了相当的混乱。因为因果关系概念是一个可以主观使用的弹性工具，与那些问题在其中得以公开面对，因而也可以使用更精确工具的制度相比，案件结果就不是那么可预见。[④]

三、成立责任的要件分析

（一）过失服务——遗嘱无效案件

如果一个公证人或律师因过失未能起草一个被请求的遗嘱，如果正确起草将从遗嘱中获益的预期受益人，遭受到纯粹经济损失。在许多法律制度中，公证人或律

[①] 李建华、董彪：《专家对第三人承担民事责任的理论基础—兼论德国新债法对我国民事立法的启示》，《社会科学战线》2005 年第 5 期。

[②] Michael Coester、Basil Markesinis：《德国法和美国法中的金融专家责任——比较法的运用》，邱雪梅译，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第 35 卷），法律出版社 2005 年版，第 301 页。

[③] 张国宏：《纯粹经济损失研究》，中国人民大学 2006 年博士学位论文。

[④] [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 340-341 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

师都对损失承担责任，但是法律原因并不相同。在一些司法制度中，认为公证人的合同义务不仅意在保护客户，也保护被期望从遗嘱中受益的人。一些司法制度然后得出结论，这个延伸的保护以侵权法为基础，但是另外的司法制度，完全通过扩张合同义务的保护范围至特定第三人的利益，允许以合同为基础提出请求。这是德国案例的方法，而英国上议院则宁愿允许以侵权行为作为赔偿的法律基础。在政策层面上，经常被用来作为支持失望的受益人请求的证据，首先是没有不确定责任的危险，因为受害方的身份是事先知道的，第二，如果预期的受益人的请求不被允许，则使过失的律师将会“随意行走”。[①]

根据我们前面章节所分析的成立责任时应考虑的因素，也认为应该允许失望的受益人就纯粹经济损失获得赔偿。首先，诉讼闸门理由不成立。因为失望的受益人的身份是已知的且确定的，没有无限多原告的危险。第二，公证人或律师与失望的受益人之间具有某种程度的近因性，因为受益人是被继承人所指定的继承人，属于客户的范围，双方的关系类似于合同关系。第三，公证人或律师没有附加额外的注意义务，因为根据公证人或律师之间的委托合同，他本身就负有按合同正确合法地拟定遗嘱使其生效的义务。第四，损失是可以预见的，因为可能的受害方的身份及牵扯的金额是被告所已知的，被告完全可以预见到如其未能使遗嘱生效，将会给什么人带来什么样的损害，预期的受益人的利益是能够被被告所察知的且具有明确的内容。第五，遗产通常对于受益人来说具有真正的重要性。最后，公证人或律师获得报酬。

根据侵权责任的构成要件进行分析，也得出同样的结论。首先，原告受到了损害，此种损害是正当的且具有严重性；其次，被告有过错，因为双方当事人之间具有某种近因性，也没有导致被告承担额外的注意义务，并且被告获得报酬，所以被告对原告的损失是具有预见的可能性的，因此应认定被告存在过错；最后，被告的行为与原告的损失之间具有因果关系。所以在遗嘱案件中，对失望的受益人的纯粹经济损失进行赔偿是合理的。

（二）不实陈述——专家第三人责任

根据基本的价值判断，专家对第三方纯粹经济损失承担责任，仅在专家故意造

[①] Willem H. van Boom, Pure Economic Loss: A Comparative Perspective, in Willem H. van Boom/ Helmut Koziol/ Christian A.Witting (eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien, New York, 2004, p.23-24.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

成该损失且并无正当理由的情况下成立。但需要注意的是，专家的意见是有价值的商品，在对第三方的纯粹经济损失赔偿上，如果第三方因直接或者间接地信赖专家的意见但第三方没有为此而支付任何费用，则在此情况下对第三方纯粹经济损失的赔偿需要有更为恰当的理由。因此，专家因故意错误陈述而承担纯粹经济损失责任的案件在生活中极少出现。

但是各国普遍认为，如果专家的意见是针对第三方并且意图影响第三人的计划时，则责任要广泛得多。因为在这样的案件中，具有近因性及高度危险性，专家的责任类似于合同法中的责任，则过失行为足够成立责任。

1．反对成立责任的因素

一些因素清楚地反对注册会计师对第三方的经济损失承担责任，即与注册会计师没有合同关系的人的损失：

首先，如果会计师对于委托人之外的所有第三人，如所有投资者承担法律责任，那么潜在原告的数量会无限制，责任的潜在不确定性，使其与注册会计师得到的酬金相比可能是不成比例的，因此诉讼闸门理由非常重要。

第二，会计师和投资者之间通常没有密切接触，因此，类似于合同当事人之间的近因性不存在。

第三，许多大企业投资者和债权人有能力采取其他的措施来保护他们自己，如通过亲自进行调查，通过分解债务或通过几年内在自己的会计准备中分散坏帐。

第四，通常会计师并不确切地知道什么人将信赖他的陈述及他们将基于他的年度财务报表做出什么样的安排，因此第三方的经济利益可能非常不同，对于注册会计师来说一般没有可预见性。

第五，第三方的经济损失通常不会象人身死亡案件中的扶养费损失那么严重。

第六，第三方是一个“搭便车者”，他企图利用别人已经支付过对价的服务，即第三方通常是免费得到信息。

2．赞成成立责任的因素

但是，另一方面，也有很多因素赞成注册会计师对第三方的纯粹经济损失承担责任：

首先，如果专家意见是为特定第三人所作，则没有潜在原告无限多的危险，诉讼闸门理由则不具有重要性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二，虽然注册会计师同第三方之间通常没有类似合同的亲密关系，但是第三方也可能被包含在专家和公司的合同的保护范围内。如法律规定的年度财务报表的公布，则可能成立这样的保护目的。并且，如果专家意图通过陈述而影响第三方的计划时，则也能够认为双方之间具有足够的近因性。这也就是在不实陈述案件中，为什么德国可以运用“附保护第三人作用之合同”理论来保护第三方的纯粹经济损失。

第三，注册会计师同公司之间签订有合同，因此会计师必须谨慎地起草年度财务报表。因此，判决他对第三方的损失承担责任，不会使会计师负担额外的注意义务。

第四，第三方对注册会计师具有合理的信赖，因为注册会计师是一个专业人士，具有专门知识和专门技能，并声称其是可信赖的。

第五，中小投资者在一定程度上信赖会计师公布的陈述，因为他们没有其他途径来获取真实的信息，他们被迫信赖专家的意见，他们缺乏保护自己经济利益的有效手段和途径。

第六，虽然通常第三方的经济利益是不明确的或不被会计师所知道的，但特殊情况下可能具有可预见性，如果会计师知道公司希望将报表呈现给贷款银行，或者他知道其陈述将在招股说明书中提及并且知道投资者将因此而信赖他的报表，或者如果他知道必须公布年度财产证明。因此，在某些案件中，第三方的经济利益是有明确的内容且被注册会计师所察知的，如基于报表授予贷款的银行的利益，或基于涉及明确的年度财务报表的招股说明书而购买股票的投资者的利益。

第七，会计师对于制作年度财务报表收取费用，因此对于提供陈述有经济利益。虽然会计师是从公司处收取费用而不是从想买股票的投资者，或考虑对公司授予贷款的银行那里。

3．可能的结论

通过会计师对第三人责任的利弊权衡，可以得出以下结论：

第一，由于诉讼闸门理由及所有其他反对会计师责任的理由，所以会计师对第三人不承担责任，除非其中一个赞成责任的因素明显存在。因此，当会计师故意制作错误的财务报表的情况下，将成立责任。

第二，如果会计师被他的合同对方（公司），告知他制作的财务报表将提交给

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一个特定的第三方，并且第三方将基于报表作进一步的安排，会计师将对第三方由于错误陈述所导致的损害承担责任。在这样的案件中，诉讼闸门理由根本不重要，近因性成立，并且会计师对第三方的利益具有可预见性。因此，如果会计师有过失，则能够成立对第三方的纯粹经济损失赔偿责任。

第三，在法定报表的情况下，会计师知道其向所有第三方提供信息。虽然具有近因性，但是诉讼闸门理由似乎份量也很重。而且，第三方的经济利益没有明显的界限，并且经济损失似乎不如抚养费损失案件中那样严重。因此必须成立一些额外因素（或者达到比平常更高的程度），这样会计师对第三人纯粹经济损失的责任才合理。如小投资者不得不信赖会计师的陈述，因为他们没有机会获得其他信息，因此成立这样的责任是合理的。反之，对于银行或其他有能力保护自己经济利益的第三方，则不能够成立这样的责任。

根据侵权责任构成要件来分析，首先损害要件可以成立，重要的是过失要件能否成立，即能否认定专业人士具有过错，如果能够认定，则基本上应该成立责任，如果不能认定，则通常不能够成立责任。专业人士具有故意时，则当然能够成立纯粹经济损失的赔偿责任。专业人士不具有故意而仅有过失时，如果第三人为专业人士所明知时，则专业人士对第三人的损害具有预见的可能性，应认为具有过错。如果第三人为专业人士所不能够预见到的，通常不认为专业人士具有过错，但是如果信赖的第三方为银行或其他具有识别能力的人时，则原告自身也有过错，会相应减轻专业人士的责任。因此，根据责任构成要件来判断专业人士的责任时，重点需要考虑：第三人是否为专业人士所明知，即其经济利益是否能够被专业人士所预见，第三人是否有获取真实信息的其他途径，即是否必须相信专业人士的陈述。

四、实例分析

（一）过失服务——王保富诉三信律师事务所财产损害赔偿纠纷案

1．案情介绍[①]

2001 年，原告王保富之父王守智与被告三信律师所签订了《非诉讼委托代理协议》书一份，约定：三信律师所接受王守智的委托，指派张合律师作为王守智的代理人；代理事项及权限为：代为见证；律师代理费用为 6000 元；支付方式为现金；

[①] 参见《最高人民法院公报》2005 年第 10 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

支付时间为2001年8月28日；协议上还有双方约定的其他权利义务。王守智在该协议书上签字，三信律师所在该协议书上加盖了公章，但该协议书未标注日期。同年9月10日，王守智又与三信律师所指派的律师张合签订了一份《代理非诉讼委托书》，内容为：因见证事由，需经律师协助办理，特委托三信律师所律师张合为代理人，代理权限为：代为见证。9月17日，三信律师所出具一份《见证书》，附王守智的遗嘱和三信律师所的见证各一份。王守智遗嘱的第一项为："将位于北京市海淀区北太平庄钟表眼镜公司宿舍11门1141号单元楼房中我的个人部分和我继承我妻遗产部分给我大儿子王保富继承。"见证的内容为："兹有北京市海淀区北太平庄钟表眼镜公司宿舍3楼4门2号的王守智老人于我们面前在前面的遗嘱上亲自签字，该签字系其真实意思表示，根据《中华人民共和国民法通则》第五十五条的规定其签字行为真实有效。"落款处有见证律师张合的签字和三信律师所的盖章。王守智于9月19日收到该《见证书》。

2002年12月9日，王守智去世。原告王保富于2003年1月起诉至北京市海淀区人民法院，要求按照王守智的遗嘱继承遗产。2003年6月30日，北京市第一中级人民法院的终审判决认定：王守智所立遗嘱虽有本人、张合律师签字且加盖北京市三信律师事务所单位印章，但该遗嘱的形式与继承法律规定的自书、代书遗嘱必备条件不符，确认王守智所立遗嘱不符合遗嘱继承法定形式要件，判决王守智的遗产按法定继承处理。王保富因此提起诉讼，要求三信律师所赔偿经济损失。

一审法院根据《民法通则》第106条第2款之规定，认为被告三信律师所在履行与王守智签订的《非诉讼委托代理协议》时，未尽代理人应尽的职责，给委托人及遗嘱受益人造成损失，应当承担赔偿责任，但赔偿范围仅限于原告王保富因遗嘱无效而被减少的继承份额。

二审法院北京市第二中级人民法院根据《民法通则》第106条第2款及《律师法》第49条第1款[①]之规定，认为三信律师所在履行自己职责中具有过错，侵害了王保富依遗嘱继承王守智遗产的权利，由此给王保富造成损失，应当承担赔偿责任。于是驳回上诉，维持原判。

2．判决分析

① 中华人民共和国律师法》第49条第1款规定："律师违法执业或者因过错给当事人造成损失的，由其所在的律师事务所承担赔偿责任。律师事务所赔偿后，可以向有故意或者重大过失行为的律师追偿。"

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一审法院依据《民法通则》第106条第2款之规定，认为“被告三信律师所在履行与王守智签订的《非诉讼委托代理协议》时，未尽代理人应尽的职责，给委托人及遗嘱受益人造成损失，应当承担赔偿责任，但赔偿范围仅限于原告王保富因遗嘱无效而被减少的继承份额。”但是被告未尽到职责，并没有给委托人造成损失，只是使遗嘱受益人受到损失，且其损失为纯粹经济损失。而一审法院并未指出原告损失的性质，就简单以《民法通则》第106条第2款之规定为依据，判决被告对原告的纯粹经济损失承担责任，虽然结论是正确的，但是判决理由不够充分。

二审法院依据《民法通则》第106条第2款及《律师法》第49条第1款之规定，认为“三信律师所履行自己职责中的过错，侵害了王保富依遗嘱继承王守智遗产的权利，由此给王保富造成损失，应当承担赔偿责任。”二审法院的判决理由也是有问题的：首先，二审法院认为被告侵犯了原告“依遗嘱继承王守智遗产的权利”，但这是一种什么“权利”？因为遗嘱并未生效，它既非物权，也非债权，更不属于其他在法律上明确规定的权利类型，事实上遗嘱无效案件中侵害的是财产，而非财产权，[①]更不是什么其他权利。但是二审法院却是认为原告被侵害的权利，并援引了《民法通则》第106条第2款。其次，《律师法》第49条第1款规定：“律师违法执业或者因过错给当事人造成损失的，由其所在的律师事务所承担赔偿责任。律师事务所赔偿后，可以向有故意或者重大过失行为的律师追偿。”遗嘱无效案件中，被继承人显然为“当事人”，这是毫无疑问的，但是被继承人并没有受有损失，受损失的是预期的遗嘱继承人，而预期的遗嘱继承人是否属于“当事人”范畴，很值得探讨。因此二审法院的判决理由也很值得探究。

事实上，根据侵权责任的构成要件，可以得出被告应该承担责任的结论：首先，原告因被告的行为而未能得到预期的遗产，因此受有损失，此种损失具有严重性；其次，被告具有过错，因为原告的损失是在被告能够合理预见的范围内的；最后，被告的过错与原告的损失之间具有因果关系。

（二）不实陈述——蓝田股份造假案

1．案情介绍

2001年10月26日，中央财经大学刘姝威教授在《金融内参》上发表了《应立

[①] 王泽鉴：《比较法、判例研究和实例研习——民商法前沿论坛第341期》，载《中国民商法律网》（www.civillaw.com）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

即停止对蓝田股份发放贷款》的 600 字文稿，蓝田股份资金链开始断裂。2001 年 12 月 13 日，湖北省洪湖市人民法院向刘姝威下达了《应诉通知书》，称“湖北蓝田股份有限公司诉刘姝威侵害名誉权案”将于 2002 年 1 月 23 日开庭，要求刘姝威作为被告出庭。然而事情突然陡起波澜。2002 年 1 月 12 日，蓝田股份三名高管和七名中层干部被抓。

1996 年至 2000 年，蓝田股份在财务数据上一直保持着神奇的增长速度。总资产规模从上市前的 2.66 亿元发展到 2000 年末的 28.38 亿元，增长了 10 倍，历年年报的业绩都在每股 0.60 元以上，最高达到 1.15 元。即使遭遇了 1998 年特大洪灾以后，每股收益也达到了不可思议的 0.81 元，创造了中国农业企业罕见的“蓝田神话”，被称作是“中国农业第一股”。蓝田股份存在造假嫌疑的消息一经公开，便引起了轩然大波，各个专业银行纷纷停止了对其贷款的支持，蓝田股份由此深陷泥潭。

蓝田股份造假丑闻曝光后，公司对有问题的财务报告进行了调整。调整后的财务报告显示：总资产 10.26 亿元，总负债 11.205 亿元，已资不抵债。2003 年 5 月 23 日三大证券报都在头版刊发上交所关于终止蓝田股份上市交易的公告。

湖北蓝田股份有限公司（后改名为“湖北江湖生态农业股份有限公司”，以下简称“生态农业”）因上市时虚增资产，1999 年 10 月 26 日接到证监会的行政处罚决定，蓝田造假案 83 名原告向 11 名被告索赔 617 万余元。2006 年 7 月 31 日 ，武汉市中院一审判决生态农业赔偿原告 540 多万元，包括华伦会计师事务所在内的其他 8 名被告对原告的经济损失承担连带赔偿责任，另外 2 名被告不承担责任。这是会计师事务所在中国内地“虚假陈述证券民事赔偿案”中承担连带责任的首例判决。

对于蓝田股份造假案中华伦会计师事务所(自然涉及该所注册会计师)民事赔偿责任的认定，法院实际上是运用过错推定归责原则。虽然在整个诉讼过程中，华伦会计师事务所进行了抗辩和举证，旨在解除其在该虚假陈述案件中的民事赔偿责任；但抗辩和举证的结果并不能证明其在该案件中没有过错，那也就自然不能解除其所应承担的民事赔偿责任。

法院在审理中认为，华伦会计师事务所违反《会计法》、《审计法》、《证券法》、《公司法》以及上市公司会计准则等有关法律法规，对具有虚假记载内容的生态农业财务报告出具无保留意见的审计结论，纵容生态农业出具虚假财务报告，对广大投资者和社会公众进行欺诈、误导，其行为与生态农业一起均构成虚假陈述。根据

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

相关司法解释，华伦会计师事务所对投资者构成共同侵权，应当承担连带责任。最终判决：华伦会计师事务所应当知道生态农业公司年度报告虚假而出具无保留意见的审计报告，亦构成共同侵权，应与生态农业公司承担连带责任。

2．判决分析

此案是会计师事务所在我国虚假陈述证券民事赔偿案中承担连带责任的第一例判决，进一步凸现了会计师职业界与法律界以及社会公众之间对会计师民事责任的边界问题的争议。该案首次明确：无论会计师事务所是否受到行政处罚，只要虚假陈述行为存在，其就可以作为被告承担赔偿责任。通过法院判决方式让会计师事务所在虚假陈述案中承担连带赔偿责任，蓝田案是证券民事赔偿发展进程中的第一例，其影响和意义远超出了案件本身。

第六节　第三人侵害债权

一、概述

债权名义上看似为一种权利，但实际上其性质更接近于法益，理由是：债权性质上是一种请求权或相对权，仅存在于特定当事人之间，不具有社会公开性，第三人从外界往往很难知悉债权的存在、内容或范围。第三人侵害债权，并未造成债权人的人身伤害或物的有形损害，而是第三人针对债务人所实施的，并因此而间接导致了债权人的损失，因债权并非一种绝对权，因此这种损失也是“非作为权利或受到保护的利益侵害结果存在的损失”，所以第三人侵害债权所造成的损失为纯粹经济损失。[①]

债权作为一种法益，不具有社会公开性，第三人从外界往往很难知悉债权的存在、内容或范围，而且同一债务人有时可能有很多债权人，如果侵害债权动辄成立侵权责任，加害人责任将无限扩大，漫无边际，不符合社会生活中合理分配损害的原则，因此为保护债务人的意思自由，维持社会经济生活的正常秩序，有必要将债权的保护与其他权利的保护区别对待。[②]

---

① 郭明龙：《对“第三人侵害债权”的理论反思》，载《新疆社会科学》2007年第6期。

② 陈忠五：《论契约责任与侵权责任的保护客体：“权利”与“利益”区别正当性的再反省》，载《国立台湾大学法学论丛》第36卷第3期，国立台湾大学法学院出版社2007年版，第99页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

二、各国的具体观点

对于第三人侵害债权，原则上，被告仅就故意干预他人契约关系的行为承担侵权责任，而不就其过失干预他人契约关系的行为承担侵权责任，这是两大法系国家法律的共同规定。

（一）英国

在英国，判例认为，“引诱他人契约违反的行为必须是故意行为，如果行为人并不知道他人契约的存在，或者如果他的行为并不是为了引诱他人违反契约，那么，尽管其行为使他人实际上违反了契约，他也不承担法律责任。”[①]因此被告的主观意图在第三人侵害债权责任的成立上起到决定性的作用。

（二）德国

在德国，债权人与第三人之间并不存在合同关系，所以损害赔偿请求的依据通常只在于侵权。而债权作为一种相对权，并不是《德国民法典》第 823 条第 1 款所规定的权利，因此债权人不能依据第 823 条第 1 款提起诉讼。能够提起请求权的唯一依据在于《德国民法典》第 826 条，该规定支持纯粹经济损失的赔偿，但要求第三人的行为存在故意并且违背了公序良俗。如果第三人并不知道债权人与债务人之间合同的存在，则其行为自始就不存在故意。但是即使第三人确实知道债权的存在，也不一定要承担责任，因为故意侵犯他人合同权利本身不违反公序良俗。任何人都没有义务将其自身的权益附属于他人的合同权利。因此，在第三人侵害债权的情形下，债权人如果要根据第 826 条获得赔偿，就必须证明存在可予归责的特定的侵犯合同权利的情形，如第三人与债务人共谋或者使用不当手段。在个案中需要结合案件的全部情况来判断违背公序良俗的问题，而且这种要求是非常严格的。

（三）法国[②]

在法国，虽然干预他人契约的侵权诉讼建立在法国民法典第 1382 条规定的基础上，但是，它并不适用该条所规定的广泛意义上的过错即过失和轻率行为，而仅适用故意这种过错形式。法国司法曾经指出：“被告不对因疏忽而没有进行调查或没有发现原始合同存在的行为承担侵权责任，第三人不承担此种法定义务，他仅对

---

① 张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 594 页。

② [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 280-281 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

故意引起原告合同性权利损害的行为承担法律责任。”[①]

三、成立责任的要件分析

根据第三章所分析的在成立纯粹经济损失赔偿时需考虑的因素及侵权责任的构成要件，对第三人侵害债权时，责任能否成立进行具体的分析。

首先，如果第三人故意侵害侵权，在多数国家认为都认为原则上可以成立责任，只是对故意的认定会有不同。在故意的情形下，侵权责任的构成要件也都会成立，因此一般应当认为成立赔偿责任。

其次，如果第三人过失侵害债权，多数国家都认为原则上不成立责任，我们也认为在这种情形下，并不具备侵权责任的构成要件：损害要件通常可以成立，因为侵权人因此不能实现债权，确实为一种正当且具有严重性的损害；过错要件通常不能够成立，因为第三人对于债权的存在根本不知道，没有预见的可能性，因此不能认为存在过错，而且侵权人债权的实现要依赖很多因素，不能仅以此认定第三人的侵权与债权人债权的未实现之间具有直接的因果关系，所以第三人对债权人的纯粹经济损失不承担赔偿责任。

四、实例分析——太原市外企服务公司诉《山西晚报》巨额赔偿案

（一）案情介绍

原告太原市外企服务公司拟定于2000年5月25日在太原举行名为“华夏之夜”的演唱会，邀请的演员中包括歌星毛阿敏。为了造势，外企服务公司举行了新闻发布会，并在各媒体发布消息，同时公开售票。三天之内，就售出一万多张票。5月17日，《山西晚报》在未经核实的情况下，引用成都媒体的报道，该报道称“毛阿敏在日本突然患了急性阑尾炎，因此取消了原本定于5月8日在福建的演出，并且也取消了原定于5月17日在四川仁寿举行的枇杷节开幕式”，《山西晚报》因此称“毛阿敏八成不来太原，一睹毛阿敏风采的愿望恐怕也要泡汤了”。随后观众退票八千多张，并且也没有人再买演唱会的票了。尽管毛阿敏本人以及原告外企服务公司迅速作出澄清，被告自己也很快刊登了更正报道，但是仍无济于事，外企服务公司无奈只好赠送两万多张票，使演出勉强举办，但因此蒙受了巨大损失。

[①] 张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社2002年版，第593-594页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2000年8月，外企服务公司将《山西晚报》所属的山西日报社告上法庭，认为由于被告刊登了未经核实的消息，致使演唱会的退票款达到89万元，因此要求被告赔偿包括退票费在内的各项损失共计145万元。2001年初，太原市中级人民法院作出一审判决，认定被告山西日报社刊登不实信息，侵犯了原告企业服务公司的合法权益，因此判决被告赔偿原告退票费损失78万元及广告费等经济损失8万余元，共计87万元。

（二）判决分析

杨立新教授在其《侵害债权的侵权行为》[①]一文中认为此项判决是正确的，但其又认为侵权行为法对侵害债权的构成要求比较严格，其中最重要的要件，为侵害债权的故意和债权关系以外的第三人作为行为人，而侵害债权的故意，他认为“为明知他人享有债权，以引诱、胁迫等方式阻止债务人不履行债务”。但具体到本案中，很难认为被告《山西晚报》具有侵害债权的故意。虽然《山西晚报》明知原告外企服务公司与观众之间有售票合同，但在刊登报道时他并不知道此为不实报道，而且也没有以引诱、胁迫等方式使观众退票，虽然观众退票的行为与被告刊登的报道之间具有因果关系，但很难认定被告的行为具有故意，最多只能认定被告具有过失，未经查实核实就刊登。但过失侵害第三人的债权，导致债权人的纯粹经济损失，通常不能成立赔偿责任。因此笔者认为本案的判决是错误的。

[①] 杨立新：《侵害债权的侵权行为》，载《法律服务时报》2003年11月21日第A06版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章　我国相关立法之检讨

第一节　我国现行法中关于纯粹经济损失的规定

一、关于纯粹经济损失的合同责任规定

我国合同法主要继受大陆法系，但也明显受到英美法系的影响。就一般违约责任而言，以纯粹经济损失为主要赔偿对象，除责任竞合的情形外，通常不包括人身伤害和物的有形损害，这与所有其他国家的立法例并无区别。

（一）《民法通则》中规定的合同责任

违反合同的民事责任被规定在《民法通则》第 111 至 116 条，其中第 111 条规定："当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。"第 112 条规定："当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。当事人可以在合同中约定，一方违反合同时，向另一方支付一定数额的违约金；也可以在合同中约定对于违反合同而产生的损害赔偿额的计算方法。"第 111 条和第 112 条规定的是违约责任，但比较笼统，没有区分各种不同的违约形态而处以不同的责任，第 112 条规定的是损害赔偿责任，但没有明确"所受到的损失"是指什么损失，仅指直接损失，还是也包括间接损失，赔偿范围如何界定？这就在司法实践和法学理论上留下了解释的空间。

（二）《合同法》中规定的违约责任

1999 年的《合同法》的规定，与《民法通则》相比较，则要具体详细很多。《合同法》共规定了四种违约形态：迟延履行（第 94 条的第三、四项）、预期违约（第 108 条）、履行不能（第 110 条）和不完全履行（第 111 条）。第 113 条第 1 款统一规定违约损害赔偿责任："当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到的或者应当预见

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

到的因违反合同可能造成的损失。”此条规定，将当事人一方违约所承担的赔偿责任范围，界定为包括所受损害和所失利益，并且赔偿范围受到可预见性规则的制约，但是所受损害是否包括债权人的人身和其他财产损害，则不明确，仍有解释的余地。

在合同效力扩张方面，1999 年的《合同法》有限的吸收了现代合同法理论和制度发展的成果，吸收了两大法系的一些具体制度规定。

首先，借鉴德国合同法，全面规定了附随义务，《合同法》第 60 条规定：“当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密义务。”这些附随义务的创设，为合同责任的扩展提供了制定法上的依据。

其次确立了缔约过失责任。我国《合同法》第 42 条规定：“当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（一）假借订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚实信用原则的行为。”第 43 条规定：“当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。”这也是借鉴德国合同法的规定，但是我国《合同法》中没有对缔约过失责任的损害赔偿范围作出具体规定，这显然是一个立法上的漏洞。理论上一般认为缔约过失责任的赔偿范围应当包括信赖利益、履行利益和维持利益，其中最主要的是信赖利益损失。这也使得一些纯粹经济损失的赔偿可以通过缔约过失责任得到救济，这也是德国最初成立此项制度的一个初衷。

第三是规定了涉他合同。《合同法》第 64 条规定：“当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。”第 65 条规定：“当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。”我国规定的涉他合同与法国、德国民法中的为第三人利益订立的合同并不相同。大陆法系中的为第三人利益订立的合同具有明确的构成要件及法律效果：在构成要件上，要求合同当事人双方约定，由债务人向第三人为给付，并且双方当事人还需要有使第三人能够直接取得请求权的意思；在法律效果上，第三人可以直接向债务人请求给付，并且当债务人不为给付时，第三人可以直接向债务人主张违约责任。而根据我国合同法的规定，如果债务人不向第三人履行或者履行不适当时，应该向债

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

权人承担违约责任，而不是向第三人承担违约责任，因此并没有赋予第三人直接请求权，第三人并不享有法律上的权利，也不承担法律上的义务，而类似于债权人的履行辅助人或代理人。而在现实经济生活中，为第三人利益订立的合同可以简化交易给付、提高经济效率，因此在实践中具有重要的意义，确有在法律上予以承认的必要。因此我国合同法对于合同效力的扩张，还是持一种相当保守的态度。

二、关于纯粹经济损失的侵权责任规定

（一）《民法通则》第106条第2款

在我国立法中，并没有出现纯粹经济损失的概念。通常认为，《民法通则》第106条第2款确立了侵权责任的一般条款。该款规定："公民、法人由于过错侵害国家的集体的财产，侵害他人的财产、人身的，应当承担民事责任。"学者通常认为不能将该款规定的"侵害他人财产、人身"理解为"侵害他人财产权、人身权"，而应该根据该条文的用语，将其理解为"行为导致他人发生财产、人身损失的，应当承担民事责任"，有点类似法国民法典所采用的一般条款模式。也正因为此，学者大都认为，《民法通则》第106条第2款规定并没有排除纯粹经济损失赔偿的本意。[①]也就是并没有把侵权责任法的保护对象限于权利，尤其是只限于绝对权，而是认为包括纯粹经济利益在内的法益都是侵权责任法的保护对象。

（二）《侵权责任法》第2条

2009年12月26日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议审议通过了《中华人民共和国侵权责任法》。这是继2007年通过《中华人民共和国物权法》之后，我国民事立法活动中又一极为重要的成果，对保护自然人、法人和其他组织的合法权益，明确侵权责任，预防并制裁侵权行为，化解社会矛盾，减少民事纠纷，促进社会公平正义具有重要意义。

第2条是关于侵权人的责任以及侵权责任法保护范围的规定："侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。"从这一规定可以看出：侵权责任法的保护对象为"民事权益"，且列举了一些具体

[①] 张新宝：《侵权责任构成要件研究》，法律出版社2007年版，第180页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的民事权益。

民事权益包括民事权利与民事利益。权利是指为了保护主体的某种利益而赋予的法律的力，它是利益与法律之力的结合。如所有权、生命权、姓名权等。民事利益，是指那些虽然受到法律保护但未被确定为权利的利益，包括人身法益与财产法益，如商业秘密、纯粹经济利益。[①]

侵权责任法的保护范围的确定有两种观点：一是德国的“法益区分保护”的立法模式，一是法国法第 1382 条的模式。按照法国模式，侵权责任法对其保护的权益范围不应在立法上做出限制，原则上权利、利益都应纳入侵权责任法的保护范围。《民法通则》第 106 条采取的就是这种模式。《侵权责任法》前后 3 次审议稿基本上都延续了《民法通则》的模式。《侵权责任法》也继承了这一模式。这种模式有利于建立一个开放、相对独立的侵权责任法体系，符合国际上侵权责任法的发展趋势，例如《日本民法典》第 709 条在修正前，保护范围仅限于权利，现在通过修正，已经扩展到了“权利或受法律保护的利益”。同时，这种模式也更有利于对民事主体权益的保护。[②]

三、保护纯粹经济利益的特别立法

我国有大量的立法和司法解释涉及纯粹经济损失的赔偿问题。以下列举一些。

1．侵权行为人的加害行为致人死亡、受伤或者伤残时，应当赔偿丧葬费、护理人员的各种费用、受害人的被扶养人的生活费等。在这些情形中，这些费用及损失并不是发生直接受害人本人身上的，而是发生在其他人身上的，因此侵害的利益形态为纯粹经济利益。

（1）立法层面上的规定：《民法通则》第 119 条规定：“侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用；造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。”《产品质量法》第 44 条规定：“因产品存在缺陷造成受害人人身伤害的，侵害人应当赔偿医疗费、治疗期间的护理费、因误工减少的收入等费用；造成残疾的，还应当支付残疾者生活自助具费、生活补助费、残疾赔偿金以及由其扶养的人所必需的生活费等费用；

---

① 奚晓明主编：《〈中华人民共和国侵权责任法〉条文理解与适用》，人民法院出版社 2010 年版，第 20 页。

② 奚晓明主编：《〈中华人民共和国侵权责任法〉条文理解与适用》，人民法院出版社 2010 年版，第 20-21 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

造成受害人死亡的，并应当支付丧葬费、死亡赔偿金以及由死者生前扶养的人所必需的生活费等费用。 因产品存在缺陷造成受害人财产损失的，侵害人应当恢复原状或者折价赔偿。受害人因此遭受其他重大损失的，侵害人应当赔偿损失。”《消费者权益保护法》第42条规定：“经营者提供商品或者服务，造成消费者或者其他受害人死亡的，应当支付丧葬费、死亡赔偿金以及由死者生前扶养的人所必需的生活费等费用；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

（2）司法解释层面上的规定，比如《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》（试行）（1988年）第145条规定：“经医院批准专事护理的人，其误工补助费可以按收入的实际损失计算。应得奖金一般可以计算在应赔偿的数额内。本人没有工资收入的，其补偿标准应以当地的一般临时工的工资标准为限。”第147条规定：“侵害他人身体致人死亡或者丧失劳动能力的，依靠受害人实际扶养而又没有其他生活来源的人要求侵害人支付必要生活费的，应当予以支持，其数额根据实际情况确定。”

最高人民法院《关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》第4条规定：“因触电引起的人身损害赔偿范围包括：（四）护理费：受害人住院期间，护理人员有收入的，按照误工费的规定计算；无收入的，按照事故发生地平均生活费计算。也可以参照护工市场价格计算。受害人出院以后，如果需要护理的，凭治疗医院证明，按照伤残等级确定。残疾用具费应一并考虑。（七）丧葬费：国家或者地方有关机关有规定的，依该规定；没有规定的，按照办理丧葬实际支出的合理费用计算。（九）被抚养人生活费：以死者生前或者残者丧失劳动能力前实际抚养的、没有其他生活来源的人为限，按当地居民基本生活费标准计算。被抚养人不满十八周岁的，生活费计算到十八周岁。被抚养人无劳动能力的，生活费计算二十年，但五十周岁以上的，年龄每增加一岁抚养费少计一年，但计算生活费的年限最低不少于十年；被抚养人七十周岁以上的，抚养费只计五年。当事人的亲友参加处理触电事故所需交通费、误工费、住宿费、伙食补助费，参照第一款的有关规定计算，但计算费用的人数不超过三人。”

最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2003年）对此问题进行了系统规定，如第17条规定：“受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。”第 21 条规定：“护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。”第 22 条规定：“交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。”第 23 条规定：“住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。”“受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。”第 27 条规定：“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。”第 28 条规定：“被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的，计算至十八周岁；被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的，计算二十年。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。被扶养人是指受害人依法应当承担扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属。被扶养人还有其他扶养人的，赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被扶养人有数人的，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。”

2．各种专业服务机构因过错导致相关利害关系人遭受损失时，承担的赔偿责任。现行法上涉及这类情形的规定非常多。

（1）注册会计师的责任，如《注册会计师法》第 42 条规定：“会计师事务所违反本法规定，给委托人、其他利害关系人造成损失的，应当依法承担赔偿责任。”

（2）资产评估、验资、验证机构的责任，如《公司法》第 208 条规定：“承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料的，由公司登记机关没收违法所得，处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告的，由公司登记机关责令改正，情节较重的，处以所得收入一倍以上五倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。承担资产评估、验资或者验证的机构因其出具的评估结果、验资或者验证证明不实，给公司债权人造成损失的，除能够证明自己没

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有过错的外，在其评估或者证明不实的金额范围内承担赔偿责任。”

（3）公证机构的责任，如《公证法》第 43 条第 1 款规定：“公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向有故意或者重大过失的公证员追偿。”

（4）证券服务机构的责任，如《证券法》第 173 条规定：“证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。其制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。”

3. 其他明确保护纯粹经济利益的法律。比如经营者不正当竞争的赔偿责任，《反不正当竞争法》第 20 条第 1 款规定：“经营者违反本法规定，给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任，被侵害的经营者的损失难以计算的，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润；并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。”经营者垄断行为致人损害的责任，《反垄断法》第 50 条规定：“经营者实施垄断行为，给他人造成损失的，依法承担民事责任。”证券内幕交易人、操纵市场行为人的责任，《证券法》第 76 条第 3 款规定：“内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。”第 77 条第 2 款规定：“操纵证券市场行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。”发行人等虚假陈述的责任，《证券法》第 69 条规定：“发行人、上市公司公告的招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、临时报告以及其他信息披露资料，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人、上市公司应当承担赔偿责任；发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；发行人、上市公司的控股股东、实际控制人有过错的，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任。”

上述法律，保护的主要是纯粹经济利益。主观要件上，可能是过失责任，也可以是故意责任。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二节　纯粹经济损失的立法建议

在现实世界上，没有哪个国家对于纯粹经济损失一概予以赔偿，也没有哪个国家完全不予赔偿，而是有条件地予以赔偿。冯·巴尔教授说：任何一个法律制度都需要过滤器，将可赔偿性损害与不可赔偿性损害予以区分。这种过滤器的产生方式、动作方式及程度，在本质上取决于：法律是愿意向法院只提供一个具有弹性但相对模糊的工具，如因果关系，并且相信法官们能够通过此弹性工具的使用来合理地权衡当事人之间的利益冲突，达到法律所要达到的目的，还是希望给法官提供一个更加精确的标准和明确的准绳。[①]

一、法国和德国侵权行为法一般条款模式分析

法国和德国分别采用的是上述第一种和第二种方法，这两种方法对于纯粹经济损失的实际处理结果可能存在着很大的差别。两者的差别体现了在对待纯粹经济损失的根本政策上的不同：到底是原则上赔偿纯粹经济损失，还是原则上不赔偿纯粹经济损失。而侵权行为法的一般条款上的区别就体现了这一点。[②]

（一）法国的减法模式

法国侵权行为法一般条款的模式，是在逻辑起点上，各种损害，不问是所受损害还是所失利益，均可以获得赔偿，但是如果存在一些抗辩事由，则可能不予赔偿，因此被形象地称为减法模式。[③]法国法官通常借助于因果关系的直接性和确定性等弹性工具来实现对责任的控制，然而法国的实践表明，在处理结果上，有很多在政策上不宜保护的纯粹经济损失案件，在法国也获得了肯定的判决，而这样的案件在其他国家基本上是不能够获得赔偿的。法国的法官在使用因果关系等弹性工具时，并不公开说明也不公开承认其背后是否有政策的考量，是否是为了适度控制纯粹经济损失的赔偿责任，而且法国最高法院也不明确确立规则。这种模糊的立场导致了司法实践中的混乱，因为因果关系概念是一个可以主观使用的弹性工具，具有相当的模糊性与任意性，导致法国对待纯粹经济损失案件的处理结果的预见性就比较

---

① [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔著，焦美华译：《欧洲比较侵权行为法》（下卷），法律出版社 2001 年版，第 33 页。

② 葛云松：《纯粹经济损失的赔偿与一般侵权行为条款》，载《中外法学》2009 年第 5 期。

③ 葛云松：《纯粹经济损失的赔偿与一般侵权行为条款》，载《中外法学》2009 年第 5 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

差，不象那些公开承认纯粹经济损失背后政策考量的国家那样，可以使用比较精确的控制工具来处理案件，而使当事人可以较为清楚地预见到案件的处理结果。[①]

（二）德国的加法模式

德国的侵权行为法一般条款的模式，与法国模式相反，其在逻辑起点上，只承认侵害权利，特别是绝对权才构成侵权行为，承担侵权责任，除此以外只有符合一些其他的特殊条件，才可以获得法律上的救济，被形象地称为加法模式。因此，德国侵权责任法在保护绝对权的第 823 条第 1 款之外，又规定了两条保护纯粹经济利益的一般通道，即第 823 条第 2 款与第 826 条，但这两条的适用范围很狭窄，并且明确排除了过失侵害其他法律未保护的纯粹经济利益的责任，然后，如果认为有应该受到保护的经济利益时，则通过扩大合同法的方式或解释侵权法的方式，对其提供救济，即“成熟一个、承认一个”。与法国的减法模式相比，德国的加法模式更体现了一种慎重的态度，增强了法律的稳定性和可预见性。[②]

德国民法典制定时之所以没有采用法国模式，主要是从法院的司法过程考虑，认为法国的侵权行为一般条款模式过于概括，使法律解释适用起来很困难，并且认为如果给法官以广泛授权，可能与当时德国人对司法功能的认知不相符合；认为法国侵权责任法因为没有较为明确的规则，法国法院在实务上出现了矛盾与零乱，为了避免这种矛盾和零乱的局面出现，德国立法者最终采用了“权利清单”的一般条款模式。[③]

二、我国侵权责任法的一般条款分析

在《侵权责任法》制定过程中，围绕着侵权责任法保护的法益范围确定，即侵权行为法的一般条款，有不同的观点：一种观点主张，借鉴德国的“法益区分保护”的立法模式，主要规定对权利甚至是绝对权利的保护。另一种观点主张借鉴法国法第 1382 条的模式：《法国民法典》第 1382 条对损害作了概要性规定，以具有高度概括性和包容性的“损害”来指称侵权法的保护对象，但并未具体列举受损利益。按照这种模式，侵权责任法对其保护的权益范围不应在立法上做出限制，原则上权

[①] [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版，第 340-341 页。

[②] 葛云松：《纯粹经济损失的赔偿与一般侵权行为条款》，载《中外法学》2009 年第 5 期。

[③] 王泽鉴：《侵权行为法》（第一册），中国政法大学出版社 2002 年版，第 45 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

利、利益都应纳入侵权责任法的保护范围。《民法通则》第 106 条采取的就是这种模式。《侵权责任法》前后 3 次审议稿基本上都延续了《民法通则》的模式。《侵权责任法》也继承了这一模式。[①]但是这种模式是否真的就是法国模式，是否对于纯粹经济损失的保护能够等同于对绝对权的保护？

（一）违约责任与侵权责任的竞合问题

民事责任的两种形式为侵权责任与违约责任，在大多数情况下，两种责任互不相干，当事人只承担违约责任或者只承担侵权责任，只在极少数的情况下，两种责任会发生竞合，即当事人的违约行为同时构成侵权责任，或当事人的侵权责任同时构成违约行为，《合同法》第 122 条规定："因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。"该条的含义就是，如果当事人的行为既构成违约责任，也构成侵权责任时，当事人可以在诉讼中选择一种来主张。因此我国法律与主流学说的基本观点是，违约行为并不必然构成侵权行为，通常二者是分离的，但在特殊情况下允许责任竞合，《合同法》第 122 条的规定也表明了此观点。

合同一方当事人违约，通常不会造成相对方的人身伤害或物的有形损害，因此给对方当事人造成的损害，通常属于纯粹经济损失的范畴。比如，在买卖合同中，卖方不交付货物或迟延交付货物，那么买方的损失首先就是原本应该取得的货物没有取得，其次还可能因为没有收到货物或迟延收到货物而发生其他损害，如未能及时投入生产而损失利润或将货物已转卖时未能交付货物而承担违约责任。根据法国侵权行为法一般条款模式的解释，任何人均负有不得侵害权利和利益的法定义务，即使是侵害纯粹经济利益也一样构成违约责任，因此债务人违约时就侵犯了债权人的纯粹经济利益，构成侵权行为，应当承担侵权责任。因此，债务人不履行债务而使债权人发生纯粹经济损失的违约行为，就成了典型的侵害他人民事权益的行为，从而构成侵权责任法上的侵权行为。

因此，将纯粹经济利益作为《民法通则》第 106 条第 2 款及《侵权责任法》第 2 条的保护对象时，会导致绝大多数的违约行为同时构成侵权行为。这样，在绝大多数情形下，违约行为都同时构成该款这上的侵权行为，从而依照《合同法》第 122

[①] 奚晓明主编、最高法院侵权责任法研究小组编著：《〈中华人民共和国侵权责任法〉条文理解与适用》，人民法院出版社 2010 年版，第 20-21 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

条发生两种责任的竞合。

对此法国判例学说采用法条竞合说，即禁止竞合的做法，以合同责任排除侵权责任，其主要理由就是因为法国民法典对侵权行为的概括规定，因故意或过失侵害他人者，都应当承担损害赔偿责任，违反合同，即债务不履行本身也可构成侵权行为，因此如果采用竞合说将使合同法上的规定成为一纸空文，不符合立法意旨及当事人利益。[①]

因此，如果认为我国侵权责任法也是按照法国模式采概括规定，凡侵害民事权益者，承担侵权责任，那就应该象法国那样，不允许责任竞合，而应将违约行为视为侵权行为的一种，依照特别法优待于普通法的规则，只发生违约责任，不发生侵权责任。但是，这不符合我国的通说，也显然不符合《合同法》第122条的清楚文义。[②]

（二）缔约过失责任的问题

缔约过失责任，起源于德国法学家耶林的创见，演变发展至今，已成为德国法上稳定成熟、体系繁杂、广泛适用的重要制度，并为许多国家所继受。2002年德国民法债编修正，将此制度在第311条明文加以规定。我国《合同法》第42、43条也对缔约过失责任问题进行了规定。从该规则引入的过程以及立法过程来看，主要受到台湾学说的影响，而台湾学说则是继受德国法的结果。因此，我国合同法中的缔约过失责任制度也是间接继受德国法。

缔约过失责任所保护的客体，除“权利”外，主要是“利益”。对于保护权利而言，德国法上的缔约过失责任制度，主要适用于在缔约过程中，因一方违反保护、照顾等义务而导致侵害他方“人身安全”或“财物完整性”的损害赔偿责任问题。这个问题，涉及侵害他方当事人“权利”的问题，原本属于侵权责任法规范的领域，本应该适用侵权责任的相关规定。然而由于德国侵权责任法相关规定的结果，在过失的举证责任、雇用人是否能够通过举证证明选任监督受雇人时已尽到相当的注意而免责、损害赔偿请求权适用短期诉讼时效期间等问题上，通常不利于被害人，因此有必要加强保护被害人，使其能够在通常比较有利的契约责任法相关规定的基础上，请求损害赔偿，即债务人的过失被推定，必须举证证明其违反契约义务具有不

① 王泽鉴：《民法学说与判例研究》（第八册），中国政法大学出版社2005年版，第243-244页。
② 葛云松：《纯粹经济损失的赔偿与一般侵权行为条款》，载《中外法学》2009年第5期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可归责事由；债务人必须就其使用人的行为承担无过失责任，不得以举证证明选任监督使用人时已尽到相当的注意而免责；损害赔偿请求权可能适用一般诉讼时效期间等。然而，很多学者指出，缔约阶段侵害他人权利的问题，有无必要借助缔约过失责任解决，是一项值得思考的问题。[①]

就利益的保护而言，缔约过失责任制度的创设，旨在解决当事人为缔约契约而接触、磋商、谈判的过程中，因为一方当事人违反义务而侵犯对方当事人利益时的赔偿责任问题。对此问题，由于双方契约关系尚未有效成立，无法适用契约责任的有关规定予以解决，只能适用侵权责任有关规定予以解决。然而由于德国侵权责任法保护客体过于狭隘，对利益的保护明显不足，如果适用侵权责任有关规定，则责任很难成立，然而当事人为缔约合同而接触、磋商、谈判，彼此间的信赖关系与日俱增，有必要加强保护因此而涉及的利益，于是借用契约责任法的原理，来解决缔约过程中所发生的损害赔偿问题。这就德国创设缔约过失责任的两个初衷。

由此可知，缔约过失责任制度的形成背景，与德国侵权责任法区别权利与利益而予以差别性保护的规范框架，具有密切的联系。侵权责任法规范功能上的局限，造成利益保护的规范漏洞，使得原本属于侵权责任法适用领域的问题，必须借助不区别权利与利益而均予以平等保护的契约责任法理，以此来解决问题。[②]

在法国，适用缔约过失责任所解决的问题就完全属于侵权行为法的范畴。法国民法学家均认为，由谈判而产生的先合同义务非合同义务，而是一种法定义务，因此，违反这种法定义务而导致他人权益受损害时，构成侵权行为法上的侵权行为，应当承担过错侵权责任。因为法国民法典第 1382 条保护的对象不限于绝对权，也包括纯粹经济利益，所以并不存在上述问题。[③]

合同缔约过程中一方当事人违反义务导致对方遭受的损害，常常是各种纯粹经济损失（比如增加的交通费、鉴定费、咨询费等费用）。如果认为我国《侵权责任法》平等保护绝对权和纯粹经济利益，过失侵害纯粹经济利益也构成侵权，那么在缔约过失责任的情形下所导致的损失完全可以依据侵权责任法的规定而得到救济。

---

① 陈忠五：《论契约责任与侵权责任的保护客体：“权利”与“利益”区别正当性的再反省》，载《国立台湾大学法学论丛》第 36 卷第 3 期，国立台湾大学法律学院出版 2007 年版，第 202 页。

② 陈忠五：《论契约责任与侵权责任的保护客体：“权利”与“利益”区别正当性的再反省》，载《国立台湾大学法学论丛》第 36 卷第 3 期，国立台湾大学法律学院出版 2007 年版，第 202-203 页。

③ 张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 187 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

同时我国民法上，相当于雇主责任的所有规定，[①]也都没有赋予雇主通过证明自己在选任和监督雇用人时无过失而予以免责的机会。这就意味着德国法上缔约过失责任的基础，在我国完全不存在，《合同法》第42、43条的规定因此纯属多余。

从我国学者研究缔约过失责任时所明确或者隐含表明的观点来看，多数人认为缔约过失责任之所以独立于侵权责任，是因为侵权法主要保护绝对权，不能为缔约上过失所导致的信赖利益损失提供救济。若无该制度，缔约阶段产生的信赖利益就会失去法律保障。这一理论清楚地体现了我国多数学者关于一般侵权行为条款保护范围的理解。[②]

综述，我们应该认为《合同法》规定的缔约过失责任具有独立的规范价值。因此，不能认为《侵权责任法》将纯粹经济损失与绝对权的保护同等对待。

三、对纯粹经济损失的立法建议

《民法通则》第106条第2款及《侵权责任法》第2条的表述，虽然类似法国模式，但是结合《合同法》关于违约责任与侵权责任竞合的规定、关于缔约过失责任的规定，并且从各级法院在司法实践中体现的观点以及主流学说来看，大体上虽然认为侵权责任法的保护范围及于纯粹经济利益，但是保护程度低于绝对权。

（一）国外的立法规定

由欧洲侵权法研究小组所起草的《欧洲侵权法基本原则》反映了上文所触及的一些思想。其第2：102条规定了受保护的利益："（1）受保护利益的范围取决于该利益的性质；价值越高，界定越精确、越明显，其所受保护就越全面。（2）生命、身体和精神的完整性，人的尊严和自由受最全面的保护。（3）财产权包括无形财产权受广泛保护。（4）纯经济利益和契约关系的保护可受更多限制。此时，尤其要充分注意行为人与遭受危险者之间的紧密性，或者行为人知道其利益肯定不如受害人的利益价值大，而其行为将造成损害的事实。（5）保护范围也受责任性质的影响，在故意侵害利益时，对利益的保护程度更高。（6）当确定保护范围时，应考虑行为人的利益尤其是其行动自由与行使权利的利益，以及公共利益。"[③]

[①] 《民法通则》第43、121条，《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》（试行）第58条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第8、9条。

[②] 葛云松：《纯粹经济损失的赔偿与一般侵权行为条款》，载《中外法学》2009年第5期。

[③] 欧洲侵权法小组编著，于敏、谢鸿飞译：《欧洲侵权法原则：文本与评注》，法律出版社2009年版，第4页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在2005年春完成的《奥地利损害赔偿法草案》也体现了同样的理念。其第1293条第2款规定，利益的保护不仅取决于其价值和位阶、内容的明确、察知的难易，同时也要考虑他人的自由发展和权利的实现及公共利益。在这一统一的基础之上，草案于第1298条规定："（1）尤其在债之关系、在法律行为接触、在可以查明相对人依赖于其解释说明或者此种解释说明的目的在于造成相对人的信赖的情况下，以及在保护财产的行为准则中，存在保护纯粹经济利益的注意义务。加害人意识到可能发生损害的并且所威胁的利益与所追求的利益严重不成比例的，通常存在保护纯粹经济利益的注意义务。（2）知晓他人享有债权的，不得有意识地诱发债务人的违约行为，除非其为了维护自己所享有的成立在先的权利或者不知晓他人针对债务人享有债权。某人利用债务人的违约而从中获取利益，其仅在知晓债务人的义务或者此种义务十分明显或者其无法证明无此行为损害仍会发生的情况下承担责任。"[①]

（二）立法建议

我国新出台的《侵权责任法》对纯粹经济损失问题没有进行具体的规定，但是在第2条将侵权责任法的保护范围规定为权利与利益，而且没有区分权利和利益的保护条件，虽然有利于责任的扩张，但由此产生的问题是对于利益的保护，包括纯粹经济利益，应该给予何等程度的保护，即如何限制纯粹经济利益的保护？

我们认为，权利和利益因为特性上的不同，不能给予同等程度的保护，否则也没有必要区分权利和利益了。利益由于其难以具体特定的特性，如果对其进行广泛的保护，将会严重限制人们的行为自由，使行为人对大量难以预见的后果承担赔偿责任，而这显然不符合公平公正合理的原则。因此仍有必要区别权利和利益，而给予不同程度的保护。

最高人民法院侵权责任法研究小组编著的《<中华人民共和国侵权责任法>条文理解与适用》一书也体现了这种观点。[②]其认为：就我国而言，虽然《侵权责任法》原则上将民事权利与利益均列入保护范围，但是由于民事利益（包括纯粹经济损失）的特殊性，并不能不加区分地一概予以保护，在界定哪些民事利益受到侵权责任法保护时，可以考虑以下几个方面的因素：

---

① 海尔穆特·库奇奥著，朱岩、张玉东译：《欧盟纯粹经济损失赔偿研究》，载《北大法律评论》第10卷第1辑（2009），北京大学出版社2009年版，第266页。

② 具体参见奚晓明主编、最高法院侵权责任法研究小组编著：《〈中华人民共和国侵权责任法〉条文理解与适用》，人民法院出版社2010年版，第26-27页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一，民事利益是否被一些特别的保护性法规予以保护，例如，《证券法》第六十九条规定，发行人、上市公司公告的招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、临时报告以及其他信息披露资料，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人、上市公司应当承担赔偿责任；这便是对投资者经济利益的保护。这些保护性法规不限于私法领域，也包括刑法、行政法规这样的公法规范。

第二，侵犯人侵犯该民事利益时的主观状态，如果侵权人主观的状态是故意的，那么被侵犯的民事利益通常可以通过侵权责任法予以保护。

第三，行为人在实施侵害行为时，是否与受害人之间处于一种紧密关系，以至于行为人可以合理预见到他的行为将给受害人的利益带来损害或者受害人可以合理信赖行为人不会从事侵害行为，从而使得对行为人施加危险防免的义务具有合理性。

第四，在界定受保护的利益范围时，要考虑行为人的行为自由；过分的强调受害人利益的保护，可能会限制行为人的行为自由。侵权责任法所追求的在受害人的法益保护与行为人的自由维护之间的平衡点就会被打破。

因此最高人民法院的观点也反映了本文的观点，认为虽然侵权责任法没有规定权利和利益的保护条件，但实质上二者还是不能等量齐观，还是应该有所区别限制。但是应该如何对利益的保护，特别是纯粹经济利益的保护予以限制呢？

根据我们的研究成果，可以借助于侵权责任的构成要件来对纯粹经济损失进行限制，即对于纯粹经济损失的赔偿采用更为严格的构成要件，具体如下：一是损害，要求损害必须具有正当性及严重性；二是过错，要求对损害后果的发生具有预见的可能性，特别考虑当事人双方之间的关系、是否使行为人承担了额外的注意义务、当事人双方之间是否有合理的信赖关系、原告是否有保护自己的其他手段（即原告是否可以采取其他预防措施来避免自己损失的发生，如果有则说明原告自己也有过错，会相应减轻被告的责任）以及当事人双方之间是否具有金钱上的利害关系；三是因果关系，要求被告的行为是原告遭受的纯粹经济损失的直接而确定的后果，并且因果关系的证明责任由原告承担。

事实上，过错和因果关系也是个弹性的工具，要求法官在面对具体案情时，综合考虑各个因素，特别是我们文中分析得出九个因素，如果赞成的因素明显多于反

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对因素，或者有的赞成因素的强度明显高于平常的，可以认定符合侵权责任的构成要件，予以保护。如果反对的因素多于赞成因素，或者反对因素的强度明显高于平常的，则可以以损害不具有严重性、不具有过错、因果关系过于薄弱或原告未能证明因果关系，而予以拒绝。

我们认为具体的规定可以是这样的：

“故意导致的纯粹经济损失应当承担赔偿责任。过失导致的纯粹经济损失，应当特别考虑以下因素：潜在原告数量无限制的可能性，原被告双方之间的近因性，额外的注意义务对行为自由的限制，原告的合理信赖，潜在原告通过其他方式保护自己的能力，原告损失的可预见性，原告遭受经济损失的重要性，当事人双方是否有金钱上的利害关系。因此过失导致的纯粹经济损失，原告应当证明自己遭受的损害的正当性和严重性，被告对原告的损失具有可预见性，原告的损失是被告的过错所直接导致的结果。”

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

结　语

纯粹经济损失的赔偿是侵权法上的一个难题，关系到侵权法与合同法的区别问题，两大法系对此问题进行了深入的研究，而《欧洲侵权法基本原则》草案对此问题也进行了具体的规定，然而我国新出台的《侵权责任法》对此问题未做具体规定，这是一个很大的遗憾，但也说明在我国对此问题仍需要进行深入的研究。希望笔者的此篇文章能够有一定的意义。

对比英国、德国、法国对各个类别的纯粹经济损失类型的具体观点，得出责任排除规则背后的政策考量，再根据一些确定受保护的经济利益的范围，得出纯粹经济损失是否得到赔偿的九个重要因素：行为人的主观心理状态，潜在原告数量无限制的可能性，原被告之间的近因性，是否强加于被告额外的注意义务，原告合理的信赖，潜在原告的保护手段，原告损失的可预见性，原告经济损失的重要性，金钱上的利害关系。由此认为对于过失导致的纯粹经济损失的救济，应当采用更严格的侵权责任构成要件，要求损害具有正当性和严重性，被告对原告的损失具有预见的可能性，过错与损害之间具有直接的因果关系。

显然这不是纯粹经济损失侵权法律责任发展的最终阶段，但我们仍希望这是一个有益的尝试，并能够为法律的最终发展提供一个有价值的意见。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

一、中文著作

1. 陈洁著：《证券民事赔偿制度的法律经济分析》，中国法制出版社 2004 年版。

2. 陈卫佐著：《德国民法总论》，法律出版社 2007 年版。

3. 胡雪梅著：《英国侵权法》，中国政法大学出版社 2008 年版。

4. 黄锫著：《法律经济学：方法论、理论脉络及应用》，浙江大学出版社 2008 年版。

5. 侯国跃著：《契约附随义务研究》，法律出版社 2007 年版。

6. 廖焕国著：《侵权法上注意义务比较研究》，法律出版社 2008 年版。

7. 李国光、贾纬编著：《证券市场事赔偿制度》，法律出版社 2003 年版。

8. 李昊著：《纯经济上损失赔偿制度研究》，北京大学出版社 2004 年版。

9. 李昊著：《交易安全义务论——德国侵权行为法结构变迁的一种解读》，北京大学出版社 2008 年版。

10. 李双元、温世扬主编：《比较民法学》，武汉大学出版社 2000 年版。

11. 刘信平著：《侵权法因果关系理论之研究》，法律出版社 2008 年版。

12. 刘燕著：《会计师民事责任研究：公众利益与职业利益的平衡》，北京大学出版社 2004 年版。

13. 龙卫球著：《民法总论》（第二版），中国法制出版社 2002 年版。

14. 麻昌华著：《侵权行为法地位研究》，中国政法大学出版社 2004 年版。

15. 马俊驹、余延满著：《民法原论》（第三版），法律出版社 2008 年版。

16. 梅夏英著：《中华人民共和国侵权责任法讲座》，中国法制出版社 2010 年版。

17. 彭真明著：《注册会计师对第三人民事责任研究》，中国社会科学出版社 2006 年版。

18. 曲振涛著：《法经济学》，中国发展出版社 2005 年版。

19. 史晋川著：《法经济学》，北京大学出版社 2007 年版。

20. 唐先锋、赵春兰、王洪宇著：《我国专家民事责任制度研究》，法律出版社 2005 年版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

21. 田韶华、杨清著：《专家民事责任制度研究》，中国检察出版社 2005 年版。

22. 熊进光著：《侵权行为法上的安全注意义务研究》，法律出版社 2007 年版。

23. 王成著：《侵权损害赔偿的经济分析》，中国人民大学出版社 2002 年版。

24. 王军著：《侵权法上严格责任的原理和实践》，法律出版社 2006 年版。

25. 王军主编：《侵权行为法比较研究》，法律出版社 2006 年版。

26. 王利明、崔建远著：《合同法新论.总则》（修订版），中国政法大学出版社 2000 年版。

27. 王利明著：《民法总则研究》，中国人民大学出版社 2003 年版。

28. 王利明著：《侵权行为法归责原则研究》（修订二版），中国政法大学出版社 2004 年版。

29. 王利明著：《侵权行为法研究》（上卷），中国人民大学出版社 2004 年版。

30. 王利明著：《违约责任论》（修订版），中国政法大学出版社 2000 年版。

31. 王利明主编：《民法典.侵权责任法研究》，人民法院出版社 2003 年版。

32. 王胜明主编、全国人大法工委民法室著：《<中华人民共和国侵权责任法>条文解释与立法背景》，人民法院出版社 2010 年版。

33. 王文杰主编：《月旦民商法研究:侵权行为法之立法趋势》，清华大学出版社 2006 年版。

34. 奚晓明主编、最高人民法院侵权责任法研究小组编著：《<中华人民共和国侵权责任法>条文理解与适用》，人民法院出版社 2010 年版。

35. 杨立新著：《侵权法论》（第三版），人民法院出版社 2005 年版。

36. 杨立新编：《中华人民共和国侵权责任法草案建议稿及说明》，法律出版社 2007 年版。

37. 杨垠红著:《侵权法上作为义务——安全保障义务之研究》,法律出版社 2008 年版。

38. 叶金强著：《信赖原理的私法结构》，元照出版社 2006 年版。

39. 于敏著：《日本侵权行为法》（第二版），法律出版社 2006 年版。

40. 余延满著：《合同法原论》，武汉大学出版社 2003 年版。

41. 张家勇著：《为第三人利益的合同的制度构造》，法律出版社 2007 年版。

42. 张民安著：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社 2002 年版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

43. 张民安著：《现代法国侵权责任制度研究》（第二版），法律出版社 2007 年版。

44. 张民安主编：《民商法学家》（第 1 卷），中山大学出版社 2005 年版。

45. 张民安主编：《民商法学家》（第 2 卷），中山大学出版社 2006 年版。

46. 张民安主编：《民商法学家》（第 3 卷），中山大学出版社 2007 年版。

47. 张民安主编：《民商法学家》（第 4 卷），中山大学出版社 2008 年版。

48. 张民安主编：《侵权法报告》，中信出版社 2005 年版。

49. 张新宝著：《侵权责任法原理》，中国人民大学出版社 2005 年版。

50. 张新宝著：《侵权责任构成要件研究》，法律出版社 2007 年版。

51. 周林彬、董淳锷著：《法律经济学》，湖南人民出版社 2008 年版。

52. 周友军著：《交往安全义务理论研究》，中国人民大学出版社 2008 年版。

53. 朱广新著：《信赖责任研究—以契约之缔结为分析对象》，法律出版社 2007 年版。

54. 布吕格迈耶尔、朱岩著：《中国侵权责任法学者建议稿及其立法理由》，北京大学出版社 2009 年版。

55. 陈聪富著：《侵权归责原则与损害赔偿》，北京大学出版社 2006 年版。

56. 陈聪富著：《因果关系与损害赔偿》，台湾元照出版有限公司 2004 年版。

57. 黄立主编：《民法债编各论》（上、下），中国政法大学出版社 2003 年版。

58. 黄立著：《民法债编总论》，自版发行， 2006 年修正三版。

59. 黄立著：《民法总则》，自版发行，2005 年第四版。

60. 黄茂荣著：《法学方法与现代民法》（第五版），法律出版社 2007 年版。

61. 简资修著：《经济推理与法律》，台湾元照出版有限公司 2006 年第二版。

62. 姜世明著：《律师民事责任论》，台湾元照出版有限公司 2004 年版。

63. 林诚二著：《民法总则》（上、下），法律出版社 2008 年版。

64. 梅仲协著：《民法要义》，中国政法大学出版社 2004 年版。

65. 潘维大、黄阳寿编著：《英美契约法案例解析——兼与本国法比较》（一、二），台湾瑞星图书有限公司 1997 年版。

66. 潘维大编著《英美侵权行为法案例解析》（上、下），台湾瑞星图书有限公司 1997 年版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

67. 邱聪智著：《从侵权行为归责原理之变化论危险责任之构成》，中国人民大学出版社 2006 年版。

68. 史尚宽著：《民法总论》，中国政法大学出版社 2000 年版。

69. 史尚宽著：《债法总论》，中国政法大学出版社 2000 年版。

70. 王泽鉴著：《法律思维与民法实例》，中国政法大学出版社 2002 年版。

71. 王泽鉴著：《民法学说与判例研究》（1-8 册），中国政法大学出版社 2005 年修订版。

72. 王泽鉴著：《民法总则》（修订版），中国政法大学出版社 2002 年版。

73. 王泽鉴著：《债法原理（三）·侵权行为法（第一册）：基本理论、一般侵权行为》，中国政法大学出版社 2002 年版。

74. 王泽鉴著：《债法原理（三）·侵权行为法（第二册）：特殊侵权行为》，台湾元照出版有限公司 2006 年版。

75. 王泽鉴著：《侵权行为》，北京大学出版社 2009 年版。

76. 姚志明著：《诚信原则与附随义务之研究》，自版发行 2003 年版。

77. 姚志明著：《侵权行为法》，自版发行 2005 年版。

78. 姚志明著：《侵权行为法研究》（一），自版发行 2003 年版。

79. 姚志明著：《债务不履行——不完全给付之研究》，中国政法大学出版社 2003 年版。

80. 姚志明著：《债务履行之研究（一）——给付不能、给付迟延与拒绝给付》，自版发行 2004 年版。

81. 曾隆兴著：《详解损害赔偿法》，中国政法大学出版社 2004 年版。

82. 曾世雄著：《民法总则之现在与未来》，中国政法大学出版社 2001 年版。

83. 曾世雄著：《损害赔偿法原理》，中国政法大学出版社 2001 年版。

84. 张志朋著：《论我国商品责任之请求权主体—消费者与第三人区别之必要性》，新学林出版有限公司 2005 年版。

85. [美]安德雷·马默主编，张卓明、徐宗立等译：《法律与解释》（法哲学论文集），法律出版社 2006 年版。

86. [澳]彼得·凯恩著，王仰光、朱呈义、陈龙业、吕杰译：《阿蒂亚论事故、赔偿及法律》（第六版），中国人民大学出版社 2008 年版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

87. 陈卫佐译注：《德国民法典》，法律出版社 2004 年版。

88. [美]大卫·D·弗里德曼著，杨欣欣译：《经济学语境下的法律规则》，法律出版社 2007 年版。

89. [美]道格拉斯·G·拜尔、[美]罗伯特·H·格特纳、[美]兰德尔·C·皮克著，严旭阳译：《法律的博弈分析》，法律出版社 2006 年版。

90. [德]迪特尔·梅迪库斯著，邵建东译：《德国民法总论》，法律出版社 2004 年版。

91. [德]迪特尔·梅迪库斯著，杜景林、卢谌译：《德国债法总论》，法律出版社 2004 年版。

92. [美]E·博登海默著，邓正来译：《法理学 法律哲学与法律方法》，中国政法大学 2004 年修订版。

93. [美]盖多·卡拉布雷西著，毕竟悦、陈敏、宋小维译：《事故的成本：法律与经济的分析》，北京大学出版社 2008 年版。

94. [美]格瑞尔德·J·波斯特马主编，陈敏、云建芳译：《哲学与侵权行为法》，北京大学出版社 2005 年版。

95. [德]汉斯-贝恩德·舍费尔、克劳斯·奥特著，江清去、杜涛译：《民法的经济分析》（第四版），法律出版社 2009 年版。

96. [德]卡尔·拉伦茨著，王晓晔等译：《德国民法通论》（上、下），法律出版社 2003 年版。

97. [德]卡尔·拉伦茨著，陈爱娥译：《法学方法论》，商务印书馆 2005 年版。

98. [美]凯斯·R·桑斯坦主编，涂水前、成凡、康娜译：《行为法律经济学》，北京大学出版社 2006 年版。

99. [德]克里斯蒂安·冯·巴尔著，张新宝译《欧洲比较侵权行为法》（上卷），法律出版社 2001 年版。

100. [德]克里斯蒂安·冯·巴尔著，焦美华译《欧洲比较侵权行为法》（下卷），法律出版社 2001 年版。

101. [德]克里斯蒂安·冯·巴尔等主编，吴越等译：《欧洲合同法与侵权法及财产法的互动》，法律出版社 2007 年版。

102. [美] 肯尼斯·S·亚伯拉罕、阿尔伯特·C·泰特选编，许传玺、石宏译：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

《侵权法重述——纲要》，法律出版社 2006 年版。

103. [德]莱因哈德·齐默曼、[英]西蒙·惠特克主编，丁广宇、杨才然、叶桂峰译：《欧洲合同法中的诚信原则》，法律出版社 2005 年版。

104. [美]理查德·A·波斯纳著，苏办译：《法理学问题》，中国政法大学出版社 2005 年版。

105. [美]罗斯科·庞德著：《法理学》（1-4 卷），法律出版社 2007 年版。

106. [德]马克西米利安·福克斯著，齐晓琨译：《侵权行为法》（2004 年第 5 版），法律出版社 2006 年版。

107. [意]毛罗·布萨尼、[美]弗农·瓦伦丁·帕尔默主编，张小义、钟洪明译：《欧洲法中的纯粹经济损失》，法律出版社 2005 年版。

108. [美]斯蒂文·G·米德玛编，罗君丽、李井奎、茹玉骢译：《科斯经济学：法与经济学和新制度经济学》，上海三联书店 2007 年版。

109. [美]斯蒂文·萨维尔著，翟继光译：《事故法的经济分析》，北京大学出版社 2004 年版。

110. [美]唐纳德·A·威斯曼编，苏力等译：《法律经济学文献精选》，法律出版社 2006 年版。

111. [美]Vincent R·Johnson 著，赵秀文、杨智杰译：《英美侵权法》，台湾五南出版有限公司 2006 年版。

112. [美]威廉·M·兰德斯、理查德·A·波斯纳著，王强、杨媛译：《侵权法的经济结构》，北京大学出版社 2005 年版。

113. [美]William Burnham 著，林利芝译：《英美法导论》，中国政法大学出版社 2003 年版。

114. 肖永平、龚乐凡、汪雪飞译：《侵权法重述第三版：产品责任》，法律出版社 2006 年版。

115. 徐爱国组织编译：《哈佛法律评论.侵权法学精粹》，法律出版社 2005 年版。

116. [日] 圆谷峻著，赵莉译：《判例形成的日本新侵权行为法》，法律出版社 2008 年版。

117. [美]詹姆斯·戈德雷著，张家勇译：《私法的基础：财产、侵权、合同和不当得利》，法律出版社 2007 年版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

118. 朱岩编译：《德国新债法条文及官方解释》，法律出版社 2003 年版。

119. 欧洲侵权法小组编著，于敏、谢鸿飞译：《欧洲侵权法原则：文本与评注》，法律出版社 2009 年版。

120. H·考茨欧主编，张家勇译：《侵权法的统一：违法性》，法律出版社 2009 年版。

121. J·施皮尔主编，易继明等译：《侵权法的统一：因果关系》，法律出版社 2009 年版。

122. J·施皮尔主编，梅夏英、高圣平译：《侵权法的统一：对他人造成的损害的责任》，法律出版社 2009 年版。

123. U·马格努斯主编，谢鸿飞译：《侵权法的统一：损害与损害赔偿》，法律出版社 2009 年版。

124. U·马格努斯，M·马丁-卡萨尔斯主编，叶名怡、陈鑫译：《侵权法的统一：共同过失》，法律出版社 2009 年版。

二、中文论文

1. 廖一帆：《船舶碰撞中定期承租人的纯经济损失》，载《中国海商法年刊》第 4 卷。

2. 浦川道太郎著，梁慧星译：《德国的专家责任》，载梁慧星主编《民商法论丛》（第 5 卷），法律出版社 1996 年版。

3. 刘桥：《注册会计师民事责任研究》，载梁慧星主编《民商法论丛》（第 16 卷），金桥文化出版（香港）有限公司 2000 年版。

4. 毛大春、王枫：《英国侵权法的注意义务述评》，载梁慧星主编《民商法论丛》（第 21 卷），金桥文化出版（香港）有限公司 2001 年版。

5. 马俊驹、白飞鹏：《对财产上法益间接损害的民法救济：保护与限制》，载《法学评论》2001 年第 2 期。

6. 王成：《过失的经济分析》，载梁慧星主编：《民商法论丛》（第 22 卷），金桥文化出版（香港）有限公司 2002 年版。

7. 张民安、龚赛红：《专业人士所承担的过错侵权责任》，载《法学评论》2002 年第 6 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

8. D.W.Roberston 著，刘慧译：《义务的新领域：纯粹经济损害》，载张新宝主编《侵权法评论》（2003 年第 1 辑），人民法院出版社 2003 年版。

9. 程啸：《英美法中虚假陈述的民事责任》，载张新宝主编《侵权法评论》2003 年第 1 辑，人民法院出版社 2003 年版。

10. 国立波：《英美侵权法上产生谨慎义务的特殊关系研究》，载张新宝主编《侵权法评论》（2003 年第 1 辑），人民法院出版社 2003 年版。

11. 刘生亮译：《欧洲侵权行为法草案》，载张新宝主编《侵权法评论》（2003 年第 1 辑），人民法院出版社 2003 年版。

12. 卢子亮：《纯粹经济损失初探》，载《江苏警官学院学报》2003 年第 1 期。

13. 王颖琼、黄长明、徐斌：《纯粹经济损失理论之践行——评《山西日报》巨额赔偿案》，载《时代法学》2003 年第 2 期。

14. 章英杰：《论纯粹经济上损失的过失侵权责任》，载《当代法学》2003 年第 7 期。

15. 王小玉：《第三人侵害债权制度研究》，载刘士国主编《侵权责任法若干问题研究》，山东人民出版社 2004 年版。

16. 许德风：《对第三人具有保护效力的合同与信赖责任——以咨询责任为中心》，载易继明主编：《私法》（第 4 辑第 2 卷），北京大学出版社 2004 年版。

17. 覃有土、晏宇桥：《论侵权的间接损失认定》，载《现代法学》2004 年第 4 期。

18. 彭真明、江华：《论证券分析师对第三人的民事责任》，载《中国民族大学学报（人文社会科学版）》2004 年第 4 期。

19. 张湘兰、朱强：《论纯经济损失的侵权责任—从欧洲比较法展开》，载《时代法学》2004 年第 5 期。

20. 许德风：《论合同法上信赖利益的概念及对成本费用的损害赔偿》，载《北大法律评论》2005 年第 6 卷第 2 辑（2005），北京大学出版社 2005 年版。

21. 周友军：《纯经济损失及其救济——“上海方舟旅行社诉东方航空公司航班延误赔偿案”评析》，载王利明主编：《判解研究》2005 年第 2 辑。

22. 李建华、董彪：《专家对第三人承担民事责任的理论基础——兼论德国新债法对我国民事立法的启示》，载《社会科学战线》2005 年第 5 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

23. 李昊：《论英美侵权法中过失引起的纯经济上损失的赔偿规则》，载《比较法研究》2005 年第 5 期。

24. 彭真明：《论注册会计师不实财务报告民事责任的性质——以对第三人责任为中心》，载《甘肃政法学院学报》2005 年第 5 期。

25. 邱雪梅：《论金融专家对第三人的民事责任——以德国法为借鉴》，载《广东商学院学报》2005 年第 6 期。

26. 周友军：《社会安全义务理论及其借鉴》，载梁慧星主编《民商法论丛》（第 34 卷），法律出版社 2006 年版。

27. Michael Coester、Basil Markesinis 著，邱雪梅译：《德国法和美国法中的金融专家责任——比较法的运用》，载梁慧星主编《民商法论丛》第 35 卷，法律出版社 2006 年版。

28. 王卫东：《德国法上纯粹经济损失分析》，载《德国研究》2006 年第 3 期。

29. 朱广新：《论纯粹经济上损失的规范模式——我国侵权行为法对纯粹经济上损失的规范样式》，载《当代法学》2006 年第 5 期。

30. 李昊：《德国专家责任的建构——以保护纯经济上损失的交易安全义务为基础》，载《华中法律评论》编委会主编：《华中法律评论》（第 1 辑第 1 卷），华中科技大学出版社 2007 年版。

31. 廖建求、姜孝贤：《纯粹经济损失的法经济学分析》，载《制度经济学研究》第 17 辑，经济科学出版社 2007 年版。

32. 余艺：《过失致人纯粹经济损失不予赔付规则及其突破》，载《政治与法律》2007 年第 1 期。

33. 唐松青：《专业人员对第三人责任问题比较研究》，载《湖南大学学报（社会科学版）》2007 年第 3 期。

34. 张新宝、张小义：《论纯粹经济损失的几个基本问题》，载《法学杂志》2007 年第 4 期。

35. 朱慈蕴、陈彦晶：《评注册会计师对第三人的民事责任——围绕会计界和法律界的观点冲突展开》，载《法学评论》2007 年第 4 期。

36. 周学峰：《审计师对第三人过失性虚假陈述责任比较研究》，载《比较法研究》2007 年第 6 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

37. 李静：《违反信息义务致损的民事救济——从德国法与英美法之比较展开讨论》，载《法商研究》2007年第6期。

38. 郭明龙：《对“第三人侵害债权”的理论反思》，载《新疆社会科学》2007年第6期。

39. 黄莉萍、朱娟：《侵权中纯经济损失保护模式的比较探讨》，载《广西社会科学》2007年第10期。

40. 王利明、周友军：《民法典创制中的中国民法学》，载《中国法学》2008年第1期。

41. 李岩：《纯粹经济损失法益性质之界定》，载《沈阳师范大学学报（社会科学版）》2008年第1期。

42. 李开国：《侵权责任构成理论研究——一种新的分析框架和路径的提出》，载《中国法学》2008年第2期。

43. 周友军：《我国侵权法上作为义务的扩张》，载《法学》2008年第2期。

44. 郭佳宁：《侵权法扩张趋势下的纯经济损失问题》，载《社科纵横》2008年第2期。

45. 徐海燕、朱辰昊：《纯粹经济损失赔偿制度研究——兼论证券市场中介机构不实陈述的民事责任》，载《甘肃社会科学》2008年第3期。

46. 王利明：《我国侵权责任法的体系构建——以救济法为中心的思考》，载《中国法学》2008年第4期。

47. 郭明瑞：《侵权立法若干问题思考》，载《中国法学》2008年第4期。

48. 冯珏：《汉德公式的解读与反思》，载《中外法学》2008年第4期。

49. 张新宝：《侵权死亡赔偿研究》，载《法学研究》2008年第4期。

50. 龚赛红：《中国民法视野中的纯经济损失——兼评我国的研究现状》，载《北京化工大学学报（社会科学版）》2008年第4期。

51. 李岩：《民事法益的界定》，载《当代法学》2008年第5期。

52. 田韶华、刘改娟：《纯经济损失特征、保护模式及在我国的适用现状》，载《产业与科技论坛》2008年第7卷第9期。

53. 张新宝、李倩：《纯粹经济损失赔偿规则：理论、实践及立法选择》，载《法学论坛》2009年第1期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

54. 梅夏英：《侵权法一般条款与纯粹经济损失的责任限制》，载《中州学刊》2009 年第 4 期。

55. 张平华：《英美产品责任法上的纯粹经济损失规则》，载《中外法学》2009 年第 5 期。

56. 毛罗.布萨尼著，徐铁英译：《西方对待过失侵权法的态度：一项比较性的批判研究》，载《中外法学》2009 年第 5 期。

57. 葛云松：《纯粹经济损失的赔偿与一般侵权行为条款》，载《中外法学》2009 年第 5 期。

58. 陈嘉昌、胡佳宵：《论过失引起纯粹经济损失中的责任排除规则》，载《合肥学院学报（社会科学版）》2009 年第 6 期。

59. 陈彦良：《未明文法律制度之法典化——德国民法上的缔约过失》，载《台北大学法学论丛》第 56 期。

60. 陈忠五：《法国侵权责任法上损害之概念》，载《国立台湾大学法学论丛》第 30 卷第 4 期，国立台湾大学法律学院出版 2001 年版。

61. 陈忠五：《产前遗传诊断失误的损害赔偿责任》，载《国立台湾大学法学论丛》第 34 卷第 6 期，国立台湾大学法律学院出版 2005 年版。

62. 陈忠五：《论契约责任与侵权责任的保护客体：“权利”与“利益”区别正当性的再反省》，载《国立台湾大学法学论丛》第 36 卷第 3 期，国立台湾大学法律学院出版 2007 年版。

63. 陈忠五：《论法国交通事故损害赔偿责任的成立要件——损害、牵连关系与归责关系之研究》，载《政大法学评价》第 97 期，国立政治大学法学院出版 2007 年版。

64. 姜世明：《德国自由业者民事责任之请求权基础》，载《法令月刊》第 51 卷第 3 期。

65. 姜世明：《律师第三人责任制度之研究》，载《法律评论》第 67 卷第 10-12 期合刊。

66. 廖大颖：《论企业揭露不实资讯与损害赔偿之因果关系-兼评台北地方法院八十七年度重诉字第一三四七号民事判决的认定基础》，载《月旦法学》第 153 期。

67. 刘春堂：《侵害生命权之财产上损害赔偿责任》，载《辅仁法学》第 34 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

68. 苏永钦：《缔约过失责任的经济分析——从现代交易的阶段化谈起》，载《台大法学评论》第33卷第1期。

三、学位论文

1. 周学峰：《公司审计与专家责任》，中国政法大学2004年博士学位论文。

2. 张国宏著：《纯粹经济损失研究》，中国人民大学2006年博士学位论文。

3. 李岩著：《民事法益研究》，吉林大学2007年博士学位论文。

4. 仲伟珩著：《专家第三人责任制度研究》，中国政法大学2007年博士学位论文。

5．杨雪飞著：《纯粹经济损失之赔偿与控制——以行为人对受害人责任为视角》，中国政法大学2008年博士学位论文。

6. 邵海著：《责任保险影响下现代侵权法的嬗变》，重庆大学2008年博士学位论文。

7. 郭平宜著：《第三人侵害缔约关系的民事责任研究》，西南政法大学2009年博士学位论文。

8. 涂咏松著：《信赖损害赔偿责任研究》，西南政法大学2009年博士学位论文。

9. 林美惠著：《侵权行为法上交易安全义务之研究》，国立台湾大学法律学研究所2000年博士论文。

10. 邱琦著：《纯粹经济上损失之研究》，国立台湾大学法律学研究所2002年博士论文。

四、外文资料类

1. Avery Viener Katz，Foundations of fhe Economic Approcch to Law（影印本），法律出版社2005年版。

2. Basis Markesinis，Compensation for Personal Injury in English, German and Italian Law，Cambridge University Press，2005.

3. Christian v. Bar, Negligence, Eigentumsverletzung und reiner Vermögensschaden zu den Grenzen der Fahrlässigkeitshaftung für reine Vermögensschäden in der neueren Entwicklung des Common Law，in “Rabels Zeitschrift für ausländischer und

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

internationales Privatrecht", Band 56 Heft 3.

4. David Gruning, Pure Economic Loss in American Tort Law: An Unstable Consensus, in "The American Journal of Comparative Law", Volume 54 (Supplement) 2006.

5. Efstsithios K.Banakas(ed.), Civil Liability for Pure Economic Loss, Kluwer Law,1998.

6. Fabio Delco, Die Bedeutung des Grundsatzes von Treu und Glauben beim Ersatz reiner Vermögensschäden, Schulthess Juristische Medien AG, 2000.

7. Fernando Gómez、and Hans-Bernd Schäfe,The law and economics of pure economic loss: Introduction to the special issue of the International Review of Law and Economics, in "International Review of Law and Economics", Volume 27, Issue 1, March 2007.

8. Francesco Parisi、Vernon Valentine Palmer、Mauro Bussan, The comparative law and economics of pure economic loss, in "International Review of Law and Economics", Volume 27, Issue 1, March 2007.

9. Gerhard Wagner(ed.), Tort Law and Liability Insurance, Springer, 2005.

10. Guiseppe Dari-Mattiacci、Hans Bernd Schäfer, The core of pure economic loss, in "International Review of Law and Economics", Volume 27, Issue 1, March 2007.

11. Hans-Friedrich Müller, Die Einführung des Vertrages zugunsten Dritter in des englische Recht, in "Rabels Zeitshrift für ausländisches und internationale Privatrecht", Band 67(2003), Heft 1(Februar).

12. J.R.Spencer, Libality for purely economic loss again: "small earthquake in chile not many dead"?, in "The Cambridge Law Journal", Vol.165.

13. Michael Furmston(ed.), The Law of Tort: Policies and Trends in Liability for Damage to Property and Economic Loss, Duckworth, 1986.

14. Paul Mitchell、Charles Mitchell, Negligence Liability for Pure Economic Loss, in "Law Quarterly Review", Vol.12, April 2005.

15. Peter Cane, Tort Law and Economic Interests, Clarendon Press. Oxford, 1996.

16. Peter Gauch Justin Sweet, Deliktshaftung für reinen Vermögensschaden.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

17. Ray Hodgin，Proefssional Liability: Law and Insurance，LLP，1999（2nd）.

18. Richard Owen，Essential Tort Law，武汉大学出版社，2004 年第 3 版.

19. Saul Levmore，Foundations of Tort Law（影印本），法律出版社 2005 年版。

20. Spier Jeep, The Limits of Expanding Liability，Kluwer Law International, 1998.

21. Urs Schweizer, Tortious acts affecting markets， in "International Review of Law and Economics", Volume 27, Issue 1, March 2007.

22. William Lucy，Philosophy of Private Law，Oxford University Press, 2007.

23. Willem H. van Boom、Helmut Koziol、Christian A. Witting(eds.), Pure Economic Loss, Springer Wien New York, 2004.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

攻读博士期间发表的科研成果目录

1.《论专家第三人民事责任制度的建构——从比较法的视角兼谈我国侵权责任法的完善》，发表于《理论与改革》2008 年第 4 期，获徐州市第九届哲学社会科学优胜成果三等奖。

2.《论“附保护第三人作用之合同”——兼谈我国侵权责任法的完善》，发表于《求索》2009 年第 10 期。

3.《注册会计师对第三人民事责任性质的研究》，发表于《商业时代》2009 年第 21 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net